

NILIO BATISTA

APONTAMENTOS PARA UMA HISTÓRIA DA LEGISLAÇÃO PENAL BRASILEIRA

*Apontamentos para uma história da
legislação penal brasileira é um
fragmento do livro **Direito Penal
Brasileiro - I**, dos autores Alejandro
Alagia, Alejandro Slokar, E. Raul Zaffaroni
e Nilo Batista. Trata-se do item 18 do
"Capítulo VI: Dinâmica histórica da
legislação penal (criminalização primária)"
do livro original.*

NILIO BATISTA

APONTAMENTOS PARA UMA HISTÓRIA DA LEGISLAÇÃO PENAL BRASILEIRA



ISBN 85-347-0863-0



Editora Revan

Nilo Batista

Professor titular de direito penal que foi da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, da Universidade Federal do Rio de Janeiro e da Universidade Candido Mendes. Presidente do Instituto Carioca de Criminologia. Advogado.

**Apontamentos para uma
história da legislação penal
brasileira**



Editora Revan

Copyright © 2016 by Editora Revan

Todos os direitos reservados no Brasil pela Editora Revan Ltda. Nenhuma parte desta publicação poderá ser reproduzida, seja por meios mecânicos ou eletrônicos, seja via cópia xerográfica, sem autorização prévia da editora.

Revisão
Roberto Teixeira

Capa
Mariana Vianna Abramo

Impressão
(Em papel off-set 90g., após paginação eletrônica, em tipo Times, c. 11/13)
Divisão Gráfica da Editora Revan

CIP-Brasil. Catalogação-na-fonte
Sindicato Nacional dos Editores de Livros, RJ.

B337a

Batista, Nilo
Apontamentos para uma história da legislação penal
brasileira / Nilo Batista. - 1. ed. - Rio de Janeiro : Revan,
2016.
138 p. : il. ; 21 cm.

Inclui bibliografia
ISBN: 978-85-710-6584-0

1. Criminologia. 2. Direito penal - Brasil - História.
I. Título.

16-38567

CDU: 343.2

12/12/2016

13/12/2016

Nota introdutória

Há cerca de três lustros, Raúl Zaffaroni sugeriu a publicação autônoma deste estudo, encartado em maço de tratado de direito penal. Não lhe acatei a sugestão naquele momento, na firme crença de que esses apontamentos não interessariam a ninguém fora dos círculos acadêmicos jurídicos.

Para minha surpresa, algumas das mais fecundas interlocuções estabelecidas com meus apontamentos provieram de outras áreas, especialmente da história e das ciências sociais. Sendo assim, não se justificava mantê-los agarrados a uma extensa teoria geral do direito penal nem continuar a extrair dezenas de cópias reprográficas.

Aí vão eles, pois, esperando sejam úteis a todos aqueles interessados na historiografia das leis e dos sistemas penais brasileiros.

Ipanema, novembro de 2016

ε Nilo Batista

Índice

I. A criminalização primária no modelo colonial-mercantilista	11
II. O Código Criminal de 1830	31
III. O Código Penal de 1890	59
IV. O Código Penal de 1940	89
V. A reforma da Parte Geral de 1984	129

Para José Paulo Netto

I

**A criminalização primária no
modelo colonial-mercantilista**

1. É ilusório atribuir à programação criminalizante, na conjuntura colonial brasileira seiscentista, funções similares às que desempenhará em momentos posteriores. Os usos punitivos do mercantilismo, concentrados no corpo do suspeito ou condenado – na reinvenção mercantil do degredo¹, nas galés, nos açoites,

¹ Rusche, G. e Kirchheimer, O., *Punição e Estrutura Social*, trad. G. Neder, Rio, 1999, ed. F. Bastos, pp. 33 ss. A história da legislação portuguesa confirma não apenas Zaffaroni, quando vê na colônia uma macro-instituição de seqüestro (Em Busca das Penas Perdidas, trad. V.R. Pedrosa e A.L. Conceição, Rio, 1991, ed. Revan, pp. 74 ss), e antes dele Euclides da Cunha, que via o Brasil inaugurado como "vasto presídio" (Os Sertões, p. 84), mas também Rusche e Kirchheimer, quando insistem nos fundamentos econômicos da alternância entre degredo e galés. Dois degredados já foram deixados por Cabral, como Pero Vaz de Caminha registrou. Numa fonte italiana, Capistrano de Abreu descobriu o projeto de enviar uma frota ao Brasil, em 1533, de três caravelas contendo cada uma uns dez ou doze condenados à morte, para não expor a perigo homens de bem (Capítulos de História Colonial, Brasília, 1982, ed. UnB, p. 65). Alvará régio de 31.mai.1535 determinava que "o degredo para S. Thomé se mude para o Brasil". Um ano depois, novo alvará (6.mai.1536) ordena que "os moços vadios de Lisboa, que andam na ribeira a furtar bolsas e fazer outros delitos", na segunda prisão fossem degredados para o Brasil. Dois meses antes, uma carta concedia couto e homizio a todos os condenados (salvo por heresia, traição, sodomia e moeda falsa) que viessem povoar a capitania de Pero de Góes (cf. Inácio, Inês C. e Luca, Tânia R., Documentos do Brasil Colonial, S. Paulo, 1993, ed. Ática, p. 48). Deles se queixaria um donatário: "nenhum fruto fazem na terra mas muito mal e dano" (cf. Romero Magalhães, Joaquim, in Mattoso, José (org.) História de Portugal, Lisboa, 1993, ed. Estampa, v. 3º, p. 577). Um alvará de 28.jul.1541 estabeleceu que os mestres e pilotos aos quais eram entregues os degredados deveriam trazer certidões sobre como ficaram eles servindo, e dois outros, de outubro de 1542, provêm sobre degredo dos presos da Misericórdia. Nova provisão, de 5.out.1549, manda que não se degrede para a ilha do Príncipe, e sim para o Brasil. Os condenados pelo Arcebispo de Lisboa a degredo deveriam ser levados à cadeia daquela capital para serem encaminhados (alv. 16.jan.1554). Em 1564, num quadro de fortalecimento da burocracia judicial, durante a regência do cardeal D. Henrique, um assento da Casa da Suplicação permitiu a comutação do degredo para o Brasil em galés (8.abr). Outro assento, de 17.mai.1607, direcionava para o Brasil degredados não cumpridos na África. Decreto de 23.set.1650 declara que o Estado do Maranhão deve reputar-se Brasil para fins de "irem para ali degredados que o possam povoar". Novo decreto, de 13.dez.1685, deslocará degredados da África para Maranhão e

nas mutilações e na morte – encontram-se, na colônia, praticados principalmente no âmbito privado². Além de constituir uma tradição ibérica, essa *continuidade público-privado*³ se beneficiava, em primeiro lugar, da incipiente e lenta implantação das burocracias estatais no Brasil colonial (ainda assim, atreladas aos ciclos produtivos e à tutela do monopólio); em segundo lugar, do escravismo, inexoravelmente⁴ acompanhado de um direito penal doméstico; e, em terceiro lugar, do emprego de resquícios organizativos feudais ao início do esforço de ocupação (capitanias hereditárias): na reminiscência feudal sobrevive a superposição entre o eixo jurídico privado (*dominium*) e o público (*imperium*). Compreende-se assim a opinião de Bezerra Câmara, para quem a legislação portuguesa era “inaplicável às questões emergentes”,

Brasil. Finalmente, em 1722, é proibido o degredo para o Brasil (28.mar). Cabe observar que as mulheres, cujo degredo brasileiro fora autorizado por assento de 30.ago.1614, tiveram seu destino trocado para Cabo Verde e S. Tomé por carta régia de 20.out.1620. É curioso que em 1732 uma lei proibisse que mulheres fossem do Brasil para Portugal, mesmo destinando-se a ordens religiosas, sem licença real (cf. Lopes Pereira, Manoel, *Prática Criminal*, Porto, 1767, ed. A.A.R. Guimarães, p. 556).

² Gizlene Neder frisa que, no mercantilismo, o controle social penal “era realizado dentro da unidade de produção” (*Humanismo Jurídico-penal Luso-brasileiro – Obediência e Submissão*, Rio, 2000, ed. F. Bastos, p. 182).

³ Batista, Nilo, *Matrizes Ibéricas do Sistema Penal Brasileiro*, Rio, 2000, ed. F. Bastos, pp. 126 ss. Graça Salgado assinala que a forma de organização sócio-econômica colonial refratou a legislação da metrópole, modelando “um padrão especial de poder, onde o público e o privado se mesclaram” (*Fiscais e Meirinhos*, Rio, 1985, ed. N. Fronteira, p. 48).

⁴ Como observou Marx, “a única base natural da riqueza colonial é a escravatura” (*O Capital*, trad. R. Sant’Anna, Rio, 1980, ed. Civ. Bras., livro 1º, v. II, p. 887).

⁵ Antonio Carlos Wolkmer vê no regime das capitanias hereditárias “uma prática político-administrativa tipicamente feudal” (*História do Direito no Brasil*, Rio, 1998, ed. Forense, p. 47); Vicente da Costa Santos Tapajós assinala “semelhanças com o feudalismo” (*A Política Administrativa de D. João III*, 2º vol. da *História Administrativa do Brasil*, Brasília, 1983, ed. UnB, p. 29).

uma vez que “cada lugar-tenente, cada potentado punha e dispunha como bem entendia”⁶.

2. O primeiro conflito “criminal” relatado em terras brasileiras passou-se em 25 de agosto de 1501, numa praia situada na atual Natal (RN), quando umas mulheres índias abateram, assaram e comeram um tripulante da primeira viagem portuguesa de Américo Vespúcio. Não houve represália, e eis como Vespúcio o narrou: “Mais de quarenta dos nossos tinham intenção de desembarcar e vingar uma tão cruel morte e um ato bestial e desumano, mas o capitão-mor não quis permitir”⁷. Cabe registrar que a extração do *pau-brasil*, a primeira atividade econômica exercida no processo de colonização, resultará, já na segunda metade do século XVI, na exportação que Portugal fará à Holanda da madeira corante, empregada naquela que é considerada, ao lado das “workhouses” inglesas, uma das instituições precursoras da prisão moderna, a “*Rasp-huis*” de Amsterdam⁸.

3. As Ordenações Afonsinas⁹, em cuja vigência (1447-1521) se deu a descoberta do Brasil, não tiveram qualquer influência na nova colônia. Trata-se de uma compilação de regimentos, concordatas e leis régias anteriores (só o primeiro dos cinco livros – divisão talvez inspirada nas Decretais de Gregório IX – ostentava dispositivos novos), que naquela ocasião disputavam autoridade

⁶ Subsídios para a História do Direito Pátrio, Rio, 1973, ed. Brasileira, t. I, p. 159. Referindo-se às Ordenações Afonsinas e Manuelinas, Fragozo anotava ter sido “muito duvidosa sua aplicação” na colônia (Lições, P. G., cit., p. 59).

⁷ Cf. Fontana, Riccardo, O Brasil de Américo Vespúcio, trad. E.A. Cunha e J.P. Mendes, Brasília, 1994, ed. UnB, p. 174; ressaltamos, em itálico, palavras que atravessariam ilesas o meio milênio que delas nos separaram.

⁸ Para a *Rasp-huis*, cf. Melossi, D. e Pavarini, M., *Cárcel y Fábrica – los Orígenes del Sistema Penitenciario*, trad. X. Massimó, México, 1980, ed. Sig. XXI, pp. 35 ss; para a participação nela do pau-brasil, cf. Hulsman, Lodewijk, Het Rasphuis – A prisão do pau-brasil, in *Continente Multicultural*, pp. 34ss.

⁹ Ordenações Afonsinas, Lisboa, 1984, ed. F.C. Gulbenkian, 5 vols. Trata-se de reprodução *fac-simile* da primeira impressão do texto, realizada em 1792 pela Universidade de Coimbra.

de e competência com o direito canônico, com o direito romano (cujas regras são ali denominadas "leis imperiais") e com os direitos locais, aqueles forais outorgados a distritos ou concelhos por senhores ou pelo próprio rei, cuja intangibilidade se reduzia desde a crise do feudalismo no século XIV. A matéria criminal se compendia, ainda que não exclusivamente¹⁰, no livro V; além da influência canônica (o título I trata dos hereges, e diversos títulos criminalizam a sexualidade segundo padrões canônicos) e romana (nas "forças novas demandadas antes do ano e dia" do título LXVIII ressoa o *interdictum unde vi*), estão presentes traços germânicos (como os gritos nas ruas que habilitavam a mulher forçada a querelar, no título VI), provenientes do processo histórico inaugurado com o reino visigótico. A cominação abusiva da pena de morte e das penas corporais, o emprego por arbítrio judicial da tortura (V, LXXXVII, 4), a ampla criminalização de crenças, opiniões e opções sexuais e a própria transmissibilidade das penas respondem à conjuntura na qual se inscreve tal compilação. A reforma das Ordenações Afonsinas, iniciada em 1505, culmina com a impressão, em 1521, no reinado de D. Manuel, das Ordenações portanto Manuelinas¹¹, que se limitam a recolher e incluir novas leis e a pequenas alterações topológicas na disposição dos textos¹². Nas delegações de jurisdição penal que os soberanos portugueses fizeram, especialmente na primeira metade do século XVI, a autoridades colonizadoras, segundo um modelo

¹⁰ Por exemplo, o artigo — resultante das cortes de Évora — no qual se determina que os vadios, que "não hão mister algum, nem vivem com senhores, e é de presumir-se que vivem de mal fazer" sejam encarcerados até que obtenham ocupação, e se retornarem ao ócio "que os açoitem publicamente" (Livro IV, tit. XXXIII).

¹¹ Ordenações Manuelinas, Lisboa, 1984, F.C. Gulbenkian, 5 vols. Trata-se também de reprodução *fac-simile* da edição universitária conimbrense de 1797.

¹² Referindo-se às Manuelinas, Coelho da Rocha dizia que "a divisão da obra, o sistema, o espírito e princípios gerais da legislação são os mesmos" (das Afonsinas); "unicamente lhes inseriram as novas providências, e alterações, que no intervalo entre uma e outra compilação haviam sido publicadas" (Ensaio sobre a História do Governo e da Legislação de Portugal, Coimbra, 1843, ed. Un. Coimbra, p. 131).

com evidentes traços feudais, estavam sem dúvida presentes as estruturas burocráticas desenhadas nas Ordenações (ouvidores, tabeliães, meirinhos etc), porém na prática o poder punitivo era exercido desregulada e privadamente.

4. Pela *Carta de Grandes Poderes* que D. João III outorgou a Martim Afonso de Souza, em 1530, atribuindo-lhe "todo poder e alçada, mero e misto império, assim no civil como no crime", podia ele aplicar penas "conforme a direito e minhas ordenações até morte natural inclusive, sem de suas sentenças dar apelação nem agravo", salvo quanto a fidalgos, os quais "prenderá e mos enviará presos com os autos de sua culpa". Paralelamente, Martim Afonso de Souza recebia poderes para desde logo "criar e fazer dois tabeliães", sem embargo de outros que se fizessem necessários para prover "os officios da justiça e governança da terra". A Duarte Coelho, capitão-donatário do futuro Pernambuco, conferiu o mesmo monarca, em 1534, a "jurisdição civil e crime da dita terra", facultando-lhe nomear um ouvidor que a exerceria diretamente num raio de "dez léguas donde estiver" e como instância recursal em toda a capitania (o texto menciona "juizes" que, quando viessem a existir, seriam por certo os juizes ordinários, eleitos anualmente pelos "homens bons" dos conselhos municipais, e confirmados, no caso, pelo donatário); a alçada criminal abrangia a pena de "morte natural inclusive em escravos, gentios e peões homens livres", sem apelação nem agravo, salvo quanto às "pessoas de mór qualidade", quando se restringiria a degredo por dez anos e multa até cem cruzados. Contudo, nos *crimina atrociora* da época (heresia, traição, sodomia e moeda falsa) tal restrição não se aplicava. O donatário providenciaria "meirinho dante o dito seu ouvidor e escrivães e outros quaisquer officios necessários e acostumados nestes Reinos"¹³. Consta-se, pois, que até a expedição pioneira de Martim Afonso de Souza,

¹³ Para a Carta de Grandes Poderes e a Carta Donatária, cf. Ribeiro, Darcy e Moreira Neto, C.A., *A Fundação do Brasil*, Petrópolis, 1992, ed. Vozes, pp. 136 ss; para os juizes ordinários, Coelho da Rocha, *op. cit.*, p. 122.

nenhum provimento legislativo aplicável a conflitos criminalizados porventura ocorrentes na colônia foi expedido, o que levou César Tripoli a afirmar que "até 1531 (...) não houve leis no Brasil"¹⁴. Regiam então, já havia uma década, as Manuelinas, razão pela qual constitui um equívoco a recorrente afirmação de que as Ordenações Afonsinas foram as primeiras leis vigentes no Brasil colonial. A predominância de um poder punitivo doméstico, exercido desregulamentadamente por senhores contra seus escravos, é facilmente demonstrável, e constituirá remarcável vineta nas práticas penais brasileiras, que sobreviverá à própria abolição da escravatura. Em 1591, um senhor confessa ao visitador do santo ofício na Bahia ter ordenado que uma negra fosse lançada na fomalha do engenho¹⁵. Em 1700, o jesuíta Jorge Benci publicou na Bahia um livro no qual, omitindo "outros castigos ainda mais inumanos que os ciúmes do senhor ou da senhora fazem executar nos escravos", indagava se seria "castigo razoável queimar ou atazanar com lacre aos servos; cortar-lhes as orelhas ou os narizes; marcá-los nos peitos e ainda na cara; abrasar-lhes os beíços e a boca com fições ardentes"¹⁶. A obra de outro jesuíta, André João Antonil, de 1711, exprobatava aos senhores "castigar com ímpeto, com ânimo vingativo, por mão

¹⁴ História do Direito Brasileiro, S. Paulo, 1936, ed. RT, v. I, p. 79. No mesmo sentido Pierangeli, José Henrique, Códigos Penais do Brasil, S. Paulo, 2001, ed. RT, p. 61.

¹⁵ Vainfas, Ronaldo (org.), Confissões da Bahia, S. Paulo, 1997, ed. Cia. das Letras, p. 65. Importa ressaltar que tal fato não desperta qualquer reação no visitador, interessado apenas num culto sertanejo herético.

¹⁶ Economia Cristã dos Senhores no Governo dos Escravos, S. Paulo, 1977, ed. Grimalho, p. 156. Mencionando que "por pouco mais de nada chegaram alguns (senhores) a lançar vivos nas fomalhas os seus escravos" (p. 159), Benci argumentava que o senhor que "queira que lhe dê" (ao escravo) a pena de morte deve entregá-lo à Justiça, para que conhecendo da causa o castigue conforme o merecimento de suas culpas" (p. 166). O divórcio entre práticas penais e textos de lei avulta ao constatar-se que uma determinação régia de 27.fev.1523 revogara parcialmente o título XXXVII do livro V das Ordenações Manuelinas, precisamente na parte que impunha aos ladrões de baixa extração social a pena de serem "ferrados no rosto com um ferro que tenha uma força".

própria e com instrumentos terríveis e chegar talvez aos pobres (escravos) com fogo ou lacre ardente, ou marcá-los na cara"¹⁷. Quando Gilberto Freyre estudou os anúncios sobre escravos na imprensa brasileira do século XIX, a permanência dessas práticas se revelavam em "cicatrizes de açoites e de ferro quente", em "dentes limados", em feridas provenientes de "anjinho", de tronco, de corrente no pescoço, de ferro nos pés, de lubambo no tornozelo" ou ainda "queimaduras na barriga"¹⁸. A situação jurídica dos índios¹⁹, conquanto muito mais regulamentada²⁰ e de certa forma pendular, no que pertine à necessidade do braço escravo, à dos negros, não os afasta de intervenções punitivas segundo os mesmos padrões. O caso do índio aldeado que em 1552 morreu quando era submetido a açoites, relatado por Serafim Leite em sua História da Companhia de Jesus no Brasil,

¹⁷ Cultura e Opulência do Brasil, B. Horizonte, 1982, ed. Itatiaia, p. 92.

¹⁸ O Escravo nos Anúncios de Jornais Brasileiros do Século XIX, S. Paulo, 1979, ed. Nacional, pp. 121 ss. Da ampla bibliografia sobre os castigos dos escravos, cf. Ramos, Arthur, Castigos de Escravos, in Rev. Arq. Mun. S. Paulo, v. 47, pp. 79 ss.; Figueiredo, Ariosvaldo, O Negro e a Violência do Branco, Rio, 1977, ed. J. Alvaro; Goulart, José Alípio, Da Palmatória ao Patíbulo, Rio, 1971, ed. Conquista.

¹⁹ Refoge a nosso objeto o interessante tema dos costumes penais dos próprios índios, menosprezado pela literatura jurídica brasileira: cf. Bevilacqua, Clovis, Instituições e Costumes Jurídicos dos Índigenas Brasileiros ao Tempo da Conquista, em Criminologia e Direito, Bahia, 1896, ed. Liv. Magalhães, pp. 221 ss.; Bernardino Gonzaga, João, O Direito Penal Índigena à Época do Descobrimento do Brasil, S. Paulo, s.d., ed. M. Limonad; Batista, Nilo, Práticas Penais no Direito Índigena, em RDP 31, pp. 75 ss.

²⁰ Deve-se a Beatriz Perrone-Moisés um valioso inventário da legislação indigenista entre 1500 e 1800, publicado em Carneiro da Cunha, Manuela (org.) História dos Índios no Brasil, S. Paulo, 1992, ed. Cia. das Letras, pp. 529 ss. Caberia acrescentar algumas leis que se referem aos índios brasileiros recolhidas na *Recopilación de las Leyes de los Reynos de las Indias*, de Carlos II (1681), outorgando liberdade a índios do Brasil (1556) ou do Maranhão despachados como escravos (1629), e determinando "que se procure castigar a los que de la Villa de San Pablo del Brasil van a cautivar indios del Paraguay" (L. VI, T. II, leis 4, 5 e 6; na publicação *fac-simile* de Madri, 1973, ed. Cult. Hispanica, t. II, p. 195). Para o século XIX, cf. Carneiro da Cunha, Manuela (org.) Legislação Indigenista do Século XIX, S. Paulo, 1992, ed. Edusp.

dado pela historiografia como excepcional²¹, é ao contrário muito sugestivo quanto às práticas punitivas reservadas aos membros de nações indígenas que resistissem ao empreendimento colonizador, para o qual, como observou Caio Prado Júnior, a "caça ao índio" foi elemento fundamental na expansão das fronteiras²². A partir do critério estabelecido por Perrone-Moisés, torna-se compreensível o emaranhado aparentemente contraditório da legislação indigenista, essencialmente dividido em leis *sobre* os "índios amigos" e leis *contra* o "gentio bravo"²³: se para os primeiros poderemos encontrar, já nas missões setentrionais do século XVII, uma atenuação dos castigos radicada no olhar medicinal-evangelizador, que em certas aldeias extrairia as normas penais do Livro de Ordens²⁴, para os segundos, numa linha que já estava explicitamente formulada no Regimento de Tomé de Souza²⁵, a mais brutal escravização²⁶ constitui o primeiro expediente jurídico do inexorável processo histórico de seu genocídio.

²¹ Cf. Assis Ribeiro, C.J., *História do Direito Penal Brasileiro*, Rio, ed. Z. Valverde, v. I, p. 111.

²² *História Econômica do Brasil*, S. Paulo, 1973, ed. Brasiliense, p. 36; sobre o aspecto, cf. Max Justo Guedes, *As Bandeiras Ignoram o Tratado de Tordesilhas e Ampliam o Espaço Geográfico Brasileiro*, em *Nação e Defesa*, 70, pp. 3 ss.

²³ *Índios Livres e Índios Escravos – os princípios da legislação indigenista do período colonial*, em Carneiro da Cunha, M., *História dos Índios no Brasil*, cit., pp. 115 ss.

²⁴ Do Livro de Ordens, que proibia a vingança privada e limitava o número de açoites, tratou Kern, Arno Alvarez, *Missões – Uma Utopia Política*, P. Alegre, 1982, ed. Mercado Aberto; coube a Antônio Carlos Wolkmer incorporar tal pesquisa à historiografia jurídica brasileira (*História do Direito no Brasil*, cit., p. 54). Cf. ainda Ruschel, Ruy Ruben, *Sistema Jurídico dos Povos Missionários*, em Wolkmer, A.C. (org.), *Direito e Justiça na América Indígena*, P. Alegre, 1998, ed. Liv. Adv., pp. 183 ss.

²⁵ Do regimento de Tomé de Souza, primeiro governador-geral do Brasil (1549), constam poderes para que respondesse às hostilidades de algumas nações indígenas "destruindo-lhes suas aldeias e povoações e matando e cativando aquela parte deles que vos parecer que basta para o seu castigo" (cf. Ribeiro, Darcy e Moreira Neto, C.A., *A Fundação do Brasil*, cit., p. 137).

²⁶ Aos capitães-donatários, um quarto de século antes do primeiro governador-geral, era já facultada a escravização de índios e a venda de certo núme-

5. Um modelo jurisdicional feudal, tal como o das capitânias hereditárias²⁷, estava por certo na contramão do processo histórico de constituição dos estados nacionais, ao qual corresponde um represamento centralizado de poder punitivo. Se o governo geral, de 1549, já representava, como disse Capistrano de Abreu, um "novo regime"²⁸, mesmo antes dele uma provisão régia, de 1538, revogava aquela competência das dez léguas dos ouvidores dos donatários, e em 1557 não só tornava-se obrigatória a apelação de condenações a morte de pobres ("peões cristãos homens livres") como afirmava o rei que "havia por bem de mandar a elas (às capitânias) corregedor e alçada quando lhe parecesse necessário e cumprisse a seu serviço, sem embargo das ditas cláusulas das ditas doações". Não foi o promotor de justiça, já previsto nas *Manuelinas*²⁹, o grande agente político dessa acumulação de poder punitivo, senão o juiz de fora, de nomeação real, sobrepondo-se ao juiz ordinário eletivo; seu sucessor no reino recomendou sua utilização no Brasil, a partir do final do século XVII³⁰. O fato é que, mesmo culminando no século XVIII, com a compra das escassas capitânias ainda subsistentes na década de 1760, ou com o fim dos coutos (então restritos a formas quase assimiláveis ao asilo eclesiástico) em 1790, um processo de centralização de poder – sobre o qual já depunha a reforma manuelina dos forais,

ro deles em Lisboa. Sobre os estratagemas usados na empreitada de cativar índios, cf. Albuquerque, Manoel Maurício de, *Pequena História da Formação Social Brasileira*, Rio, 1981, ed. Graal, pp. 29 ss. Sobre a legislação da escravização dos índios, cf. Perdigão Malheiro, *A Escravidão no Brasil*, Petrópolis, 1976, ed. Vozes, v. I, pp. 149 ss.

²⁷ Na carta donatária de Duarte Coelho, determinava D. João III que "nas terras da dita capitania não entrem nem possam entrar em tempo algum corregedor nem alçada nem outras algumas justiças para nelas usar de jurisdição alguma por nenhuma via nem modo que seja".

²⁸ *Op. cit.*, p. 74. Frei Vicente de Salvador assinala a redução nos poderes jurisdicionais dos capitães donatários ocorrida nessa ocasião, com a criação do ouvidor-geral (*História do Brasil*, B. Horizonte, 1982, ed. Itatiaia, p. 143).

²⁹ *Ord. Man.* I, XXXIV.

³⁰ Para Graça Salgado, "a medida significou a mais direta interferência metropolitana na instância judicial menor da colônia" (*op. cit.*, p. 80); para Caio Prado Júnior, "um dos maiores golpes desferidos nas franquias locais" (*op. cit.*, p. 52).

na segunda década do século XVI – estava em curso e deixou as suas marcas.

6. Diversamente das Afonsinas, que não existiram para o Brasil, e das Manuelinas, que não passaram de referência burocrática, casual e distante em face das práticas penais concretas acima noticiadas, as Ordenações Filipinas constituíram o eixo da programação criminalizante de nossa etapa colonial tardia, sem embargo da subsistência paralela do direito penal doméstico que o escravismo necessariamente implica. A vigência das Filipinas, em matéria penal, avançou mesmo alguns anos sobre o próprio estado nacional brasileiro, até a promulgação do código criminal de 1830, com os limites e alterações decorrentes da nova ordem constitucional e de algumas leis penais editadas naquele período; quanto aos assuntos de direito privado, inúmeras disposições suas regeram até 1º de janeiro de 1917, quando entrou em vigor nosso Código Civil. Publicadas em 1603, durante a união ibérica³¹, por Felipe III (II de Portugal), representavam um novo esforço de atualização e consolidação da legislação extravante, iniciado por ordem de Felipe II (I de Portugal) em 1595. Seus autores (Pedro Barbosa, Paulo Afonso, Damião de Aguiar e Jorge de Cabelo) beneficiaram-se de uma coletânea elaborada por Duarte Nunes do Leão em 1569³². A matéria penal concentrava-se no Livro V,

³¹ A aprovação real data de 11 de janeiro de 1603. Terminada a união ibérica, com a aclamação do duque de Bragança em 1º de dezembro de 1640, o agora rei D. João IV, por lei de 29 de janeiro de 1643, conhecida por lei de confirmação, houve “por bem (...) revalidar, confirmar, promulgar, e de novo ordenar e mandar que os ditos cinco livros das Ordenações, e Leis, que neles andam se cumpram, e guardem (...) como se por mim novamente fossem feitas, e ordenadas, promulgadas e estabelecidas”. Por privilégio real, as primeiras edições das Ordenações Filipinas tocaram ao mosteiro de S. Vicente de Fora (o trabalho gráfico da edição *princeps* foi de Pedro Crasbeeck), sendo designadas por edições *vicentinas*; em 1773, um alvará régio pombalino transferiu o encargo para a Universidade de Coimbra; nasciam as edições *coimbrenses*, nas quais estudariam os juristas brasileiros.

³² Leis Extravagantes Collegidas e Relatadas pelo Licenciado Duarte Nunes do Lião, per Mandado do muito Alto & muito Poderoso Rei Dom Sebas-

que reproduzia, com as alterações intercorrentes, a mesma estrutura básica das Afonsinas; pode-se contudo afirmar que a ferocidade dos textos não correspondia uma implacável aplicação judicial massiva, que em todo caso será maior no século XVIII do que nos antecedentes³³. Quando, em 1609, concretizou-se a criação do tribunal da Relação do Estado do Brasil, com sede em Salvador, determinou-se que seu chanceler trouxesse três exemplares das Ordenações Filipinas³⁴. É significativo que a instala-

tiam, nosso Senhor, Lisboa, 1569, ed. A. Gonçalves. As leis penais posteriores às Manuelinas foram recolhidas na Parte IV (dos delitos e acessórios a eles), em 23 títulos.

³³ Num escrito luminoso (A Punição e a Graça) in Mattoso, José – org. – História de Portugal, 1993, ed. Estampa, v. IV, pp. 239 ss. Antonio Manuel Hespanha desvenda “o segredo da específica eficácia do sistema penal do Antigo Regime (...): de ameaçar sem cumprir; de se fazer temer, ameaçando; de se fazer amar, não cumprindo” (p. 244). Trabalhando sobre uma fonte de 1694, uma relação de 454 encarcerados em Lisboa, constatou que a 72% deles poderia (a 38% *deveria*) ser aplicada a pena de morte, enquanto que isto efetivamente ocorreu a 1% (3 homicidas). Hespanha menciona o esforço de alguns juristas para interpretar o sinistro estribilho das Ordenações (“*morra por ello*”, originado, como Mello Freire lembraria, do *moriatur pro eo* da legislação mosaica vertida ao latim) como degredo perpétuo cumulado com perdimento de bens, valendo-se da distinção morte civil – morte natural, opinião que naturalmente não podia prevalecer porquanto uma abolição geral de múltiplas cominações da pena de morte comprometeria aquela política criminal de dupla face. Coube ao brasileiro Alexandre de Gusmão a redação de uma carta régia, a 20 de janeiro de 1745, pela qual D. João V adverte o Corregedor do Crime de Lisboa de que “as leis costumam ser feitas com muito vagar e sossego, e nunca devem ser executadas com aceleração, e nos casos críme sempre ameaçam mais do que na realidade mandam, devendo os executores delas modificá-las em tudo o que lhes for possível, porque o legislador é mais empenhado na conservação dos vassallos do que nos castigos da justiça, e não quer que os ministros procurem achar nas leis mais rigor do que elas impõem”; seu teor confirma a ambigüidade vislumbrada por Hespanha.

³⁴ Regimento de 7 de março de 1609. O tribunal fora criado em 1587, porém não se instalara porquanto apenas três dos desembargadores nomeados lograram chegar à Bahia. Cf. Figueiredo Dias, Jorge, A Relação do Estado do Brasil e o Direito Português, in Forum Int. de Dir. Pen. Comp., Salvador, 1989, ed. TJBA, pp. 27 ss; Graça Salgado, *op. cit.*, pp. 76 ss.

ção do tribunal tenha desagradado à classe senhorial mercantil, que contra ele formulou representações à corte³⁵; dos motivos da insatisfação da oligarquia açucareira certamente participaram receios, fundados ou não, de perda de poder punitivo privado, ainda que o fechamento da Relação, em 1626, costume ser atribuído à economia da guerra contra a invasão holandesa. Três ouvidores-gerais (Estado do Brasil, Repartição do Sul e Estado do Maranhão) subordinados diretamente à Casa da Suplicação centralizaram a administração judicial na colônia até a reabertura da Relação, em 1652; após essa data, apenas a Ouvidoria-geral do Estado do Maranhão, por maiores facilidades de comunicação com a corte que com a Bahia, manteve seu nível jurisdicional. Em 1751, foi criada a Relação do Rio de Janeiro. Muitos juizes de fora já exerciam suas funções na colônia, a essa altura, e a partir de 1765 promoveu-se a instalação de Juntas de Justiça nas cidades onde residissem os remanescentes ouvidores das capitanias. A burocracia necessária à aplicação das Ordenações Filipinas estava agora alojada e aliva, e seus anelos por autonomia perante o poder local encontram explicável ressonância³⁶. As Ordenações Filipinas – sempre ressalvado o sistema penal doméstico senhorial – passam a constituir a referência central, escrita, da programação criminalizante, e desde a metade do século XVII se determinara que “daqui em diante não possam servir de juizes senão pessoas que saibam ler e escrever”³⁷. Uma profusão de normas penais, dispersas por alvarás, regimentos, decretos, cartas-régias e mesmo assentos da Casa da Suplicação³⁸ regiam

³⁵ Graça Saigado, *op. cit.*, p. 78.

³⁶ No regimento de 17 de julho de 1643, da Ouvidoria-geral do Brasil, vedava-se ao Governador Geral intervir nos assuntos forenses; em 1712, carta régia de D. João V reafirmava o mesmo princípio.

³⁷ Alvará de 13 de novembro de 1642.

³⁸ Sobre a prática, de origem manuelina, de equiparar-se a lei certos assentos da Casa da Suplicação, cf. Bezerra Câmara, *Assentos com força de lei*, in *Subsídios*, cit., v. II, pp. 167 ss.

paralelamente ao Livro V das Ordenações Filipinas, cujo texto era menos usualmente alterado por alguma delas³⁹.

7. Em 17 de dezembro de 1531, cedendo a insistentes gestões de D. João III, o papa Clemente VII nomeia inquisidor para Portugal⁴⁰. A iniciativa, concentradora de um poder punitivo que a partir de 1560, com a introdução do confisco de bens, seria altamente rendosa, daria origem a uma nova programação criminalizante que, mesmo se beneficiando de normas recebidas pelo direito régio desde a inquisição medieval, vai se materializar num corpo próprio e multifário, do qual fazem parte, entre outros textos, as instruções de 1541, a nova bula de 1547, o regimento de 1552, um breve do papa Pio V de 1560, o regimento do Conselho Geral de 1570, os repertórios de 1596 e 1634, o novo regimento de 1640 e o último, pombalino, de 1774, já “decadente”, na proscrição do segredo e na crítica à tortura. Essa outra programação criminalizante intervém no Brasil colonial. O primeiro caso envolveu o donatário de Porto Seguro⁴¹. A primeira visitação se deu na Bahia (1591) e Pernambuco (1594); a segunda, em 1618, novamente na Bahia; e a terceira, em 1763, no Pará⁴². Além das visitas, muitas inquirições foram realizadas

³⁹ Tomemos dois exemplos, do mesmo ano, 1756: A lei de 24 de janeiro, que impunha a pena de 1000 açoites, executada em 10 dias, aos escravos que no Brasil fossem achados com faca, permaneceu extravagante; o alvará de 13 de novembro, sobre crimes falimentares (“mercadores que quebram e se levantam com fazenda alheia”) integrou-se parcialmente às Ordenações Filipinas (Livro V, tit. LXVI). Para o texto integral, cf. Lopes Ferreira, Manoel, *Prática Criminal*, cit., p. 609. Um precioso repertório de leis extravagantes, de 1143 a 1805, em apêndice a Pereira e Souza, Joaquim José Caetano, *Primeiras Linhas sobre o Processo Criminal*, Lisboa, 1806, ed. Lacerdina.

⁴⁰ O nomeado, Diogo da Silva, fora indicado pelo rei. Cf. Herculano, Alexandre, *História da Origem e Estabelecimento da Inquisição em Portugal*, Mira-Sintra, s/d, ed. Europa-América, v. I, pp. 124 ss; Bethencourt, Francisco, *História das Inquisições*, S. Paulo, 2000, Cia. das Letras, pp. 44 ss; Novinsky, Anita, *A Inquisição*, S. Paulo, 1986, ed. Brasiliense.

⁴¹ Cf. Britto, Rossana G., *A Saga de Pero do Campo Tourinho*, Petrópolis, 2000, ed. Vozes.

⁴² Vainfas, Ronaldo (org.), *Confissões da Bahia*, S. Paulo, 1997, ed. Cia. das

nesses e em outros lugares, como o Rio de Janeiro, a Paraíba e o Maranhão⁴³. A inquisição também aplicou a pena de degredo para o Brasil⁴⁴. Desse modo, embora não tenha o Brasil colonial – ao contrário do Peru, de Cartagena (Colômbia) e do México – sediado um tribunal da inquisição, os tentáculos do santo ofício manobram intensamente por aqui, e qualquer estudo de nossas práticas processuais penais que aspire a transcender dos textos para as mentalidades não pode ignorar esse legado silente mas profuso. É importante ainda registrar que, em determinado período do século XVII, uma boa porção do território brasileiro, de Sergipe ao Maranhão, observou a programação criminalizante e a organização judiciária holandesas. A conquista batava de Pernambuco representou a concretização da proposta de Grócio em seu *Mare Liberum*⁴⁵ – em pleno choque econômico, geopolítico e religioso com os interesses ibéricos – e traz a hoje inquietante marca de ter sido uma aventura política planejada e gerida por uma sociedade mercantil privada, a Companhia Privilegiada das Índias Ocidentais. Particularmente no período nassoviano (1637-1644) encontramos uma estrutura judicial completamente distinta: escoltetos (com funções policiais e acusatórias públicas), conselhos de escabinos (tribunais municipais, com um máximo

Letras; Amaral Lapa (org.), Livro da Visitação do Santo Ofício da Inquisição ao Estado do Grão-Pará, Petrópolis, 1978, ed. Vozes.

⁴³ Da ampla bibliografia se destacam, exemplificativamente, Novinsky, Anita, Cristãos Novos na Bahia, S. Paulo, 1972, ed. Perspectiva; Ferreira da Silva, Lina G., Heréticos e Impuros, Rio, 1995, col. Biblioteca Carioca; Vainfas, Ronaldo, A Heresia dos Índios, S. Paulo, 1995, ed. Cia. das Letras; Freire Gomes, Plínio, Um Hereje vai ao Paraíso, S. Paulo, 1997, ed. Cia. das Letras; Mello e Souza, Laura, O Diabo e a Terra de Santa Cruz, S. Paulo, 1986, ed. Cia. das Letras. Para o caso de Antônio José da Silva, cf. Dines, Alberto, Vínculos do Fogo, S. Paulo, 1992, ed. Cia. das Letras; para o caso de Vieira, cf. Muhana, Adma (org.), Os Autos do Processo de Vieira na Inquisição, S. Paulo, 1995, ed. Unesp e ainda Vieira, Antônio, De Profecia e Inquisição, Brasília, 1998, ed. Senado Federal.

⁴⁴ Pieroni, Geraldo, Os Excluídos do Reino, Brasília, 2000, ed. UnB.

⁴⁵ A observação é de Joaquim Ribeiro, Administração do Brasil Holandês, in História Administrativa do Brasil, cit., v. 3, p. 323.

de quatro membros, holandeses e portugueses, anualmente escolhidos), o Conselho Público (que o regulamento de 23.ago.636 converteu em tribunal de apelações inteferpostas das decisões dos escabinos) e o Alto Conselho, presidido pelo próprio governador. Nassau teria interferido sobre o poder punitivo doméstico, reivindicando a exclusiva aplicação das penas de marca a ferro, mutilações e morte nos escravos, preservadas para os senhores e chicote, o tronco e as correntes no pescoço e nas pernas⁴⁶.

8. Na segunda metade do século XVIII instala-se o conflito entre o capitalismo mercantil de Estado e o nascente capitalismo industrial, cujos interesses se opõem aos monopólios – que na legislação penal são ardentemente protegidos pelo contrabando⁴⁷ –, ao trabalho escravo e às colônias fechadas para o livre comércio. A ascensão revolucionária da burguesia, especialmente na França, produzirá princípios políticos em tudo opostos ao absolutismo. Inscrevem-se naquele conflito os sucessos europeus que trarão ao Brasil, em 1808, a família real e a administração superior portuguesa, e a abertura dos portos (ainda que decretada em caráter provisório, mas historicamente irreversível) não por acaso constituiu seu primeiro ato, praticado em escala na Bahia, antes mesmo de chegar ao Rio de Janeiro. Com raízes na baixa idade média, porém ajustadas ao capitalismo mercantil monárquico lusitano, as Ordenações Filipinas serão confirmadas pela Assembléia Constituinte do Brasil, já após a independência, “enquanto se não organizar um novo código ou não forem especial-

⁴⁶ Gonsalves de Mello Neto, J.A., Tempo dos Flamengos – Influência da Ocupação Holandesa na Vida e na Cultura do Norte do Brasil, Rio, 1947, ed. J. Olympio, p. 159; Rebello Pinho, Ruy, História do Direito Penal Brasileiro – Período Colonial, S. Paulo, 1973, ed. J. Bushatsky, pp. 109 ss.

⁴⁷ Alvará de 14 de novembro de 1757 dizia do delito de contrabando ser “hum dos mais perniciosos entre os que infectam os estados, e dos que se fazem na sociedade civil mais odiosos; porque, tendo a vileza do furto, não só é cometido contra o erário régio, e contra o público do Reino, onde é perpetrado, mas também quando grava em geral prejuizo do comércio, é a ruína do mesmo comércio”.

mente alteradas"⁴⁸, e passam a conviver com as primeiras leis penais genuinamente brasileiras. Neste período, observa-se por vezes uma correspondência entre provisões adotadas na metrópole e na nova sede da corte, ou mesmo na nova nação. Se em 1756 D. José, sabedor de que "no estado do Brasil continuavam os mulatos e pretos escravos a usar de facas e mais armas proibidas", impõe-lhes a pena de cem açoites por dez dias alternados, um edital de polícia, no Rio de 1816, cominava para a mesma infração a pena de trezentos açoites mais três meses de trabalho em obras públicas⁴⁹. Analogamente, se em 1821 as Cortes Gerais Extraordinárias e Constitucionais da Nação Portuguesa extinguíram as devassas gerais sobre delitos incertos – um legado da *inquisitio generalis*, que se revelara tão útil ao antigo regime –, em 1828 uma decisão de governo (nº 148, de 6.out.1828) também as proibiu por aqui⁵⁰. As razões de algumas leis penais deste período são facilmente identificáveis. Conhecido o fato de que lojas maçônicas discutiam e veiculavam idéias liberais⁵¹, explica-se o alvará de D. João VI, de 30 de março de 1818, proibindo as sociedades secretas e tornando inafiançável o delito de delas participar (da mesma forma se negaria fiança a salteadores mediante a decisão de governo nº 58, de 26.fev.1824); por lei de 20 de ou-

⁴⁸ Decreto de 27.set.1823, sancionado e publicado em 20.out.1823, art. 1º.

⁴⁹ Cf. Lopes Ferreira, Manoel, *Prática Criminal*, cit., p. 607; Holloway, Thomas H., *Polícia no Rio de Janeiro*, trad. F.C. Azevedo, Rio, 1997, ed. F. Getúlio Vargas, p. 55.

⁵⁰ Cf. Romeiro, Jorge Alberto, *Da Ação Penal*, Rio, 1949, ed. Forense, p. 73; Pierangeli, José Henrique, *Processo Penal – Evolução Histórica e Fontes Legislativas*, Bauru, 1983, ed. Jalevi, p. 93. A proibição de devassas gerais sobre delitos incertos tem sido frequentemente violada por certas Comissões Parlamentares de Inquérito, nos dias que correm.

⁵¹ Emília Viotti da Costa, *Introdução ao Estudo da Emancipação Política do Brasil*, em *Brasil em Perspectiva*, cit., p. 88. O fato de que "alguns indivíduos (...) falavam nos negócios públicos da Europa, louvando e aprovando o sistema da rebelião da nação francesa e dando por este modo a conhecer o veneno de que seus ânimos se achavam contaminados" motivara o Conde de Resende, em 1794, a determinar uma devassa no Rio (Autos da Devassa – A Prisão dos Letrados no Rio de Janeiro, Rio, 1994, ed. Arq. Pub. RJ, p. 37).

tubro de 1823, a Assembléia Constituinte revogou o alvará joanino. O intenso debate político através da recém-nascida imprensa brasileira responde pelo contraditório conjunto dos atos legislativos que disciplinaram a matéria⁵². Editam-se paralelamente leis penais gerais, sobre prisão (dec. de 23.mai.1821), processo (dec. de 17.abr.1824, leis de 23.set.1828 e 22.set.1829), graça (decs. de 6.fev.1818, 20.mar.1821, 23.mar.1822 e, já na nova ordem constitucional, lei de 11.set.1826). Merece menção especial a portaria de 10 de abril de 1822, pela qual José Bonifácio criou dois cargos de ajudantes de Intendente Geral de Polícia "com a atribuição explícita de vigiar as pessoas, cercar casas e clubes políticos e prender os suspeitos"⁵³. Por lei de 11 de agosto de 1827, Pedro I criou "dois cursos de ciências jurídicas e sociais, um na cidade de São Paulo e outro na de Olinda"⁵⁴. O Supremo Tribunal de Justiça, previsto na Constituição de 1824, foi organizado por lei de 16 de setembro de 1828, instalando-se em 9 de janeiro de 1829. As garantias individuais previstas nos incisos do artigo 179 da Constituição de 1824 – entre as quais a liberdade de manifestação do pensamento, a proscrição de perseguições religiosas, a liberdade de locomoção, a inviolabilidade do domicílio e da correspondência, as formalidades exigidas para a prisão, a reserva legal, o devido processo, a abolição de penas cruéis e da tortura, a intransmissibilidade das penas, o direito de petição, a abolição de

⁵² Entre outros, decretos de 2.mar.1821, de 18.jul.1822 e de 22.nov.1823; decisão nº 160, de 21.jul.1825; decreto de 12.set.1828; leis de 30.ago.1829 e 20.set.1830. Para os debates, cf. Nelson Werneck Sodré, *A História da Imprensa no Brasil*, Rio, 1966, ed. Liv. Brasl, pp. 50 ss.; Isabel Lustosa, *Insultos Impressos*, S. Paulo, 2000, ed. Cia. das Letras.

⁵³ Hamilton de Mattos Monteiro, *Da Independência à Vitória da Ordem*, em Maria Yedda Linhares (org.) *História Geral do Brasil*, cit., p. 118.

⁵⁴ Alberto Venâncio Filho, *Das Arcadas ao Bacharelismo*, S. Paulo, s/d, ed. Perspectiva; Sérgio Adorno, *Os Aprendizes do Poder*, Rio, 1988, ed. Paz e Terra; Aurélio Wander Bastos, *O Ensino Jurídico no Brasil*, Rio, 1998, ed. Lumen Juris; para os debates parlamentares a respeito, e para a íntegra dos Estatutos do Visconde de Cachoeira, cf. *Criação dos Cursos Jurídicos no Brasil*, Brasília, 1977, ed. F. Casa de Rui Barbosa.

privilégios e foro privilegiado⁵⁵ – colidem abertamente com inúmeras disposições das Ordenações Filipinas, em delicada sobrevida nesta conjuntura. Um desses incisos recomendava “quanto antes” a organização de “um código civil, e criminal, fundado nas sólidas bases da Justiça e Equidade” (inc. XVIII).

II

O Código Criminal de 1830

⁵⁵ Estas últimas cláusulas levaram a diplomacia brasileira, em 1825, a argumentar com a impossibilidade de manter-se o Juiz Conservador da Nação Inglesa, criado através do Tratado de Comércio e Navegação, de 19 de fevereiro de 1810, que além de garantir à Inglaterra alíquotas *ad valorem* inferiores à do próprio Portugal, também implicava tolerância religiosa e o compromisso de não ser aqui introduzida a inquisição. Cf. Delgado de Carvalho, Carlos, *História Diplomática do Brasil*, Brasília, 1998, ed. Sen. Federal, pp. 16; Buarque de Holanda, Sérgio (org.), *História Geral da Civilização Brasileira*, S. Paulo, 1976, ed. Difel, t. II, v. 1^o, p. 355; Manoel Maurício de Albuquerque, *Pequena História*, cit., p. 257. Aviso do ministro da Justiça, de 22.nov.1832 (então, Honório Hermeto Carneiro Leão), levando em conta a publicação do Código de Processo Criminal, extinguiria todos os juizes especiais, e entre eles, expressamente, o Juiz Conservador da Nação Inglesa (cf. João Mendes, *op. cit.*, v. I, p. 166).

1. A compreensão da programação/criminalizante que teve seu núcleo no Código Criminal do Império do Brasil, de 1830, bem como do sistema penal montado a partir dela, pode ser facilitada pela análise de dois grandes eixos, no primeiro dos quais encontramos a *contradição entre o liberalismo e a escravidão*, e no segundo o movimento político de *descentralização e centralização*, que se valeu intensamente do processo penal. Quando se assenta a poeira dos tensos episódios que assinalam a independência, ascende ao poder do novo estado "a classe mais diretamente interessada na conservação do regime: os proprietários rurais, que se tornam sob o império a força política e socialmente dominadora"⁵⁶. Paralelamente à decadência do nordeste, a cultura do café no sudeste faz este produto ultrapassar o açúcar e o algodão nas exportações⁵⁷ e concentra geograficamente riqueza e poder político, prorrogando a demanda de mão de obra escrava. A queda nos preços internacionais do açúcar e do algodão e a crise financeira agravada pelo *deficit* fiscal – tratado com volumosas emissões de papel-moeda⁵⁸ – produzem insatisfações que se materializarão em inúmeras sedições: a partir de 1831 os *cabanos* no Pará, a *setembrada* de 1832 em Pernambuco, a revolução *farroupilha* de 1835 no sul (mesmo ano de uma revolta de escravos na Bahia, sobre a qual retornaremos), a *sabinada* também na Bahia em 1837, a *balaçada* no Maranhão em 1839, a revolução *praieira* em Pernambuco em 1848, São Paulo e Minas Gerais em 1842, Alagoas em 1844... A Constituição de 1824 mantivera a escravidão, sob a fórmula circunloquial de garantir "o direito de propriedade *em toda a sua plenitude*" (art. 179, inc. XXII). A contradição entre a condição escrava e o discurso liberal era irredutível: como disse Emília Vioti da Costa, "a es-

⁵⁶ Caio Prado Júnior, *op. cit.*, p. 143.

⁵⁷ Mattos Monteiro, Hamilton, Da independência à vitória da ordem, em Linhares, Maria Yedda (org.) História Geral, cit., p. 125.

⁵⁸ Sobre a crise deste período, cf. Furtado, Celso, Formação Econômica do Brasil, Rio, 1964, ed. F. de Cultura, pp. 118 ss. e Faoro, Raymundo, Os Donos do Poder, P. Alegre, 1979, ed. Globo, v. I, pp. 324 ss.

cravidão constituía o limite do liberalismo no Brasil", frisando Roberto Schwarcz que "as idéias liberais não se podiam praticar, sendo ao mesmo tempo indescartáveis"⁵⁹. De outro lado, o tratamento dos conflitos aguçados pela crise fará o projeto liberal de Estado rethuir para um projeto policial, num movimento de centralização política que explicitamente se veiculará através do poder punitivo, notadamente do processo penal.

2. Se fosse possível abstrair a condição jurídica dos escravos⁶⁰, outra contradição se estabeleceria, no âmbito penal, entre as remanescentes Ordenações Filipinas⁶¹ e as promessas da nova ordem constitucional. Tomemos, exemplificadamente, três delas: o princípio da reserva legal, a proscrição de açoites e "mais penas cruéis", e a proibição de responsabilidade penal por fato alheio, todas reconhecidas pela Constituição de 1824 (art. 179, incs. XI, XIX e XX). Sabemos que "no antigo regime, o intendente de polícia e várias outras autoridades judiciais e administrativas podiam declarar uma atividade ilegal, bastando para tanto baixar uma norma" que frequentemente cominava uma pena⁶². Sabemos

⁵⁹ Viotti da Costa, E., Introdução ao estudo, cit., p. 92; Schwarcz, R., As idéias fora do lugar, p. 22.

⁶⁰ Sobre o tema, entre outros, Perdigão Malheiro, A Escravidão no Brasil, Petrópolis, 1976, ed. Vozes, 2 vols; Spiller Pena, Eduardo, Pajens da Casa Imperial, Campinas, 2001, ed. Unicamp; Nunes Mendonça, Joseli M., Entre a Mão e os Anéis, Campinas, 1999, ed. Unicamp; Wehling, Arno, O escravo ante a lei civil e a lei penal no Império, em Wolkmer, A.C. (org.) Fundamentos da História do Direito, B. Horizonte, 2001, ed. Del Rey, pp. 373 ss.; Bandechi, Pedro Brasil, Legislação básica sobre a escravidão no Brasil, em Rev. História, pp. 207ss.; João Luiz Alves, A questão do elemento servil, em Anais do 1º Cong. Hist. Nacional, Rio, 1914, pp. 187 ss.

⁶¹ Já foi mencionado que a legislação filipina vigorou no Brasil até a segunda década do século XX, quanto a aspectos não regulados do direito privado. Seu grande comentarista e compilador brasileiro foi Cândido Mendes de Almeida (Codigo Philipino, Rio, 1870, ed. Tip. Inst. Philomathico; Auxiliar Jurídico, Rio, 1869, ed. Tip. Inst. Philomathico).

⁶² Holloway, Thomas H., op. cit., p. 67. Assim, um edital de polícia de dezembro de 1816 punia o porte de armas brancas ou mesmo impróprias com 300 açoites e 3 meses de trabalhos em obras públicas.

também da posição estratégica do princípio da reserva legal na conjuntura revolucionária burguesa; tal princípio não pode ser contemplado apenas, como parecia supor um penalista do império⁶³, por seu valor técnico-jurídico, mas principalmente por sua significação política. A legalidade deveria, portanto, ingressar no direito brasileiro pela Constituição de 1824 e pelo artigo 1º do Código Criminal de 1830, que também proclamava o princípio. Não foi o que aconteceu. O Código do Processo Criminal de 1832 autorizava o juiz de paz a "cominar" as penas de multa, prisão até 30 dias ou internação por 3 meses em casa de correção ou oficinas públicas aos "suspeitos da pretensão de cometer algum crime", caso violassem o "termo de segurança" que eram obrigados a assinar; tal poder seria transferido, em 1841, para os chefes da polícia, delegados e subdelegados. Isso não é tudo. Lei de 1º de outubro de 1828 atribuía às câmaras municipais a criminalização, através de posturas policiais, de um amplo conjunto de infrações (vozerias nas ruas, injúrias, obscenidades, trazer gado solto, venda de pólvora etc), às quais poderiam impor penas de prisão até 30 dias, em caso de reincidência, e multa. O próprio código criminal mencionava tais contravenções ("crimes contra a polícia e economia particular das povoações"), punidas "na conformidade das posturas municipais" (art. 308, § 4º). Muitas leis provinciais, por seu turno, eram manifesta, latente ou eventualmente penais. Assim, pelo artigo 7º da lei nº 9, de 13.mai.835, da Assembléia Legislativa da Bahia, africanos libertos que chegassem à província e os expulsos que a ela regressassem seriam presos e processados por insurreição, crime ao qual o código imperial impunha, para as lideranças ("cabeças"), a pena de morte (art. 113). Tal lei – elaborada sob a influência da recente revolta

⁶³ Da reserva legal dizia Thomaz Alves Júnior: "é um princípio verdadeiro. Era um dos axiomas favoritos de Feuerbach" (Anotações Theoricas e Practicas ao Código Criminal, Rio, 1864, ed. F.L. Pinto & Cia., v. I, p. 52). Por justiça, ressalte-se que ele estava copiando do prefácio de Vattel à sua tradução do código bávaro (Vattel, Ch., *Code Pénal du Royaume de Bavière*, Paris, 1852, ed. A. Durand, p. XXX).

malé – promovia aí uma equiparação monstruosa, e em seu artigo 21 elevava as penas estabelecidas por um decreto imperial; em ambos os casos, o princípio da reserva legal virava pó. A mera deambulação do escravo, após 21:00 hs., sem bilhete do senhor, era punida com 8 dias de prisão pela câmara municipal da vila de Maracás; já na vila de Joazeiro, 1 dia de prisão responderia a “lundus, batuques e algazarras”; em Feira de Sant’Anna, alugar uma casa a escravos custaria 8 dias de prisão⁶⁴. Sobre a proscrição dos açoites e “mais penas cruéis”, bastaria lembrar que a vedação constitucional era ignorada pelo código criminal, que cominava os açoites, limitados a 50 por dia, aos escravos (art. 60). Na sessão de 16 de maio de 1835 da Câmara dos Deputados, requeriam-se informações ao governo sobre o retorno ao poder de sua senhora de uma escrava “achada com a língua cosida com o lábio inferior”⁶⁵. Uma lei provincial paulista determinava que os senhores arcassem com as despesas de “sustento, vestuário e curativo” dos escravos recapturados⁶⁶. Um Aviso ministerial (nº 365, de 10.jun.861) preconiza a graduação dos açoites “conforme a idade e robustez do réu, na inteligência de que, segundo afirmam os facultativos, quando o número excede a duzentos é sempre se-

⁶⁴ Legislação da Província da Bahia sobre o Negro: 1835-1888, Salvador, 1996, ed. F. Cult. Bahia, pp. 19, 128 e 137. Piza Duarte, Evandro Charles, *Criminologia e Racismo – Introdução ao Processo de Recepção das Teorias Criminológicas no Brasil*, mimeo, UFSC, dissertação de mestrado, trabalha com posturas municipais gaúchas (pp. 244 ss). Cf. também Jupiracy Affonso Rego Rossato, *Sob os olhos da lei: o escravo urbano na legislação municipal da cidade do Rio de Janeiro*, diss. mestrado UFF, Niterói, 2002, mimeo.

⁶⁵ Pereira Pinto, A. (org.), *Annaes do Parlamento Brasileiro, Câmara dos Srs. Deputados*, Rio, 1879, ed. H.J. Pinto, Sessão de 1835, p. 76.

⁶⁶ Lei nº37, de 7.jul.869. Tal lei determinava que, 90 dias após o edital, se procedesse quanto ao escravo não reclamado de modo idêntico à “arrecadação dos bens do evento” (Bandechni, P. Brasil, *Legislação da Província de São Paulo sobre Escravos*, cit., pp. 235 ss.); frisa-se aí a coisificação do escravo. A “gado de vento, de evento, provindo das manadas erradas” se refere Câmara Cascudo (Mouros, Franceses e Judeus – Três Presenças no Brasil, S. Paulo, 2001, ed. Global, p. 26).

guido de funestas conseqüências”; outro Aviso (de 20.jun.879) recomendava “que não se infligam castigos a escravos na casa de detenção sem prévio exame do respectivo facultativo”. Daqueles pelourinhos rústicos – madeiros com pouco mais de dois metros – que Debret viu “fincados em todas as praças mais freqüentadas” do Rio, e registrou numa gravura a fustigação urbana se deslocaria para o interior de um estabelecimento estatal, determinada no entanto pelos senhores (disciplinar) mais que pelos juizes (legal). Em suma, as penas corporais aplicadas aos escravos não figuram apenas nos abundantes relatos, na iconografia ou nos anúncios de jornais que mencionam suas marcas: estavam nas leis, nos atos administrativos, e nos debates parlamentares. Por fim, quanto à responsabilidade penal por fato alheio, observe-se a confirmação, pela assembléia legislativa provincial da Bahia (Resolução de 9.jun.870), de uma postura da câmara municipal da vila do Prado, cujo artigo 22, tutelando a dedicação da força de trabalho servil às tarefas assinadas pelos senhores, punia com multa ou 4 dias de prisão os donos de “tendas, botequins ou tavernas” que permitissem em seus estabelecimentos a “demora de escravos por mais tempo que o necessário para as compras”, com a cláusula “respondendo sempre os senhores pelos caixeiros”⁶⁷. Definitivamente, as promessas liberais não poderiam cumprir-se numa sociedade escravista.

3. O fracasso do projeto liberal ganha mais visibilidade nas fontes que se ocupam da própria organização do sistema penal, com ênfase no processo criminal. A discussão parlamentar das atribuições dos juizes de paz foi integrada por enfáticos pronunciamentos contra o vigilantismo policial, como os de Bernardo Pereira de Vasconcelos⁶⁸. O vigilantismo acabou aprovado, sen-

⁶⁷ Legislação da Província da Bahia, cit., p. 136.

⁶⁸ Dizia ele, na sessão de 19.mai.827, que a vigilância sobre desconhecidos suspeitos implicaria na existência de “um exército de espíões; isto parece-me uma polícia de Fouché”, insurgindo-se também contra a exigência de passaporte para deslocamentos internos. Na sessão de 21.mai.827 retornou

do no entanto confiado a uma autoridade eletiva local, o juiz de paz. O Código do Processo Criminal de Primeira Instância⁶⁹ estruturou um sistema penal que concretamente concedia a administração do poder punitivo direta ou indiretamente às autoridades locais, dos juizes de paz ao júri, passando pelos inspetores de quarteirão, pelos promotores públicos e pelos juizes municipais. A criação da Guarda Nacional, em 18 de agosto de 1831, obedeceu também ao modelo descentralizador⁷⁰, restando nas mãos dos grandes proprietários locais seu comando. Porém o texto legal mais marcante, nessa direção, foi o Ato Adicional (lei nº 16, de 13.ago.834), que criou e outorgou poderes às assembleias legislativas provinciais, entre os quais o de legislar "sobre a policia e economia municipal" (art. 10, § 4º) e decretar a suspensão ou

ao tema: "Eu já disse que ela (a emenda em discussão) ia estabelecer a mais horrorosa policia, porque tinha o juiz de paz de examinar a vida privada e pública dos cidadãos. E neste estado o que será da liberdade e segurança? (...) Senhores, eu prefiro a impunidade dos pequenos delitos a estas inspeções policiais, dignas dos Fouchés e Pombais" (Araújo, cit., 1827, pp. 141 e 143). Vasconcelos abjuraria de suas posições liberais, antes que transcorresse uma década. Sobre ele, que foi o principal artífice do código criminal de 1830, cf. Tarquínio de Souza, Octavio, *História dos Fundadores do Império do Brasil*, Rio, 1957, ed. J. Olympio, v. V; Carvalho, J. M. (org.), *Bernardo Pereira de Vasconcelos*, S. Paulo, 1999, ed. 34 (contendo inúmeros discursos seus).

⁶⁹ Promulgado por lei de 29 de novembro de 1832; um decreto de 13 de dezembro de 1832 ministrava instruções para sua execução. Sobre o código, Pimenta Bueno, J. A., *Apontamentos sobre o Processo Criminal Brasileiro*, Rio, 1857, ed. Garnier; Ramalho, J. L., *Elementos do Processo Criminal*, S. Paulo, 1856, ed. 2 de Dezembro; Alencastro Autran, M. G. de, *Código do Processo Criminal de Primeira Instância*, Rio, 1880, ed. Garnier; Paula Pessoa, V. A. de, *Código do Processo Criminal de Primeira Instância*, Rio, 1899, ed. Jacintho; Figueiras Junior, A., *Código do Processo do Império do Brasil*, Rio, 1874, ed. Laemmert. Sobre as atribuições do juiz de paz, cf. o apócrifo *Actos, Atribuições, Deveres e Obrigações dos Juizes de Paz*, Rio, 1884, ed. Laemmert.

⁷⁰ Cf. Mattos Monteiro, Hamilton, *Da Independência à Vitória da Ordem*, em Maria Yedda Linhares (org.) *História Geral*, cit., pp. 111 ss; Nunes Ferreira, Gabriela, *Centralização e Descentralização no Império*, S. Paulo, 1999, ed. 34, especialmente pp. 23 ss.

demissão de magistrado (art. 11, § 7º). As turbulências do período regencial propiciaram condições para o chamado movimento de "regresso", cujo marco inicial pode situar-se na lei de interpretação do Ato Adicional (nº 105, de 12.mai.840), que tratou de esclarecer que a citada expressão "policia" compreendia apenas a policia administrativa, não a judiciária (art. 1º), bem como que a palavra "magistrado" não abrangia os membros das Relações e tribunais superiores (art. 4º). Através da lei nº 261, de 3 de dezembro de 1841, foi o Código de Processo Criminal reformado, no sentido de transferir os poderes dos juizes de paz – inclusive o de julgar contravenções e crimes punidos com prisão até 6 meses – para as autoridades policiais, acrescentando-lhes outros (arts. 4º, 5º, 6º e 91); juizes municipais e promotores públicos passam a ser incondicionalmente nomeados e demitidos pelo Imperador; dispunha ainda a lei sobre fiança, júri e recursos. Seu regulamento (nº 120, de 31.jan.842), com 504 artigos, afirmava ser o ministro da Justiça o "primeiro chefe e centro de toda a administração policial do Império" (art. 1º, 1º); os passaportes estavam disciplinados (arts. 67 a 90), tanto quanto a "inspeção dos teatros e espetáculos públicos" (arts. 131 a 143); criava-se a estatística criminal (art. 171 ss)⁷¹ e regulamentavam-se extensamente as matérias propriamente processuais da lei. Quando a reforma da Guarda Nacional (lei nº 602, de 19.set.850) deslocar também para o ministro da Justiça seu comando, a obra de centralização estará concluída. O pacto político que a presidiu foi assim sintetizado: "longe de terem sido destruídos pelo governo central, os chefes locais teriam se aliado a ele, com benefícios para os dois lados: o governo ganhava sustentação nas bases rurais, os senhores territoriais legitimavam seu domínio político em nível local"⁷². O interesse especial que esses movimentos de descentra-

⁷¹ Desta matéria tratariam, mais tarde, os decretos nº 3.572, de 30.dez.865, e nº 7.001, de 17.ago.878.

⁷² Gabriela Nunes Ferreira, *op. cit.*, p. 36; nas palavras de Faoro, "as autoridades locais não desaparecem, senão que se atrelam ao poder central; (...) os capangas dos senhores territoriais passam a ser capangas do império" (*op. cit.*, v. I, p. 333).

lização e centralização de poder nos oferecem está na circunstância de terem sido exercidos principalmente com utilização de poder punitivo, manipulado menos na programação criminalizante do que na organização judiciária e policial e no processo penal⁷³. As raízes do autoritarismo policial e do vigilantismo brasileiro estão fincadas nessa conjuntura histórica, que demarca o inevitável fracasso do projeto liberal.

4. É um equívoco recorrente na historiografia jurídica brasileira tomar o código imperial de 1830 como produto da conciliação de dois projetos, o de José Clemente Pereira e o de Bernardo Pereira de Vasconcelos. Na verdade, Clemente Pereira apresentou à assembléia legislativa apenas algumas bases para o futuro código, na sessão de 3 de junho de 1826⁷⁴. Dispostas em 45 artigos, tratavam elas da reserva legal (art. 4º), da personalidade da responsabilidade penal (art. 5º), da tentativa (entendida como perpetração de "um crime que não se seguiu, porque foi estorvado por alguma força estranha" – art. 1º, inc. 4), de autoria e participação (incluindo a receptação e o favorecimento pessoal – art. 9º, incs. 4 e 6) e da imputabilidade (por menoridade, aos sete anos – art. 10). Quanto às penas, divididas entre "aflictivas e infamatórias" (morte, desnaturalização, trabalhos perpétuos e prisão perpétua – arts. 12 e 13) e "aflictivas somente" (degredo, perpétuo ou temporário, trabalhos temporários, prisão temporária, suspen-

⁷³ Cf. Pierangeli, José Henrique, *Processo Penal – Evolução Histórica e Fontes Legislativas*, Bauru, 1983, ed. Jalovi, pp. 133 ss.

⁷⁴ Clemente Pereira se referia a seu trabalho como bases: "depois de ter adiantado algum trabalho sobre as bases que havia estabelecido, lembrei-me que talvez essas mesmas bases houvessem de sofrer grandes transformações (...) julguei que faria algum serviço publicando estas bases". No projeto de lei por ele então oferecido, o artigo 2º rezava: "Ficam desde já reconhecidos como bases os seguintes princípios, que formarão os primeiros dois títulos do livro primeiro do sobredito código" (cf. Annaes, cit., 1826, t. I, p. 16). Também a comissão de legislação e justiça opinaria sobre o projeto valendo-se da palavra bases (Annaes, cit., 1826, t. II, p. 17, sessão de 6.ago.826); todos talvez sob a influência do artigo 179, inciso XVIII da constituição de 1824.

são de direitos e multa – art. 14), proibiam as bases de Clemente Pereira a condenação a duas corporais, salvo quanto aos escravos (arts. 15 e 17); a reincidência duplicaria aquelas aplicadas no primeiro crime (art. 20). A pena de multa, quando não cominada em quantia certa, se quantificaria proporcionalmente ao "rendimento líquido anual dos réus, de um décimo a um terço (art. 42); para o crime de furto, prevalecia o antigo critério de proporcionar-se ao valor de coisa (art. 43). Entre setembro e dezembro de 1826, Bernardo Pereira de Vasconcelos redige seu projeto de código penal em Ouro Preto, aonde se recolhera para recuperar a saúde. Em janeiro de 1827, o periódico *O Universal* anuncia a subscrição, a 1\$600 por exemplar, do projeto⁷⁵. Na sessão de 5 de maio de 1827, Vasconcelos discursava referindo-se ao "meu projeto de código"⁷⁶, apresentado na véspera. Tínhamos aí, efetivamente, um projeto de código penal, que contemplou o princípios da legalidade e da culpabilidade (art. 2º) e mesmo, em fórmula tosca, o da lesividade ("ninguém será castigado pelos crimes que contra si mesmo cometer" – art. 10), definiu a tentativa (exigindo "atos exteriores" e "princípio de execução", que "não teve efeito por circunstâncias fortuitas ou independentes da vontade do delinquente" – art. 1º, inc. 2), estabeleceu a inimputabilidade por imaturidade aos quatorze anos (art. 3º, inc. 1) e previu os "delitos justificáveis" (consentimento do ofendido, estado de necessidade, defesa sem provocação, resistência a ordens ilegítimas e moderação nos castigos – arts. 12 ss). As penas (morte, galés, prisão com trabalho, simples prisão, banimento, desterro, infâmia, multa, perda dos objetos do crime, caução e vigilância – art. 56) eram submetidas a extenso sistema agravador-atenuador (arts. 19 a 29). A pena de multa se regulava "pelo que o réu com os seus bens e indústria pode ganhar em dois dias de trabalho" (art. 90). A parte especial se dispunha de forma inversa à que prevaleceria no código, principiando pelas contravenções ("Dos crimes policiais" – art. 110 ss), seguindo-se os "crimes particulares" (art.

⁷⁵ Tarquínio de Souza, *op. cit.*, p. 61.

⁷⁶ Annaes, cit., 1827, t. I, p. 23.

127 ss) e terminando pelos "delitos públicos" (art. 226 ss). A discussão parlamentar sobre as bases de Clemente Pereira e o projeto de Vasconcelos foi teórica e politicamente muito pobre⁷⁷. A pena de morte – um destacado tópico do debate político-criminal daquela etapa histórica – foi discutida em duas oportunidades. A comissão mista (integrada por deputados e senadores) que examinou as bases de Clemente Pereira e o projeto de Vasconcelos exarou um parecer, registrando que desejara "suprimir a pena de morte", detendo-se diante do "estado atual da nossa população em que a educação primária não pode ser geral"⁷⁸. Um ano mais tarde, a pena de morte foi rediscutida na Câmara dos Deputados, e enquanto Martim Francisco falava de sua ineficiência ("não faz efeito", é "improficua"), mencionando como expediente preventivo a "instrução primária", Lino Coutinho, curto e grosso, afirmava que seu objetivo era "conter a escravatura: esta é a única pena que a pode conter" e "assegurar nossa existência contra os escravos"⁷⁹. Uma discussão cômica sobre autoria e participação, originada de um esdrúxulo artigo do projeto Vasconcelos⁸⁰, levou Ferreira França à desalentada afirmação de que "eu também não sei se cúmplices e sócios são coisas diversas"; após propor o critério da "parte maior" no crime para caracterizar a autoria, pensa aprimorá-lo lembrando que "não são dous os autores, nunca se acha mais do que um"; Lino Coutinho, invocando o código da Luiziana, tenta discernir convivência de cumplicidade pela ca-

⁷⁷ O melhor estudo a respeito segue sendo o de Zahidé Machado Neto, *Direito Penal e Estrutura Social*, S. Paulo, 1977, ed. Saraiva. Observe-se que os *Anaes* só foram publicados em 1875, tendo o responsável pela compilação, Antônio Pereira Pinto, mencionado as inúmeras lacunas que dificultaram seu trabalho.

⁷⁸ *Anaes*, 1829, t. 2, p. 84 (sessão de 31 ago. 829).

⁷⁹ *Anaes*, 1830, t. 2, pp. 508 e 512 (sessões de 14 e 15 set. 830). Nesta última sessão, Paula e Souza, mencionando a "ociosidade e embriaguês" como "paixões favoritas dos escravos", perguntava "quem, senão o terror da morte, fará conter esta gente imoral nos seus limites" (p. 514).

⁸⁰ Art. 9º. Quando houver muitos delinquentes, serão somente punidos os autores dos crimes.

característica de que "o cúmplice de certo modo concorre"; mas Ferreira França já aprimorara sua teoria, no sentido de que "basta um só autor: contente-se o julgado com um só criminoso, caia nesse a pena da lei e esqueçam-se os cúmplices e aderentes"⁸¹. A comissão mista, a partir principalmente do projeto Vasconcelos, formulou diversas alterações, tendo o texto final sido aprovado em outubro de 1830 na câmara e em novembro no senado. O Código Criminal do Império do Brasil foi sancionado pelo imperador em 16 de dezembro de 1830.

5. As influências que o código imperial sofreu, bem como aquelas que exerceu sobre outras legislações, constituem matéria cuja investigação se encontra reaberta, sugerindo portanto um exame um pouco mais minucioso. (a) *Influência francesa*. A despeito da colisão frontal entre o artigo 1º do código penal napoleônico, que estabelecia a divisão tripartida (contravenção, delito e crime), e o artigo 1º do código imperial (que dispunha serem "crime e delito palavras sinônimas"), Tobias Barreto afirmava que o brasileiro "teve o *Code* por principal modelo"⁸². O reconhecimento de alguma influência legislativa (para além da inevitável, naquela conjuntura, influência política e teórica) francesa tornou-se um lugar comum⁸³, que hoje se questiona⁸⁴. Não pode haver dúvida de que José Clemente Pereira, que no artigo 12 de suas bases classificava

⁸¹ *Anaes*, 1830, t. 2, pp. 487, 488 e 489 (sessões de 10 e 11 set. 830).

⁸² Estudos, cit., p. 151. No mesmo sentido, afirmava ele que "o legislador brasileiro regulou-se em mais de um ponto pelas doutrinas do *Code penal*" (p. 83).

⁸³ Cesar Tripoli extrai das "aspirações modernas e liberais" a conveniência da "escolha do código penal francês para servir de molde à confecção do código criminal do Brasil" (História, cit., v. II, p. 219); a influência francesa é geralmente reconhecida na literatura jurídico-penal (p. ex., Fragoso, Lições, cit., PG, p. 60; Bruno, *Direito Penal*, cit., PG, t. I, p. 165).

⁸⁴ Cf. Rivacoba y Rivacoba, M. e Zaffaroni, E.R., *Siglo y Medio de Codificación Penal en Iberoamérica*, Valparaíso 1980, ed. Edeval, pp. 34 ss; Pierangeli, J.H., *Código Penais do Brasil*, S. Paulo, 2001, ed. RT, que nesta segunda edição reformula sua opinião, aduzindo que "alguns autores, muitas vezes sem explicitar quando e onde, têm assinalado a influência do código francês" (p. 70).

as penas em "aflictivas e infamatórias ou aflictivas somente", contactou o direito francês⁸⁵. Da mesma forma, no projeto de Bernardo Pereira de Vasconcelos a previsão da pena de infâmia (art. 56, 7^o) bem como a utilização de expedientes infamatórios na execução de outras penas (como o "rótulo do crime nas costas" dos condenados a galés — art. 72 — ou do padecente a caminho da forca — art. 63) não constitui uma permanência do estílo penal do antigo regime⁸⁶, podendo mais propriamente reportar-se ao uso revolucionário da infamação, que se valia de expedientes similares⁸⁷. Há, porém, muito mais. O artigo 66 do projeto Vasconcelos, que permitia a entrega do corpo dos enforcados a suas famílias, proibindo seu enterro com pompa, e resultou no artigo 42 do código imperial, não se inspirou diretamente no artigo 14 do *Code*? Mesmo com o desconto de que a minuciosa descrição das condições penais integrava o severo compromisso do legislador da época com o princípio da legalidade, as inúmeras coincidências entre as condições das galés segundo as bases de Clemente Pereira (art. 28) e o projeto de Vasconcelos (arts. 72 e 73), que resultaram nos artigos 44 e 45 do código imperial, inclusive a conversão em prisão para as mulheres, e as condições similares do código de 1791 (arts. 6^o a

⁸⁵ Seja o projeto de Lepeletier de Saint-Fargeau (que no artigo 1^o classificava as penas em "afflictives" e "infamantes", esclarecendo no 5^o que "toute peine afflictive sera infamante"), do qual provejo o código penal de 1791, seja o código napoleônico (art. 6^o: "les peines en matière criminelle sont ou afflictives et infamantes, ou seulement infamantes"). Sobre Lepeletier, cf. Plawski, Stanislaw, em RScCrDPC, 1957, pp. 619 ss.

⁸⁶ Como certamente o eram outras passagens, da previsão de penas arbitrárias (art. 59) à permissão para que do enforcado "lhe sejam cortadas a cabeça e mãos para serem afixadas no lugar do delito" (art. 62).

⁸⁷ Segundo o código de 1791, condenados aos ferros e a outras penas corporais seriam expostos publicamente por determinado período, portando um cartaz onde "seront inscrits en gros caractères son nom, sa profession, son domicile, la cause de sa condamnation et le jugement rendu contre lui" (art. 28). Como se sabe, o código napoleônico não se afastou das penas corporais senão a partir de 1830, sendo a exposição pública banida apenas em 1848 (cf. Laurent, Hippolyte, *Les Chatiments Corporels*, Lyon, 1912, ed. Philly, p. 160); os legisladores do código imperial brasileiro não podiam conhecer essa tendência.

10) e do código de 1810 (arts. 15 e 16) serão mera casualidade? As proibições de execução da pena de morte em domingos ou dias de festa nacionais ou religiosas (art. 39 CCr) e em mulher grávida antes de seu parto (art. 43 CCr), conquanto comuns a muitas legislações, têm uma fonte direta e acessível no código napoleônico (arts. 25 e 27). No emprego, ainda que não exclusivo, de penas mitigadamente tarifadas (com graus máximo, médio e mínimo), tal como preconizado no artigo 18 das bases de Clemente Pereira, ecoa uma preocupação com o arbítrio judicial que o código de 1791 levava às últimas consequências: Lepeletier procurara com insistência o objetivo de "établir pour chaque délit une peine fixe et déterminée". A definição de emboscada do projeto Vasconcelos ("quando se esperou o ofendido em um ou diversos lugares" — art. 20, 13), que passou ao código imperial ("ter o delinqüente esperado o ofendido em um ou diversos lugares" — art. 16, 12) provém diretamente da qualificadora do *guet-apens*, prevista no artigo 298 do código napoleônico, que se refere à espera da vítima "dans un ou divers lieux". Parece inquestionável que, sem o exagero de Tobias Barreto, cabe reconhecer influência legislativa francesa no código imperial. (b) *Influência de Bentham*. O prestígio de Jeremias Bentham à época pode ser confirmado pelo fato de ter sido ele, ao lado de Livingston, o autor mais citado nas atas dos trabalhos parlamentares de elaboração do código imperial; suas idéias circulavam entre nós através das duas coletâneas de textos seus, organizadas e traduzidas por Dumont⁸⁸. Não obstante, quando Thomaz Alves Junior afirmou que "nosso código criminal moldou suas doutrinas sobre o sistema de utilidade ou escola do célebre jurisconsulto Jeremias Bentham"⁸⁹ foi energicamente contestado

⁸⁸ Dumont, Et., *Traité de Législation Civile et Pénale — ouvrage extrait des manuscrits de M. Jérémie Bentham*, Paris, 1830 (3^a ed.), ed. Rey e Gravier; *Théorie des Peines et des Récompenses — ouvrage extrait des manuscrits de M. Jérémie Bentham, jurisconsulte anglais*, Paris, 1825 (3^a ed.), ed. Bossanges Fr.

⁸⁹ Anotações Theóricas e Práticas, cit., v. I, p. 45. O parecer da comissão mista, encarregada de rever e compatibilizar as bases de Clemente Pereira e o projeto de Vasconcelos, expressamente consignara "ter seguido com todo o rigor da análise o desenvolvimento do princípio cardinal da utilidade", referido no artigo 162, §2^a da constituição imperial (cf. Annaes, cit., 1829,

por Camargo, a quem horrorizava a possibilidade de que nossa legislação "se basasse no sensualismo ou no utilitarismo de J. Bentham"⁹⁰. Nenhum dos dois estava completamente certo: da influência de Bentham não se pode dizer que tenha "moldado as doutrinas" do código imperial, e ao mesmo tempo não se pode negá-la. Apesar de tratar-se de uma influência não formulada legislativamente, e sim como reflexão teórica, deixou seus vestígios nos textos. O tradutor de Bentham falava da "*douceur*" (em oposição à *rigueur*) das penas, e de seu "*adoucisement*"⁹¹; foi o suficiente para Vasconcelos, em seu projeto, tratando da atenuante da menoridade, estabelecer que "o juiz poderá mudar a natureza da pena, adoçando-a, como for de razão" (art. 22,8°). A sexta regra de Bentham sobre determinação da pena recomendava observar a influência da "*sensibilité*"⁹²; eis o projeto Vasconcelos importando a "sensibilidade do ofendido ou do delinquente" como critério de agravção ou atenuação (art. 24), adotado pelo código imperial no artigo 19. O receio benthamiano de tornar inócua a pena de banimento⁹³ repercute no artigo 82 do projeto Vasconcelos, que se converterá na parte final do artigo 50 do código imperial. Da mesma forma, o dispositivo do projeto Vasconcelos que poderia tomar-se como a primeira formulação brasileira do princípio da lesividade⁹⁴ não passa de incorporação da categoria benthamiana dos "*délits réflexifs ou contre soi-même*"⁹⁵. Vasconcelos leu Bentham, e valeu-se intensamente das opiniões dele em seu projeto; muitas delas foram ter ao código imperial. O artigo 3°, tão avançado para a época que foi praticamente suspenso por avisos ministeriais, que não permi-

v. II, p. 84).

⁹⁰ Cf. Camargo, J.A., *Direito Penal Brasileiro*, Rio, 1881, pp. 221 ss.

⁹¹ *Théorie*, cit., v. I, pp. 17 e 139.

⁹² *Théorie*, cit., v. I, pp. 31 ss.

⁹³ As facilidades que a América oferecia o preocupavam: *Théorie*, cit., v. I, p. 194.

⁹⁴ Art. 10. Ninguém será castigado pelos crimes que contra si mesmo cometer, exceto nos casos expressos nas leis, ou determinações das autoridades competentes, e nos em que de tais crimes resulta mal a terceiro.

⁹⁵ *Traité*, cit., v. II, p. 2.

tiam fosse ele submetido ao júri⁹⁶, usava as expressões "conhecimento do mal" e "intenção", extraídas de Bentham⁹⁷. As agravantes do uso de disfarce (art. 16, § 16 CCr; art. 20,15 do projeto Vasconcelos) e do diferencial etário (art. 16, § 5° CCr; art. 20,3 do projeto Vasconcelos) provêm de considerações de Bentham, e se articulam com palavras dele⁹⁸. Em suma, naquela polêmica travada por dois penalistas do império, Thomaz Alves Júnior estava menos equivocado. (c) *Influência de Livingston*. Eduardo Livingston foi, como já frisado, ao lado de Bentham, a autoridade mais referida nos debates parlamentares pertinentes à elaboração do código. De seu projeto de código penal para a Luisiânia foram oferecidos à Câmara dos Deputados dois exemplares⁹⁹, um dos quais traduzido, contendo a exposição de motivos e uma seleta do complexo articulado, em cinco livros, do Beccaria de Nova Orleans¹⁰⁰. A despeito de estar ele mesmo confessadamente influenciado por Bentham, é possível respigar nos trabalhos preparatórios e no próprio código imperial vestígios de seu pensamento: o desânimo do deputado Ferreira França quanto aos "cúmplices e aderentes" é reportável ao artigo 55 do livro II de Livingston¹⁰¹. Impressiona a similitude entre o cardápio de penas propostas por Livingston e aquele constante do artigo 56 do projeto Vasconcelos. Semelhanças redacionais podem ainda ser notadas na definição formal de crime (art. 2°, § 1° C.Cr. e art. 24, livro II do projeto Livingston) e na tentativa (art. 2°, § 2° C. Cr. e art. 41, livro II, do projeto Livingston). O artigo 64 C.Cr., segundo o qual os condenados que "se acharem no estado de

⁹⁶ Avisos nº 46, de 16.fev.854, e nº 133, de 14.abr.858.

⁹⁷ "*Celui qui a fait le mal avec intention et connoissance*"... (*Traité*, cit., v. II, p. 20).

⁹⁸ Respectivamente *Traité*, cit., v. II, p. 35 e v. III, p. 100.

⁹⁹ Cf. Zahidé Machado Neto, *op. cit.*, pp. 57 e 59.

¹⁰⁰ Certamente o trabalho de Taillandier, M.A.H., *Rapport sur le projet d'un code pénal fait à l'assemblée générale de l'état de la Louisiane par M. Édouard Livingston*, publicado em Paris em 1825 (ed. A.A. Renouard). A comparação com Beccaria está na introdução do tradutor. Referenda a hipótese de ter sido este o texto utilizado sua expressa menção pelos penalistas do império (p. ex., Thomaz Alves Júnior, *op. cit.*, v. I, p. 139).

¹⁰¹ Art. 55. *Il peut y avoir des complices et des adhérens dans tous les cas de délit.*

loucura não serão punidos enquanto nesse estado se conservarem" parece originado do artigo 30, *in fine*, do projeto Livingston¹⁰². A escusa do caso fortuito, prevista no artigo 10, § 4º do código imperial, que isenta de pena crimes praticados "casualmente, no exercício de qualquer ato lícito, feito com atenção ordinária" provém diretamente do artigo 37, livro II, do projeto Livingston¹⁰³; retornaremos oportunamente a este dispositivo. (d) *Influência de Mello Freire*. A circunstância de José Clemente Pereira e Bernardo Pereira de Vasconcelos terem sido "ambos egressos de Coimbra"¹⁰⁴, onde o magistério de Pascoal José de Mello Freire predominou para muito além de sua jubilação (1790), sugeriria uma forte influência do projeto por ele elaborado, em 1789, por encomenda da rainha Maria I¹⁰⁵. O exame comparativo dos textos, entretanto, desmente tal sugestão. Desde logo, o artigo 3º do Código Criminal¹⁰⁶, que impôs aos penalistas do império tantas cabriolas para, recorrendo a um "conhecimento menos pleno e a uma intenção indireta"¹⁰⁷, viabilizarem a punição de crimes culposos, contrapõe-se frontalmente ao § 1º, T. I do projeto Mello Freire (p.M.F.)¹⁰⁸. A impunibilidade da "simples cogitação, mera vontade" (§ 2º, T. I p.M.F.) não teve ressonância no código imperial, num contexto histórico que recomendaria sua proclamação. A tentativa, que no texto lusitano era sempre impunível, ressalvados os "factos ilícitos que obrou" anteriormente o sujeito, com a explícita afirmação

¹⁰² *Aucune personne condamnée ne sera punie, si elle tombe et continue en démence.*

¹⁰³ *Nul événement arrivé par méprise ou accident dans l'exécution d'un acte légal, fait avec une attention ordinaire n'est un délit.*

¹⁰⁴ Gaier, Ruth M.C., *A Construção do Estado-Nação no Brasil*, Curitiba, 2001, ed. Juruá, p. 305.

¹⁰⁵ Mello Freire, P.J. de, *Ensaio do Código Criminal a que Mandou Proceder a Rainha Fidelíssima D. Maria I*, Lisboa, 1823, ed. M. Setáro.

¹⁰⁶ Não haverá criminoso ou delinqüente sem má-fé, isto é, sem conhecimento do mal e intenção de o praticar.

¹⁰⁷ Assim, Braz Florentino, *Lições de Direito Criminal*, Pernambuco, 1872, ed. J.N. Souza, p. 131, socorrendo-se do art. 18, § 1º C. Cr.

¹⁰⁸ Sem dolo e malícia, ou culpa, não se pode considerar delicto para o efeito da pena.

de que "o conato não é o mesmo delicto" (§ 4º, T. I, p.M.F.), teve no código imperial disciplina diversa (art. 2º, § 2º), ainda que impunível nos crimes cuja pena fosse inferior a 2 meses de prisão ou desterro para fora da comarca (dispositivo oriundo do projeto Vasconcelos, art. 2º; as bases de Pereira excluíam a punibilidade da tentativa nas contravenções, art. 3º). A precursora formulação do princípio da lesividade por Mello Freire¹⁰⁹ é completamente distinta do já transcrito artigo 10 do projeto Vasconcelos. Na classificação dos crimes em públicos e privados (§ 7º, T. I p.M.F.) respeitáveis autores assinalam uma influência, discutível não só porque a essas duas classes o código imperial agregava os "crimes policiais", mas principalmente porque consistia uma tendência muito generalizada no penalismo ilustrado sair da matriz da classificação canônica (que na versão mais ortodoxa buscava imitar a ordem dos dez mandamentos) para retornar à matriz romana. Aliás, a parte especial do projeto Mello Freire, contraditoriamente, submete-se ao primeiro modelo, não passando de uma atualização das Ordenações Filipinas, que, como elas, principia pelos filhotes penais do primeiro mandamento, a criminalização casuística de herejes, apóstatas, cismáticos, blasfemos etc (T. V ss): dela se pode afirmar, com certeza, que teve pouca influência sobre o código imperial (mencionaremos, adiante, uma provável influência quanto à letalidade das lesões). Embora possa parecer temerário generalizar tal afirmação, é extremamente difícil encontrar vestígios confiáveis. Proviriam os "lúcidos intervalos" (art. 10, § 2º C.Cr.), durante os quais os loucos são imputáveis, daqueles "intervalos de razão" dos "furiosos e lunáticos" (§ 4º, T. II p.M.F.)? Mera conjectura. Mello Freire redige seu "ensaio" num momento de transição, porém ainda dentro do regime antigo. Se é certo que, fiel a sua própria doutrina, não contempla a tortura como prova, e tenta proteger o réu interrogado com uma regulamentação preciosista, não é menos certo que dispõe sobre o esquartejamento e a evisceração *post*

¹⁰⁹ § 5º, T. I — Os factos que não offenderem a sociedade, nem os individuos della, posto que sejam illicitos, não serão reputados verdadeiros delictos.

mortem do condenado por *perduellio* (T. XIII, § 17 p.M.F.). Quicá tais ambiguidades, diretamente associáveis à conjuntura política na qual Mello Freire elaborou seu projeto¹¹⁰, respondam pela decepçionante influência sobre o código imperial. (e) *Influência do código bávaro*. A prova habitualmente invocada para a determinação de alguma influência do código bávaro de 1813 (C. Báv.), elaborado por Feuerbach, sobre o código imperial, ou seja, a imprescritibilidade das penas (art. 65 C.Cr.), é fraca. Apesar da afirmação peremptória inicial, o dispositivo correspondente (art. 139 C.Báv.) reconhecia, sob certas condições, a prescrição, ressaltando inclusive não atingir ela a obrigação de reparar o dano *ex delicto*, e quatro prazos eram estabelecidos para seu decurso, segundo a pena cominada (art. 140 C. Báv.). Em oposição à concepção unitária brasileira (art. 1º C.Cr.), a lei da Baviera adotava uma divisão tripartida, entre crimes, delitos e contravenções (art. 2º C. Báv.). Existem algumas similitudes, embora encontráveis em outras legislações da época, como a referência explícita às calceias impostas aos condenados às galés (art. 7º C.Báv. e art. 44 C.Cr.; art. 28 bases Pereira e art. 72 projeto Vasconcelos). Se os diplomas franceses, como vimos, não dispusessem igualmente a respeito, seria imaginável que Vasconcelos teria buscado na Baviera (arts. 5º e 7º, *in fine*) aquele “rótulo nas costas” referido ao delito praticado, que ele desejou impor os condenados à morte e às galés (arts. 63 e 72 projeto Vasconcelos), e felizmente não chegou ao código imperial. Aquela “vigilância da justiça” que Vasconcelos incorporou como pena a seu projeto (arts. 56, inc. 11, e 89) seria inspirada na medida cautelar de vigilância especial da polícia, de que Feuerbach se valera (arts. 59 e 117 C. Báv.)? Ao patamar máximo de 50 açoites do código bávaro (art. 25) correspondia a limitação de 50 açoites “por dia” do nosso (art. 60, *in fine* C. Cr.). A questão da causalidade das lesões corporais das quais decorra homicídio, então gravitando em torno da velha idéia da letalidade das lesões, está disciplinada de forma distinta nos dois diplomas (arts. 143 ss C. Báv. e 194 ss C. Cr.). Por outro lado, a atenuante da menoridade (art. 18, § 1º, e art.

¹¹⁰ Aspecto realçado por Rívaco e Zaffaroni, *Stigla y Médio*, cit., p. 36.

45, § 2º C. Cr.), dada por Roberto Lyra como uma “inovação brasileira”¹¹¹, figurava no código bávaro (arts. 98 ss). Se a influência sobre o código imperial é duvidosa, até mesmo diante da tradução francesa ter sido publicada apenas em 1852¹¹², é fora de dúvida que o § 4º do artigo 27 do código republicano de 1890, tão execrado por Hungria¹¹³, provém da “perturbação dos sentidos ou da inteligência” que Feuerbach manejava em seu código (art. 121 C. Báv.). (f) *Influência do código napolitano*. A maior dificuldade para respigar algum vestígio do *Codice per lo Regno delle due Sicilie*, de 1819, em nosso código imperial, está no fato de que, em decorrência da dominação francesa, consistia ele numa espécie de adaptação do *Code Pénal*, que vinha substituir uma quase literal tradução deste ao italiano, vigente desde 1808, com pequenas alterações — aliás, progressistas, como a supressão da mutilação da mão do parricida antes de sua execução¹¹⁴. É duvidoso que Pereira ou Vasconcelos — cujos textos preliminares previam penas infamantes, como visto — tenham contactado uma legislação que afirmava peremptoriamente que “nenhuma pena é infamante” (T. I, art. 1º, inc. 2º), ao contrário dos modelos franceses então disponíveis. Alguma similitude redacional (como aquela na fórmula do princípio da reserva legal, entre o artigo 60 do código napolitano e o artigo 33 do código imperial), ou o emprêgo de soluções equiparáveis (como a pesquisa judicial de discernimento nos menores entre 9 e 14 anos, no código napolitano, e nos menores de 14 anos no código imperial) não superam divergências radicais, como por exemplo no tratamento dos crimes políticos, onde a superioridade

¹¹¹ Direito Penal Normativo, Rio, 1975, ed. J. Konfino, p. 42.

¹¹² *Code Pénal du Royaume de Bavière*, trad. Ch. Vatet, Paris, 1852, ed. A. Durand. Após tal tradução é que o diploma bávaro começa a ser citado na literatura brasileira (p. ex., Thomaz Alves Júnior, op. cit., pp. 116 e 501).

¹¹³ Com expresso reconhecimento do “modelo bávaro”: Comentários, v. I, t. II, p. 381.

¹¹⁴ Cf. Pessina, *Il Diritto Penale in Italia*, em *Enciclopedia*, cit., v II, pp. 580 ss.; Stile, Alfonso M., *Il codice penale del 1819 per lo Regno delle due Sicilie*, em Vinciguerra, Sergio, *Il Codici Preunitari e il Codice Zanardelli*, Pádua, 1999, ed. Cedam, pp. 183 ss.

brasileira é evidente. As raízes francesas do código napolitano, que naturalmente adotara a divisão tripartida, invalidariam muitas referências comuns. Um dos méritos do código napolitano, a ruptura com a consideração da receptação como participação *ex post facto*, foi desconhecido pelo código imperial (art. 6º, § 1º). Quaisquer que tenham sido – e só uma pesquisa, até agora não realizada e talvez irrealizável, na biblioteca de seus redatores, sanaria certas dúvidas sobre elas – quaisquer que tenham sido as influências, o código imperial teve inquestionável originalidade¹¹⁵ no tratamento das matérias de que se ocupou. Traduzido ao francês por Victor Foucher¹¹⁶, viria por seu turno a influenciar diretamente o código penal espanhol de 1848, e portanto, indiretamente, muitas legislações latino-americanas.

6. São muitas as ambiguidades do diploma patriarcal escravista. Se a pena de morte foi expungida de acessórios cruéis ou infamantes, mais do que na maior parte de seus prováveis modelos (e ser o padecente conduzido à forca com seu “vestido ordinário” – art. 40 – sinaliza este avanço), sua escabrosa facilitação processual para réus escravos compete com a invulnerabilidade a ela dos senhores¹¹⁷. Se os legisladores, invertendo o conselho de Beccaria, não cominaram a pena de morte para crimes políticos (decisão que, naquela incendiada conjuntura, tinha sabor de autoproteção), o crime de insurreição – a reunião

¹¹⁵ Fragoso, Lições, P.G., cit., p. 61.

¹¹⁶ *Code Criminale de l'Empire du Brésil, adopté par les Chambres Législatives dans la session de 1830.*

¹¹⁷ A execução do fazendeiro Manoel da Motta Coqueiro, em 1855, despertaria grande celeuma sobre a pena capital, após um moribundo ter-se atribuído a autoria dos homicídios pelos quais fora aquele condenado; cf. José do Patrocínio, Motta Coqueiro e a Pena de Morte, Rio, 1887; Menezes, Raimundo de, O enforcamento de Motta Coqueiro, em Investigações, S. Paulo, 1952; Marchi, Carlos, Fera de Macabu, Rio, 1998. Parece que Motta Coqueiro foi apenas um dos últimos brancos proprietários executados (neste sentido, Luis Francisco Carvalho Filho, Motta Coqueiro: o erro em torno do erro, em Rev. IBCCrim, v. 33, pp. 261 ss.).

de vinte escravos para “haverem a liberdade por meio da força” (art. 113 C.Cr.) – não era considerado político, embora incluído no título “Dos crimes contra a segurança interna do Império e pública tranquilidade”. Para além dessas ambiguidades, onde aflora a contradição entre liberalismo e escravidão, poderemos encontrar soluções técnico-jurídicas criativas e originais. A invenção do dia-multa (art. 55), fórmula que realizava o ideal de proporcionalidade no âmbito da pena pecuniária como nenhuma outra, é uma delas. Também cabe mencionar a invenção da responsabilidade sucessiva nos crimes de imprensa (arts. 7º e 8º), antes da lei belga que receberia as honras do (falso) pioneirismo. Aqui a criatividade consistia em, homenageando o valor liberal da imprensa, abrir parênteses na disciplina geral da co-autoria e participação, para que apenas *um* responsável fosse reconhecido (autor do escrito, impressor, gravador, litógrafo, editor, vendedor), preservando-se a estrutura do jornal¹¹⁸. Na parte especial, penas tarifadas (graus máximo, médio e mínimo) conviviam com escalas penais que o juiz percorreria tendo em conta um volumoso conjunto de circunstâncias agravantes (arts. 16 e 17) e atenuantes (arts. 18 e 19). Já mencionamos a tormentosa questão da letalidade da lesão (arts. 194 e 195), legado histórico que teria se inspirado no ensaio de Mello Freire, neste ponto considerado pelo projeto Vasconcelos¹¹⁹, lugar inicial da história brasileira da causalidade. A questão dos crimes culposos merece referência mais ampla. Como vimos, o artigo 3º do código imperial (exigindo “conhecimento do mal e intenção de o praticar”), temperado pela atenuação da inoccorrência de “pleno conhecimento do mal e direta intenção de o praticar” (art. 18, § 3º) levou os penalistas a certas piruetas, ancoradas na velha concepção tomista da

¹¹⁸ Os penalistas do império tinham essa compreensão (p. ex., Braz Florentino, *op. cit.*, p. 182), nem sempre clara em seus sucessores.

¹¹⁹ Cf. Eduardo Teixeira de Carvalho Durão, A conêausa no homicídio, em O Direito, Rio, 1891, ed. Montenegro, v. 55, pp. 540 ss; para uma visão médica da matéria, João Baptista Correia, Breves Considerações sobre alguns Pontos de nossa Legislação Criminal, Rio, 1846, ed. Imparcial.

voluntas indirecta, acessada principalmente através de autores franceses, para fundamentar não o dolo eventual – na linha do que estava se passando por toda parte – mas sim a punibilidade dos crimes culposos¹²⁰. É que o código, embora contendo a previsão especial de escassos crimes culposos, nada teria disposto sobre eles na parte geral¹²¹. Mas o código dispusera, sim: o § 4º do artigo 10 contemplava a excusa do *casus*, através de fórmula na qual um resquício do *versari in re illicita* se articulava a uma nítida delimitação com a culpa¹²². A cláusula “atenção ordinária” representava uma referência normativa muito bem elaborada – avançada para a época –, sinalizadora de culpa; neste sentido, a doutrina espanhola acerca do artigo 8º, inciso 8º do código de 1848, no qual, sob influência brasileira, se traduzira tal cláusula por “*debida diligencia*”¹²³. Sucede que, por um erro de impressão, grafou-se “*tenção ordinária*”. Julgamentos foram anulados por questionarem ao júri sobre atenção ordinária; mesmo após a incorporação do homicídio e das lesões culposas, os tribunais não enlaçavam sua disciplina nas virtualidades teóricas daquela cláusula¹²⁴. Só em 1885, por iniciativa de João José do Monte, diretor da revista O Direito, o Arquivo Público certificou que do

¹²⁰ Cf. Thomaz Alves Júnior, op. cit., pp. 145 ss; J. Camargo, op. cit., pp. 107 ss; Braz Florentino, op. cit., pp. 129 ss.

¹²¹ “Efetivamente o código não aludia à culpa em disposição alguma de modo geral”, queixava-se Vieira de Araújo, João, Código Criminal Brasileiro, Recife, 1889, ed. J.N. Souza, p. 79. Para um tipo culposo, cf., por exemplo, o artigo 125 (fuga de presos “sendo por negligência”). Em 1874, a Relação da Corte (ac. nº 7.913) absolveu um carcereiro “pela razão de não haver na cadeia correntes nem outros meios de segurança para os escravos fugidos” (Paula Pessoa, op. cit., p. 228). Homicídios e lesões corporais culposos só se incorporariam ao código em 1871 (lei nº 2.033, de 20.set.871).

¹²² Art. 10. Também não se julgarão criminosos: (...) § 4º. Os que cometerem crimes casualmente no exercício ou na prática de qualquer ato lícito, feito com atenção ordinária.

¹²³ Pacheco, Joaquín Francisco, *El Código Penal Concordado y Comentado*, Madrid, 2000, ed. Edisofer, pp. 185 ss.

¹²⁴ Cf. Milton, Aristides A., O art. 10, § 4º do código criminal e o art. 19 da lei nº 2.033, de 20.set.71, em O Direito, v. 13, pp. 472 ss.

autógrafo do código constava *atenção*, e não *tenção* ordinária¹²⁵. O quanto tal erro de impressão perturbou a teoria do crime culposos entre nós é um tema à espera de estudo.

7. Queixavam-se os penalistas do império da proliferação de leis penais¹²⁶. Da síntese que se segue da legislação extravagante penal estão excluídas as leis de caráter processual, referidas anteriormente na descrição dos movimentos de descentralização-centralização do poder punitivo no império. Não por acaso, a primeira tentativa de reforma do código criminal incidia sobre o artigo 36, de caráter processual¹²⁷. Excluídas também estão as leis penais provinciais e municipais¹²⁸. A lei nº 631,

¹²⁵ O requerimento e a certidão em Ferreira Tinoco, Antônio Luiz, Código Criminal do Império do Brasil Annotado, Rio, 1886, ed. Imp. Industrial, p. 568.

¹²⁶ “Nesse número infinito de leis penais, tanto as que compõem o código como as que, em quantidade muito maior, acham-se fora dele, haverá alguém que possa dizer, mesmo entre aqueles cuja profissão é estudá-las e aplicá-las, que as conhece todas, ou quase todas?” – indagava, sem prever que o futuro seria muito pior, Braz Florentino (op. cit., p. 119).

¹²⁷ Art. 36. Nenhuma presunção, por mais veemente que seja, dará motivo para imposição de pena. Na discussão parlamentar, em 13 de julho de 1832, o deputado Ribeiro de Andrade argumentou com uma curiosa equiparação do princípio da lesividade com as presunções: “se as opiniões e intenções dos homens, embora contrárias à sociedade, “não são crimes porque são idealidades, as suspeitas e indícios não são provas, porque são igualmente idealidades” (Annaes, cit., 1832, v. II, p. 62).

¹²⁸ O medo branco, tanguido pelas notícias do Haiti e da revolta malé na Bahia, produziu uma duríssima legislação penal provincial e municipal. Na província do Rio de Janeiro, a lei nº 5, de 27.mar.835, suspendia as garantias constitucionais para suspeitos de insurreição (art. 1º), criminalizando “discursos diretamente tendentes a promover insurreição” (art. 2º), facultando ao presidente expulsar “todos os estrangeiros de cor de um e outro sexo”, especialmente aqueles ocupados “no tráfico de mascates e pombeiros” (art. 4º); toda associação secreta da qual participasse “algum estrangeiro de cor” era declarada criminosa (art. 7º). Tal lei seria substituída pela de nº 45, de 11.mai.836, de teor semelhante. Decreto nº 46, de 13.mai.836 aprovava posturas municipais das cidades de Niterói e Cabo Frio e das vilas de Marica, Itaboraí e Magé, segundo as quais a venda de pólvora ou armas a escravos ou “pessoas suspeitas” era punida, na reincidência, com 30 dias de cadeia e

de 18.set.831, criou crimes militares. A lei nº 52, de 3.out.833 (arts. 7º ss) alterou o artigo 173 C.Cr. (moeda falsa). A lei – que Thomaz Alves Junior chamou de “muito especial”¹²⁹ – nº 4, de 10.jun.835, cominava irrecoerivelmente (art. 4º) a pena de morte para escravos que matassem ou ferissem gravemente o senhor, o feitor ou seus familiares¹³⁰. Uma semana após a edição desta lei, um Aviso recomendava que a força fosse levantada apenas

multa para livres e 100 a 200 açoites para escravos. Pena idêntica respondia aos “donos, administradores ou caixeiros de armazém, botequins ou tavernas” nos quais “se encontrar ajuntamento de mais de três escravos”. Qualquer escravo encontrado à noite, ou em domingos e feriados sem um bilhete do senhor receberia de 20 a 50 açoites. Proibia-se finalmente o exercício da profissão de “mascate ou pombeiro”, sob a ameaça penal de 100 a 200 açoites. “Ajuntamentos para danças ou *candomby*”(sic) custavam, para os anfitriões livres, 8 dias de cadeia e multa; para os bailarinos escravos, 50 a 100 açoites (Legislação Provincial do Rio de Janeiro, de 1835 a 1850, Niterói, 1850, ed. Tip. Fluminense de Lopes, pp. 5, 91, 92). Este era o direito penal do cotidiano, ausente dos livros e cego para o princípio da legalidade.

¹²⁹ *Op. cit.*, p. 74.

¹³⁰ Não procede a opinião corrente de que tal lei foi consequência da revolta malê na Bahia, ainda que a aceleração de seu procedimento legislativo tenha sofrido tal influência: seu projeto tramitava por dois anos. Cf. Ribeiro, João Luiz de Araújo, A lei de 10 de junho de 1835, Rio, 2000, dissertação de mestrado em História Social; Graden, Dale T., Uma lei ... até de segurança pública, em *Rev. Estudos Afro-asiáticos*, Rio, 1996, nº 30, pp. 113 ss. Ribeiro, João Luiz, No Meio das Galinhas as Barbas não têm Razão, Rio, 2005, ed. Renovar. Decreto de 11.abr.829 (regulamentador da lei de 11.set.826) já autorizava que as sentenças capitais contra escravos condenados pelo homicídio de senhores fossem “executadas independentemente de subirem a minha imperial clemência”. Na verdade, e indiscutivelmente a partir do Reg. nº 120, de 31.jan.842 (cujo artigo 501, mantendo a irrecoeribilidade da lei nº 4, de 10.jun.835, ressaltava o direito de petição de graça ao poder moderador, contrariando o artigo 2º do decreto de 9.mar.837), a única revisão possível era na seção de Justiça do Conselho de Estado (cf. Soares de Souza, Os escravos e a pena de morte no império, em *Rev. IHGB*, Rio, v. 313, pp. 5 ss). Anteriormente a 1842, a negativa mesmo de graça para homicídios de senhor era observada, como na S. João del Rei de 1833 (Ribeiro, J.L. de Araújo, *op. cit.*, p. 30), ou simplesmente o advogado se esquecia de requerê-la, como na Vassouras de 1839 (cf. Pinaud, João Luiz *et alii*, *Insurreição Negra e Justiça*, Rio, 1987, ed. Exp. e Cultura, p. 69).

quando necessário, para não ficar continuamente à vista de todos. A “lei Euzébio de Queiroz”, de 4.set.850, repristinou de fato uma lei, de 7.nov.831, que criminalizara por equiparação ao artigo 179 C.Cr. (art. 2º) o tráfico negreiro, mas que “permanecera letra morta”¹³¹. A lei nº 601, de 18.set.80, chamada lei de terras e imigração, é menos importante pela matéria penal nela contida (o art. 2º criminalizava o esbulho de terras devolutas ou alheias, e o incêndio rural) do que por consistir na matriz da tragédia fundiária brasileira¹³². Cabe mencionar o regulamento de 29 de setembro de 1851, cujo artigo 51 contemplava a venda irregular de “substâncias venenosas”, expressão que chegaria ao código penal de 1890 e seria mais tarde substituída por entorpecentes; tratava-se de contravenção, naquela ocasião julgada pelo delegado de polícia com recurso para o juiz de direito (art. 77); o controle administrativo de médicos, boticários e droguistas também se centralizava então, saindo da esfera das câmaras municipais (aviso do ministério do Império de 12.out.869). Muitos decretos (12.jul.851; 16.dez.853; 14.out.854; 28.mar.860; 9.mai.860) se ocupam das petições de graça. O código comercial (lei nº 566, de 25.jun.850) estipulou os casos de quebra fraudulenta (art. 802) e de participação nela (art. 803), complementando a previsão da bancarrota pelo código criminal (art. 263). Três anos após a inauguração de nossa primeira estrada de ferro, o Reg. nº 1.930, de 26.abr.857, criminalizava empregados da ferrovia que, por omissão ou negligência, causassem acidentes com resultados

¹³¹ Rodrigues, Jaime, *O Infame Comércio*, Campinas, 2000, ed. Unicamp, p. 108; cf., entre ampla bibliografia, Conrad, Robert Edgar, *Tumbeiros*, S. Paulo, 1985, ed. Brasiliense; Florentino, Manoel Garcia, *Em Costas Negras*, Rio, 1995, ed. Arq. Nac; e o clássico *Veíger*, Pierre, *Fluxo e Refluxo*, trad. T. Gadzanis, S. Paulo, 1987, ed. Corrupio.

¹³² Osório Silva, Lígia, *Terras Devolutas e Latifúndio*, Campinas, 1996, ed. Unicamp; Bessa Antunes, Paulo, *A Propriedade Rural no Brasil*, Rio, 1985, ed. OAB-RJ; Menendes Motta, Márcia Maria, *Nas Fronteiras do Poder*, Rio, 1998, ed. V. Leitura; sobre os ecos contemporâneos dessa tragédia, MST, *Assassinatos no Campo*, S. Paulo, 1987, ed. Global; Fajardo, Elias, *A Violência no Campo*, Petrópolis, 1988, ed. Vozes.

de ferimentos ou morte (art. 98). A lei nº 2.033, de 20.set.871, conhecida por lei de reforma judiciária, e de onde proveio aquela atribuição dos delegados de polícia para processar -- sem julgar -- contravenções (art. 10), que chegaria ao código de processo penal de 1942 (art. 531 ss), criminalizou finalmente o homicídio culposo e as lesões corporais culposas (art. 19) e aprimorou o estelionato previsto no código (art. 21); foi ela regulamentada pelo dec. nº 4.824, de 22.nov.871¹³¹. A lei nº 1.099, de 18.set.860, criminalizou "loterias e rifas de qualquer espécie não autorizadas por lei" (art. 1º); o decreto nº 2.874, de 31.dez.861, que a regulamentou, ampliou a criminalização para abranger quem expusesse à venda bilhetes e loterias não autorizadas, ou ultrapassassem o território da autorização. O decreto nº 2.682, de 23.out.875, versava sobre a contrafação de marcas de indústria ou comércio. A lei nº 3.311, de 14.out.886, tratava dos hoje chamados crimes de perigo comum (incêndio, explosão, inundação). A dois anos e meio da abolição, a lei nº 3.279, de 28.set.885, equiparava "o acoutamento de escravos" à apropriação indébita de coisa alheia perdida (art. 4º, § 3º).

¹³¹ Sobre essa lei, Nequete, Lentine, *O Poder Judiciário no Brasil a partir da Independência*, P. Alegre, 1972, ed. Sulina, v. 1, pp. 78 ss.

III O Código Penal de 1890

1. As cartas que decidirão o jogo fraudado das relações econômicas e sociais na república positivista foram marcadas ainda na metade do século XIX. Com efeito, naquele 1850 em que a finalmente eficaz proibição do tráfico internacional de escravos passava a incrementar um tráfico interprovincial endereçado à florescente cultura do café no sudeste, naquele, 1850 em que se promulgava o código comercial também¹³⁴ a terra era transformada em mercadoria corrente, referendando-se o seu controle por parte dos grupos dominantes do país¹³⁴. Com as terras devolutas subordinadas ao capital – eis que sua aquisição somente se operaria através de compra – tínhamos uma determinante essencial para as futuras relações de produção no ambiente agrário, que lograram manter na república modelos de exploração que evocam fortemente o escravismo¹³⁵. Paralelamente, iniciara-se um processo de industrialização que, se na década de 1850 dispõe de pouco

¹³⁴ Fragoso, João Luis, *O império escravista e a república dos plantadores*, em Linhares, Maria Yedda (org.) *História Geral*, cit., p. 133, referindo-se à lei nº 601, de 18.set.850.

¹³⁵ Como a "parceria" e o "colonato"; cf. João Luis Fragoso, loc. cit. O pagamento de salários reduzidos em contraposição ao fornecimento, a preços escorchantes, de gêneros de primeira necessidade, colocava o trabalhador como um endividado permanente que, especialmente em regiões remotas – como na extração da borracha –, não dispunha de meios para quitar seu débito e abandonar a fazenda (cf. Caio Prado Júnior, op. cit., p. 212). Assinala Alberto Passos Guimarães que a abundância de mão-de-obra ociosa e a decorrente incapacidade de negociação dos trabalhadores nacionais permitiam seu recrutamento "a níveis de remuneração tão baixos que os colocavam praticamente em pé de igualdade dos custos de manutenção do escravo" (*As Classes Perigosas*, Rio, 1981, ed. Graal, p. 94). As frequentes reclamações da diplomacia estrangeira sobre as condições de trabalho dos imigrantes (na Itália chegou-se a um projeto de lei proibindo a imigração para o Brasil) constituem um depoimento eloquente. Um documento apresentado ao ministro da Agricultura, Comércio e Obras Públicas, em 1869, sugeria a importação de "trabalhadores chineses", argumentando estarem eles "afeitos a ténue salário e parca subsistência" (Alberto Passos Guimarães, op. cit., p. 95). Na primeira década republicana, muitos grupos – entre eles, acadêmicos de direito paulistas – optavam-se à imigração chinesa com argumentos claramente racistas (cf. Schwarcz, Lília Moritz, *O Espetáculo das Raças*, S. Paulo, 1993, ed. Cia das Letras, p. 185).

mais de 60 estabelecimentos industriais, contabilizará 3.258 em 1907 e 13.336 em 1920; na transição para o capitalismo, o setor têxtil predomina, seguido pelos de gêneros alimentícios (que o ultrapassará no primeiro quartel do século XX), vestuário, couros, velas e outros bens de consumo¹³⁶. Poucas décadas separam a máquina a vapor (no decênio de 1850, 20 empresas de navegação e 8 estradas de ferro) da energia elétrica, que na província do Rio de Janeiro dispunha de menos de 1.000 kw em 1900 contra 61.925 kw em 1920¹³⁷. Indústrias subsidiárias de grandes empresas estrangeiras principalmente norte-americanas (química e farmácia, montagem de veículos motores, pneumáticos, frigoríficos, aparelhos elétricos, alimentos) começam a estabelecer-se no país, especialmente após a primeira guerra. A crise financeira do início da república (o *encilhamento*) conduzirá a políticas deflacionárias, na presidência de Prudente de Moraes, que culminarão na moratória (*funding loan*) negociada por Campos Sales em Londres; a dívida externa brasileira, orçada em menos de 30 milhões de libras quando da proclamação da república, estará multiplicada por três em 1910 e chegará ao valor de 250 milhões de libras em 1930¹³⁸. Temos aí uma síntese, sem dúvida lacunosa porém suficiente para nossas finalidades, da estrutura econômica da primeira república: basicamente agroexportadora (ao lado da posição privilegiada – até as respectivas crises – do café e da borracha, ainda o açúcar – já decadente –, o algodão, o cacau etc), baseada na grande propriedade rural, com uma incipiente industrialização na qual a exploração capitalista da força de trabalho praticamente não tem limites, à qual vêm agrupar-se empresas estrangeiras, sinalizando a dependência do capital externo sobre a qual depõem os números da dívida. A tal estrutura correspondem relações sociais de dominação que, no campo, expressam-se –

¹³⁶ Caio Prado Júnior, op. cit., pp. 192 e 260 ss; M. Maurício de Albuquerque, op. cit., pp. 452 ss.

¹³⁷ AA. VV., A CERJ e a História da Energia Elétrica no Rio de Janeiro, Rio, 1993, ed. CERJ, p. 31.

¹³⁸ Caio Prado Júnior, op. cit., p. 211.

pela ponta dominante – no “coronelismo” que encadeia a grande propriedade rural ao poder estadual¹³⁹, na base do que se chamou “política dos Governadores”; na ponta dominada, aos escombros sociais da escravidão eventualmente aproveitados, e ao lado dos pobres livres cujas desconfortáveis estratégias de sobrevivência provinham ainda do escravismo (tropeiros, sitiantes, agregados, camaradas¹⁴⁰), tínhamos os contingentes de imigrantes, nos quais as oligarquias apostavam também para realizar um “embranquecimento” nacional. Nas cidades em que se concentravam indústrias, o proletariado lutava pelas mais elementares limitações à exploração de seu trabalho¹⁴¹, luta que se acirrou especialmente com o movimento anarquista¹⁴²; convém mencionar desde logo os desclassificados urbanos (prostitutas e cântens, desempregados, capoeiras e mais tarde malandros etc), alvos explícitos do sistema penal da primeira república. No próprio ano da abolição, a Câmara dos Deputados votava um projeto de criminalização da vadiagem¹⁴³ – com privação da liberdade até 3 anos para reincidentes –, tentando exorcizar os medos da conjuntura: no campo, “hordas” de libertos que vagariam pelas estradas “a furtar e rapinar”, nas palavras de um parlamentar¹⁴⁴, e, na cidade, as maltas

¹³⁹ Para Victor Nunes Leal, “a política dos coronéis consistia precisamente nesta reciprocidade: carta-branca, no município, ao chefe local, em troca do seu apoio eleitoral aos candidatos bafejados pelo governo do estado” (Coronelismo, Enxada e Voto, S. Paulo, 1975, ed. Alfa-Omega, p. 88).

¹⁴⁰ Cf. Carvalho Franco, Maria Sylvia, Homens Livres na Ordem Escravocrata, S. Paulo, 1983, ed. Kairós.

¹⁴¹ Lahmeyer Lobo, Eulália Maria (org.), Rio de Janeiro Operário, Rio, 1992, ed. Access; Carone, Edgard, Movimento Operário no Brasil, Rio, 1979, ed. Difel, 2 vols.; Koval, Boris, História do Proletariado Brasileiro, S. Paulo, 1982, ed. Alfa-Omega; Khoury, Yara Aun, As Greves de 1917 em São Paulo, 1981, ed. Cortez.

¹⁴² Addor, Carlos Augusto, A Insurreição Anarquista no Rio de Janeiro, Rio, 1986, ed. Dois Pontos; Arnoni Prado, Antonio (org.), Libertários no Brasil, S. Paulo, 1986, ed. Brasiliense.

¹⁴³ Cf. a excelente análise de Sidney Chalhou, Trabalho, Lar e Botequim, Campinas, 2001, ed. Unicamp, pp. 66 ss.

¹⁴⁴ Apud Chalhou, op. cit., p. 67.

de capoeiras e todos aqueles pobres desocupados dos balcões comerciais ou não admitidos na disciplina fabril.

2. No discurso deste novo sistema penal, a *inferioridade jurídica* do escravismo será substituída por uma *inferioridade biológica*; enquanto a primeira, a despeito de fundamentos legítimos importados do evolucionismo, podia reconhecer-se como mera decisão de poder, a segunda necessita de uma demonstração científica. Neste sentido, poderíamos afirmar que o racismo tem uma explicável permanência no discurso penalístico republicano, que se abebera nas fontes do positivismo criminológico italiano e francês para realizar as duas funções assinaladas por Foucault: permitir um corte na população administrada, e ressaltar que a neutralização dos inferiores "é o que vai deixar a vida em geral mais sadia; mais sadia e mais pura"¹⁴⁵. A contribuição do pensamento médico, neste transe de seu acasalamento com a técnica policial, merece especial atenção. Na metade do século XIX, constituiu-se a medicina social: "o médico torna-se planejador urbano"¹⁴⁶. Além de diagnosticar a doença presente no espaço insalubre, propõe-se um novo tipo de prática, organiza-se como poder político, torna-se um braço a serviço da prosperidade e segurança do estado"¹⁴⁷. Podemos ter uma ideia de como este poder médico-policial se exerce, "devassando corpos, casas e quintais"¹⁴⁸, mirando apenas dois episódios: a demolição do cortiço Cabeça de Porco, em 1893, sob os auspícios da Inspetoria Geral de Higiene (dos desuroços do cortiço nascerão os casebres da primeira "favela" no vizinho morro de Santo Antônio; a palavra "favela" só estará disponível, nesta acepção, quatro anos mais

¹⁴⁵ Foucault, Michel, *Em Defesa da Sociedade*, trad. M.E. Galvão, S. Paulo, 2000, ed. M. Fontes, p. 305.

¹⁴⁶ Machado, Roberto *et alii*, *Danação da Norma*, Rio, 1978, ed. Graal, p. 155.

¹⁴⁷ Benichmol, Jaime Larry, *Pereira Passos: um Haussmann Tropical*, Rio, 1991, ed. Bib. Carioca, p. 115.

¹⁴⁸ Garcez Martins, Paulo César, *Habitação e Vizinhaça*, em Novais, Fernando A. (org.) *História da Vida Privada no Brasil*, S. Paulo, 1998, ed. Cia das Letras, v. 3, p. 144.

tarde, quando tropas vindas de Canudos estacionarem no morro da Providência), e a revolta da Vacina, em 1904¹⁴⁹. O pé-na-porta sanitário se fundamenta num discurso cujas metáforas foram incorporadas por criminólogos e juristas, na conjuntura favorável da invenção europeia das medidas de segurança¹⁵⁰ (as quais no entanto só ingressarão *expressamente* no direito penal brasileiro em 1940). Num livro de 1894, Viveiros de Castro divulga um pensamento segundo o qual o crime "é o efeito do *contagio*, transmite-se como um micróbio"¹⁵¹. Dois anos mais tarde, o futuro chefe de polícia, Aurelino Leal, daria a lume seu *Germens do Crime*¹⁵²; um oficial superior do exército publicava em 1926, na edição inaugural da Revista Policial, artigo intitulado *O micróbio do crime*¹⁵³. Como esses transportes são geralmente recíprocos, um médico contemporâneo daquele oficial – a expressão higiene mental entrava em moda – se preocupava com as taxas "de incapazes, de mendigos, de criminosos, de anormais de todo gênero que dificultam e oneram, pesadamente, a parte sã e produtiva da sociedade"¹⁵⁴. A intervenção higienista, que das casas e quintais

¹⁴⁹ Chalhoub, Sidney, *Cidade Febril*, S. Paulo, 1996, ed. Cia das Letras; Sevcenko, Nicolau, *A Revolta da Vacina*, S. Paulo, 2001, ed. Scipione.

¹⁵⁰ Do conceito garofaliano de "temibilidade" se passará ao de periculosidade. Para o debate fundador das medidas de segurança, travado no seio da velha União Internacional de Direito Penal, cf. Aníbal Bruno, *Perigosidade Criminal e Medidas de Segurança*, Rio, ed. Rio, pp. 13 ss. O anteprojeto de código penal suíço, redigido por Carlos Stooß em 1893, foi o primeiro a contemplá-las. Cf. Ataliba Nogueira, J. C., *Medidas de Segurança*, S. Paulo, 1937, ed. Saraiva; Stevenson, Oscar, *Problemas das Medidas de Segurança*, Rio, 1965, ed. F. Bastos; Machado Alvirá, Rui Carlos, *Uma Pequena História das Medidas de Segurança*, S. Paulo, 1997, ed. IBCCrim; Moraes Ribeiro, Bruno de, *Medidas de Segurança*, P. Alegre, 1998, ed. Fabris; Reale Ferrari, Eduardo, *Medidas de Segurança e Direito Penal*, S. Paulo, 2001, ed. RT; Virgílio Mattos, *Trem de Doido*, B. Horizonte, 1999, ed. Una.

¹⁵¹ A Nova Escola Penal, Rio, 1894, ed. D. Magalhães, p. 363.

¹⁵² Leal, Aurelino, *Germens do Crime*, Salvador, 1896, ed. Magalhães.

¹⁵³ Tórtima, Pedro, *Crime e Castigo para além do Equador*, B. Horizonte, 2002, ed. Inédita, p. 153.

¹⁵⁴ Freire Costa, Jurandir, *História da Psiquiatria no Brasil*, Rio, ed. Xenon, p. 97. Cf. também o imprescindível Carrara, Sérgio, *Crime e Loucura*, Rio, 1998, ed. EdUERJ.

do "bota abaixo" modernizador se deslocara para os próprios corpos, na revolta da Vacina, invadia agora a subjetividade pelos caminhos da "degenerescência" e da "higiene mental"; para a viabilização política deste percurso, foi preciso que ela houvesse chegado à teoria da pena. No livro de um dos fundadores da escola de Polícia do Rio¹⁵⁵, Gizlene Neder percebe essa chegada: "no lugar do castigo, remédios"¹⁵⁶. Este saber médico, que influencia cada vez mais as decisões judiciais criminais, e mesmo na prática decide diretamente uma parcela dos casos (inimputáveis por doença mental), se acasalará clinicamente com a técnica policial num lugar arquitetônico especial: o anfiteatro dos institutos de medicina legal, na superação da luta por poder travada entre a academia e as repartições médico-policiais, segundo um modelo que Nina Rodrigues implantaria na Bahia e Afrânio Peixoto aplicaria no Rio¹⁵⁷. Bastem-nos tais notas para a compreensão dessas trocas, que edificaram o manicômio judiciário; que ainda hoje perduram, se já não nos salões nobres das universidades, onde viveram, certamente nos obscuros laudos que cotidianamente orientam o poder punitivo; que prestamente acorreram à épica moderna da eletricidade para inventar as terapias do eletrochoque, da eletrotortura e — no país das grandes empresas e da pesquisa científica — da cadeia elétrica.

3. Embora convicto de que, após a abolição, as reformas "que podem ser votadas por lei" seriam "insignificantes" perante as culturais, Joaquim Nabuco apresentou projeto de lei, em outubro de 1888, para que fossem as leis penais adaptadas à nova

¹⁵⁵ Blyso de Carvalho, *A Polícia Carioca e a Criminalidade Contemporânea*, Rio, 1910, ed. Imp. Nac. A escola foi fundada em 1912.

¹⁵⁶ Neder, Gizlene, *Discurso Jurídico e Ordem Burguesa no Brasil*, P. Alegre, ed. Fabris, p. 93.

¹⁵⁷ Cf. Corrêa, Mariza, *As Ilusões da Liberdade*, Bragança Paulista, 1998, ed. Edusp, pp. 128 ss. Já em 1907, no novo regulamento do serviço policial no Rio efetuado pelo decreto nº 6.440, de 30 mar. 1907, o Serviço Médico Legal era "organizado como seção autônoma" (arts. 8º, § 3º, e 70 ss).

situação¹⁵⁸. A dissolução da Câmara dos Deputados impediu que o projeto se convertesse em lei. Contudo, sensibilizado pela idéia, no primeiro semestre de 1889 João Vieira de Araújo — catedrático de direito criminal na Faculdade do Recife — elaborou o anteprojeto de uma *Nova edição oficial do Código Criminal*, submetendo-o ao ministro da Justiça, que, por aviso de 12 de junho, designou para apreciá-lo uma comissão, de cujos trabalhos João Batista Pereira — professor no Rio de Janeiro — seria o relator. Em 10 de outubro de 1889 a comissão sugeriu que, ao invés de simples nova edição acrescida de "figuras novas", se procedesse a uma completa revisão da legislação penal. Aceita a sugestão, o ministro Cândido de Oliveira incumbiu exclusivamente Batista Pereira do "trabalho da revisão do Código Criminal". Se corresponder à verdade a informação acreditada de que, ao proclamar-se a república, a revisão da parte geral já estaria pronta¹⁵⁹, teríamos que tal trabalho consumira apenas um mês ao jurista. O fato é que, proclamada a república, Batista Pereira interrompeu seu trabalho: nas suas palavras, "larguei de mão o trabalho de revisão"¹⁶⁰. Em junho de 1890, o ministro da justiça do Governo Provisório, Campos Salles, renovou o convite nos mesmos termos, ou seja, para uma *revisão* do código criminal,

¹⁵⁸ Nabuco, Joaquim, *O Abolicionismo*, Rio, 1999, ed. N. Fronteira, p. 237. Um quarto de século após a abolição, em plena república, edições do código comercial ainda estampavam a proibição de "dar-se em penhor comercial escravos" (art. 273); cf. Braga Júnior (org.) *Código Commercial Brasileiro*, Rio, 1914, ed. EFDI, p. 48.

¹⁵⁹ "Já havia preparado a Parte Geral, quando foi proclamada a República" (Fragoso, Heleno, *Lições*, op. cit., PG, p. 62); "e tinha elaborado a parte geral, quando foi proclamada a República" (Siqueira, Galdino, *Direito Penal Brasileiro*, Rio, 1932, ed. Jacyntho, v. I, p. 10); nas imprescindíveis *Notas Históricas* do próprio Batista Pereira (publicadas, em 14 capítulos, por Raja Gabaglia [org.] *Revista de Jurisprudência*, Rio, 1898-1899, ed. Aldina, vols. II a VI) a afirmação é algo diferente: "estava já articulada a parte geral do Código, quando a 15 de novembro, um mês depois, sobreveio inopinada a sedição militar", sugerindo houvesse ele se antecipado nessa tarefa ao ato de sua designação, datado de 14 de outubro de 1890.

¹⁶⁰ *Notas Históricas*, cit., em *Rev. Jur.* IV, p. 259. Trechos subsequentes entre aspas, sem remissão distinta, provêm dessa fonte.

encarecendo apenas – talvez por ignorar a já demonstrada celeridade de Batista Pereira – a “apresentação urgente do trabalho”. (A coincidência de convidar o governo republicano o mesmo jurista que o governo imperial convidara para a reforma do mesmo código, nas mesmas condições, demonstra suficientemente que na realidade nada estava mudando muito.) Batista Pereira concluiu seu trabalho “ao cabo de pouco mais de três meses”; determinando Campos Salles sua publicação pela Imprensa Nacional. Uma comissão foi constituída para examinar o anteprojeto, não chegando a consumir duas semanas em sua tarefa¹⁶¹, que concluiu por adotá-lo “na sua quase totalidade”. Foi o código penal promulgado pelo decreto nº 847, de 11.out.890. A *vacatio legis* original de seis meses (art. 411) foi alterada pelo decreto nº 1.117, de 6.dez.890, que antecipou a vigência do código, segundo um critério diferenciado¹⁶².

4. A rapidez desses procedimentos costuma ser invocada na literatura jurídico-penal brasileira como uma das razões para as críticas impiedosas que o código penal de 1890 sofreu¹⁶³. Parte dessa literatura se esquece da natureza puramente revisional de tais procedimentos – que exsurge cristalinamente das fontes primárias disponíveis – e incide por vezes na contradição de elogiar no código criminal de 1830 quase a mesma solução (por vezes a

¹⁶¹ Integrada por José Júlio de Albuquerque Barros (barão de Sobral), Francisco de Paula Belfort Duarte e Luiz Antônio dos Santos Werneck, reuniu-se pela primeira vez em 29 de setembro; o código penal seria promulgado doze dias depois!

¹⁶² A vigência se iniciou no Distrito Federal em 30 de dezembro de 1890; nos estados litorâneos, do Rio Grande do Sul ao Pará, e em Minas Gerais, em 1º de fevereiro de 1891; nos estados de Goiás, Mato Grosso e Amazonas, em 1º de março de 1891.

¹⁶³ Bem representadas no severo juízo de João Monteiro, recorrentemente citado: “o pior de todos os códigos conhecidos”. Para o maior de seus comentaristas e um dos fundadores da dogmática jurídico-penal brasileira, contudo, tais críticas eram “não raro exageradas e destinadas de razão” (Costa e Silva, Antônio José, Código Penal dos Estados Unidos do Brasil, Rio, ed. Cia. Nacional, p. II).

mesmíssima solução) que no texto de 1890 lhe provoca aversão. Na verdade, o desprestígio do código penal de 1890 proveio de seu fracasso na programação criminalizante dos alvos sociais do sistema penal da Primeira República, fracasso diretamente ligado à circunstância de não passar ele de um decalque alterado do diploma anterior. Uma boa prova dessa deficiência – muito mais política do que técnica – do código de 1890 está no fato de que a criminalização daqueles alvos sociais – imigrantes indesejáveis, anarquistas, prostitutas e cáptens etc – foi empreendida através de leis extravagantes, ou de leis que alteravam o texto original do código. Não por acaso, essa profusão de leis – em paralelo à profusão de anteprojeto de códigos que substituísssem o de 1890 – culminaria por uma Consolidação das Leis Penais, como veremos. Essas leis extravagantes, contudo, não despertam na literatura críticas similares àquelas dirigidas ao velho código. Talvez a natureza ideológica de tais críticas seja similar à daquelas que, nos dias que correm, queixam-se do CP 1940, reformado em 1985, como “legislação antiquada”, em descompasso com “novas realidades”, mas silenciam sobre a chamada lei dos crimes hediondos e correlatas.

5. Adotando a divisão bipartida (crime e contravenção – art. 2º), o Código Penal de 1890 contemplava o princípio da legalidade, proibia o emprego de analogia “para qualificar crimes ou aplicar-lhes penas” (arts. 1º), e estipulava a retroatividade benigna da lei nova que abolisse o crime ou lhe cominasse “pena menos rigorosa” (art. 3º). O caráter subjetivo e pessoal da responsabilidade criminal vinha explícito no texto dos artigos 24 e 25: o primeiro deles isentava de pena “ações ou omissões contrárias à lei penal que não forem cometidas com intenção criminosa, ou não resultarem de negligência ou imperícia”; o segundo proclamava que “a responsabilidade criminal é exclusivamente pessoal”; e seu parágrafo, versando a hipótese de crimes “em que tomarem parte membros de corporação, associação ou sociedade”, frisava que a responsabilidade penal só recairia “sobre

cada um dos que participarem do fato criminoso". A tentativa era definida segundo o modelo clássico do dolo com respeito ao delito consumado ("com intenção de cometê-lo"), do "começo de execução" e da frustração "por circunstâncias independentes da vontade do criminoso" (art. 13). Reconhecia o código a impunibilidade dos atos preparatórios (art. 10), do crime impossível (art. 14, par. ún.), bem como da tentativa de contravenção e de crime aos quais não estivesse cominada pena superior a um mês de prisão celular (art. 16). Distinguiam-se autoria (art. 18) e cumplicidade (art. 21); nesta última, segundo prática ainda predominante, incluíam-se casos de receptação e favorecimento (art. 21, §§ 3º e 4º). A responsabilização objetiva do mandante "por qualquer outro crime que o executor cometer" (art. 19, § 1º), em franca oposição aos já citados artigos 24, 25 e 26, era um pouco atenuada pela regra segundo a qual não prevaleceria a responsabilidade do mandante que "retirar a tempo sua cooperação no crime" (art. 20). Nos crimes de imprensa, estabelecia-se uma surpreendente responsabilidade solidária entre o autor, o proprietário da tipografia ou do jornal e o editor (art. 22), excluindo-se contudo a cumplicidade, cabendo à vítima escolher ("a arbitrio do queixoso") contra qual deles exerceria a ação penal (art. 23): o modelo brasileiro da responsabilidade sucessiva seria recuperado em 1923¹⁶⁴. A imputabilidade por imaturidade era absoluta até os 9 anos, e relativa ("que obrarem sem discernimento") entre os 9 e os 14 anos (art. 27, §§ 1º e 2º), disciplina que seria alterada em 1927¹⁶⁵. A violência física irresistível e a velha escusa do *casus*

¹⁶⁴ Através do decreto nº 4.743, de 31.out.923, art. 10 ss. A razão de ter-se Batista Pereira desligado da tradicional responsabilidade sucessiva foi o que ele chamou de "indecorosa indústria dos *testas-de-ferro*" (Notas Históricas, cit., VIII, p. 372).

¹⁶⁵ Através do decreto nº 17.943-A, de 12.out.927 (nosso primeiro Código de Menores), que subtraiu o menor de 14 anos a qualquer intervenção penal (art. 68), impunha aos maiores de 14 e menores de 18 anos internação em "escola de reforma" pelo prazo de 3 a 7 anos (art. 69, § 2º), e, em casos de crimes graves praticados por maiores de 16 e menores de 18 anos, provada a periculosidade e a "perversão moral", determinava-lhes a aplicação da pena minorada da cumplicidade, solução prevista no artigo 65 do Código Penal (art. 71), recomendando apartação prisional dos adultos (art. 77).

(art. 27, §§ 5º e 6º) situavam-se ao lado da imputabilidade por "imbecilidade nativa ou enfraquecimento senil" e dos surdos-mudos não educados (art. 27, §§ 3º e 7º), e também daquela importação bávara que daria tanto que falar, a "completa privação dos sentidos e da inteligência" (art. 27, § 4º)¹⁶⁶. Prevvia o código a obediência hierárquica (art. 28), o estado de necessidade (arts. 32, § 1º e 33) e a legítima defesa (arts. 32, § 2º e 34); esta última não admitia a provocação (art. 34, § 4º), e era especialmente prevista para a antiga hipótese do invasor noturno da casa e para a resistência a ordens ilegais (art. 35). Manejava o código as penas de prisão celular, banimento — logo proscrita pela Constituição de 1891¹⁶⁷ —, reclusão, prisão com trabalho, prisão disciplinar, interdição, suspensão ou perda do emprego público, inabilitação para o emprego público e multa (art. 43)¹⁶⁸. Embora a privação da liberdade, com seu cardápio técnico de regimes, assumisse uma

¹⁶⁶ O decreto nº 4.780, de 27.dez.923, substituiu a palavra "privação" por "perturbação" (art. 38), curvando-se às críticas dirigidas à duvidosa capacidade de ação de alguém completamente privado dos sentidos e da inteligência. Num parecer elaborado em 1897 para o Instituto dos Advogados Brasileiros, Batista Pereira alegara ter ocorrido erro de publicação; cf. Galdino Siqueira, *Direito Penal Brasileiro*, cit., v. I, p. 371. Também em suas *Notas Históricas* Batista Pereira reiteraria que "em vez de *privação* dos sentidos e de inteligência o texto dizia *perturbação*" (VIII, p. 374). Vieira de Araújo considerou tardia a explicação, redarguindo-lhe Batista Pereira com o original do texto (Notas Históricas, VIII, p. 376).

¹⁶⁷ *Ar. 72, § 20. Fica abolida a pena de galés e a de banimento judicial. Se levamos em conta que vadios e capoeiras estavam sujeitos a recolhimento, por 1 a 3 anos, em "colônias penais que se fundarem em ilhas marítimas ou nas fronteiras do território nacional" (art. 400), e, caso fossem estrangeiros, a deportação (art. 400, par. ún.), bem como os poderes excepcionais dos frequentes estados de sítio, compreenderemos como na verdade o banimento continuou a ser intensamente praticado na primeira república, a despeito da proibição constitucional.*

¹⁶⁸ A partir de uma observação de Escorel, Macedo Soares registra a presença, na Parte Especial do código de 1890, de outras penas, tais como a privação do exercício de profissão (art. 300, § 2º), a perda do pátrio-poder e da herança, a destituição do tutor ou curador (art. 277, par. ún.), além da deportação mencionada na nota anterior, entre outras. Cf. Macedo Soares, Oscar de, *Código Penal*, Rio, 1906, ed. Garnier, p. 139.

posição central no discurso de autoridades e juristas¹⁶⁹, na prática do sistema penal se dava algo semelhante ao que Faoro percebeu na economia: "a herança mercantilista envolve, controla e tritura os desígnios dos estadistas"¹⁷⁰, ou seja, a intervenção corporal – visível na deportação sistemática de imigrantes e capoeiras, nos açoites aplicados em tombadilhos da Armada, na chacina de Canudos, nas sevícias que os revoltosos da Vacina sofriam antes de, postos a ferro no porão de um paquete, serem despejados no Acre – a intervenção corporal não deixa o proscedimento do controle social penal. Proclamava o código que "não há penas infamantes" (art. 44)¹⁷¹. Mantinha-se o sistema do dia-multa, regulado "pelo que o condenado puder ganhar em cada dia por seus bens, emprego, indústria ou trabalho" (art. 58). Minucioso conjunto de circunstâncias agravantes e atenuantes (arts. 36 a 42), integrado pela proibição de dupla valoração da agravante que constituísse elemento do crime (art. 37), permitia a individualização das penas, que a Parte Especial cominava em escalas com patamares

¹⁶⁹ O relatório de 1891 do ministro da Justiça mencionava "o sistema da Philadelphi, combinado com o de Auburn, e modificado pelo método irlandês, numa palavra, o de Crofton"; segundo Batista Pereira, "evitando os perigos e inconvenientes do sistema pensilvânico, (...) e fugindo igualmente dos que são peculiares ao auburnismo, o único que entre nós tem sido praticado em escala modesta, o legislador brasileiro adotou o sistema progressivo irlandês, a que Walter Crofton ligou seu nome" (Notas Históricas, cit., v. VI, p. 230). Os maiores defensores da prisão celular foram Lima Drummond e A. Bezerra da R. Moraes; este último faz de apaixonada defesa num livro (Estudo sobre os Sistemas Penitenciários, Rio, 1915, 2ª ed., ed. Jacintho). Cf. também Evaristo de Moraes, Prisões e Instituições Penitenciárias no Brasil, Rio, 1923, ed. Cons. Candido de Oliveira (para o CP de 1890, pp. 48 ss).

¹⁷⁰ Os Donos do Poder, cit., v. 2, p. 502.

¹⁷¹ Dos participantes da revolta da Vacina dizia o chefe de polícia, em relatório oficial, que constituíam "fezes sociais" (Sevcenko, A Revolta da Vacina, cit., p. 71); transcrevendo considerações de Aureliano Leal, pode-se ler em Galdino Siqueira, acerca dos imigrantes a serem deportados, que "nosso excessivo espírito de tolerância, nossa bondade natural" (aos quais provavelmente se deveria a proscrição de penas infamantes) estavam reduzindo o Brasil a "uma espécie de cano de esgoto dos detritos de outros países" (op. cit., v. I, p. 120).

mínimo e máximo¹⁷². Prazia o código o livramento condicional numa chave que substancialmente o inseria no direito de graça: mediante ato do Poder Executivo, por provocação do diretor do estabelecimento penitenciário (art. 51), obrigando o condenado a residir em lugar designado e sujeitar-se à vigilância policial (art. 51, par.ún.)¹⁷³. A jurisdicionalização do livramento condicional, com intervenção do Conselho Penitenciário, viria com o decreto nº 16.665, de 6 de novembro de 1924, exatos dois meses após o decreto nº 16.588 introduzir entre nós a suspensão condicional da pena¹⁷⁴. Na Parte Especial, o livro II se ocupava "dos crimes em espécie", classificados em treze capítulos, e o livro III tratava das contravenções. Algumas disposições gerais associavam-se num minúsculo Livro IV.

6. A pesquisa das influências sofridas pelo código penal de 1890 – à exceção da mais ampla e estrutural, que provém de seu modelo direto, o código brasileiro imperial, e de outras de procedência bem evidente (como, por exemplo, algumas do código bávaro cuja tradução já circulava entre nós, tal qual anteriormente mencionado) – pode levar a alguns equívocos, por duas razões. A primeira delas consiste no que chamariamos hoje de "circularidade cultural" jurídica, e que Vieira de Araújo chamou de "empréstimos legislativos", na sua polêmica com João Monteiro¹⁷⁵: a incorporação por diversas legislações de paradigmas adotados

¹⁷² Por isso mesmo, cabe considerar o artigo 62 ("Nos casos em que este Código não impõe pena determinada e somente fixa o máximo e o mínimo") como reminiscência do texto de 1830, inadvertidamente mantido na sua revisão.

¹⁷³ Galdino Siqueira, que finalmente observara a assimilação de tal medida ao direito de graça, lembrava que a vigilância policial constituía, em diversas legislações, pena autônoma (op. cit., v. I, pp. 617 e 618).

¹⁷⁴ Cf. Auler, Hugo, Suspensão Condicional da Execução da Pena, Rio, 1957, ed. Forense, pp. 17 ss; Batista, Nilo, Alternativas à Prisão no Brasil, no volume Punidos e Mal Pagos, cit., pp. 126 ss.

¹⁷⁵ Vieira de Araújo, João, O Projeto do Código Penal e a Faculdade de São Paulo, Recife, 1895, ed. Nogueira Irmãos, p. 9.

por códigos penais oitocentistas "fortes" (por exemplo o francês, o bávaro, o brasileiro imperial etc), circunstância que dificulta sobretudo conclusões acerca desses paradigmas, que tanto poderiam provir do modelo original quanto da(s) legislação(ões) que posteriormente os incorporara(m). Em segundo lugar, temos o fato de que o autor do código só cuidou de registrar as influências sofridas vários anos após sua elaboração, e num ambiente de debate acadêmico no qual o recurso à filiação a determinada legislação aparece mais como argumento de autoridade que como subsídio historiográfico. Tomemos como exemplo a questão da divisão bipartida, em crime e contravenção, que o código penal de 1890 adotava (art. 2º), distinguindo-os categorialmente (arts. 7º e 8º). A opção pela divisão bipartida, cuja significação teórica e política não pode ser esquecida¹⁷⁶, foi atribuída por Batista Pereira em 1899¹⁷⁷, e todo mundo acreditou¹⁷⁸, ao código Zanardelli. Seria realmente necessário recorrer ao código Zanardelli, se o código imperial de 1830, cuja revisão se empreendia, afirmava que crime e delito eram "palavras sinônimas" (art. 1º), operando portanto com uma divisão bipartida, na qual as contravenções

¹⁷⁶ Para os partidários da divisão bipartida, na linha do pensamento ilustrado, o crime ofendia um direito subjetivo anterior ao contrato social e protegido por ele, enquanto a contravenção não passava de infração a convenções policiais, secundárias e localizadas, puníveis ao argumento de uma prevenção utilitarista (a "falta de observância das disposições preventivas das leis e dos regulamentos" se referia o art. 8º CP 1890). Ao contrário, perante a divisão tripartida — que o código francês de 1810 disseminou por toda parte — a contravenção é apenas o estrato mais baixo de um *continuum*, que abrange também o delito e o crime, todos enlaçados por uma ilicitude substancialmente idêntica. Cf. Padovani, Tullio, *La Tradizione Penalistica Toscana nel Codice Zanardelli*, em Vinciguerra, Sergio, *I Codici Preunitari*, cit., pp. 397 ss.

¹⁷⁷ "O novo código aceitou a classificação binária do código da Itália" (Notas Históricas, cit., em Rev. Jur., cit., v. IV, p. 15).

¹⁷⁸ Por exemplo, Macedo Soares: "O Código Penal, seguindo o italiano, e a maioria dos códigos modernos, adotou a divisão bipartida" (op. cit., p. 5). A improvável influência italiana é geralmente admitida: por todos, Bustos Ramírez, Juan e Valenzuela Bejas, Manuel, *Derecho Penal Latinoamericano Comparado*, B. Aires, 1981, ed. Depalma, p. 19.

eram também designadas por "crimes policiais"? Por outro lado, se verdadeira for a afirmação de Batista Pereira no sentido de que, quando da proclamação da República, "estava já articulada a parte geral do código", ao início da qual se colocaria a questão da divisão bipartida, é certo não ter ele consultado o código Zanardelli, cuja publicação oficial só ocorreu em 1º de dezembro de 1889. Se estivermos advertidos de que o código penal de 1890 não passa de uma revisão, com alterações e acréscimos, do código criminal de 1830, e mantivermos cautela quanto às falsas indicações provenientes do debate acadêmico posterior a ele, será possível identificar algumas influências. Há confiáveis vestígios de influência portuguesa, seja do projeto de 1861, refundido em 1864, do qual participou Levy Maria Jordão¹⁷⁹, seja da reforma de 1886, que modificaria o texto, de 1852, de inspiração francesa porém com traços brasileiros indiretamente recebidos (através do código espanhol de 1848). Assim, a expressa proibição de analogia (art. 1º) proviria do código português¹⁸⁰, tanto quanto a punibilidade dos atos de tentativa que constituam de *per se* delitos (art. 15)¹⁸¹, ou ainda a atenuante do "exemplar comportamento anterior" (art. 42, § 9º)¹⁸². Igualmente nítida é a influência do código bávaro, claríssima na debatida escusa da completa perturbação dos sentidos e da inteligência (art. 27, § 4º)¹⁸³, ou nas regras sobre consumação e resultado (arts. 11 e 12)¹⁸⁴, menos clara mas provável na violência física e coação moral irresistíveis (art. 27, § 5º)¹⁸⁵. Duvidosa é a influência do código holandês de 1886,

¹⁷⁹ Cf. Correia, Eduardo, *Direito Criminal*, Coimbra, 1971, ed. Almedina, v. I, pp. 106 ss.

¹⁸⁰ Mais especificamente, de seu artigo 18; cf. Galdino Siqueira, op. cit., v. I, p. 40.

¹⁸¹ Sobre tal dispositivo, dizia Costa e Silva: "o legislador pátrio, tendo copiado o artigo 12 do código português" (op. cit., p. 79).

¹⁸² "A fonte deste parágrafo é o código português, artigo 39" (Macedo Soares, op. cit., p. 130).

¹⁸³ No texto de Feuerbach, art. 121, inc. 9.

¹⁸⁴ Extraídos, respectivamente, dos artigos 38 e 37 do código bávaro.

¹⁸⁵ As palavras sugerem inspiração na tradução francesa disponível do código

reivindicada ardentemente por Batista Pereira¹⁸⁶, no aspecto específico da unificação das penas privativas da liberdade, matéria na qual a legislação flamenga foi pioneira. Contudo, o código de 1890 previa nada menos do que quatro penas privativas de liberdade (prisão celular, reclusão, prisão com trabalho obrigatório e prisão disciplinar – art. 43), e mesmo considerando que a primeira delas era cominada à quase totalidade dos crimes e até a certas contravenções (p. ex. arts. 391 a 398), é meio forte afirmar que o código as unificara, salvo no sentido de que, no cotidiano da execução penal, os equipamentos penitenciários promoviam – e seguiram promovendo, até a unificação de fato que ocorrerá em 1985 – uma uniformização que desafiava a programação legal. A verdade é que, sem embargo do pontual registro de afinidades (que chegam a incluir os códigos russo, húngaro, e alguns cantonais suíços como Zurich e Berna), e independentemente da atração comparativa exercida pelo importante e coevo código unitário italiano¹⁸⁷, o código penal de 1890 foi uma revisão do código criminal de 1830, influenciada aqui pelo código português, ali pelo bávaro, e talvez por alguns outros – porém – quanto a estes, ressalvado o óbvio impedimento diacrônico do italiano, as provas são insuficientes para conclusões preempatórias.

7. Já mencionamos a importância da programação criminalizante expressa em leis penais extravagantes na primeira República, eis que através delas é que se atingiam os alvos sociais do sistema penal. A defraudação do penhor agrícola, pela “alienação sem consentimento” ou pelo “desvio” da garantia, foi equiparada *quoad poenam* ao estelionato pelo dec. n° 169-A, de 19.jan.890

bávaro (art. 121, incs. 7 e 8). Cf. Vattel, op. cit., p. 105. Mas a excusa já constava, com redação menos analítica, do código imperial (art. 10, § 3°).

¹⁸⁶ “O autor da revisão penal de 1890 (...) enveredou pelo caminho desbravado pelo código da Holanda (...) que resolvera o problema de modo original, admitindo uma única pena privativa de liberdade” (Notas Históricas, VII, pp. 264 e 265).

¹⁸⁷ Com ele dialogava intensamente Vieira de Araújo, João, O Código Penal Interpretado, Rio, 1901, ed. Imp. Nac., v. I, *passim*.

(art. 18, § 2°). A primeira alteração no código foi anterior a sua própria vigência: os artigos 205 e 206, que criminalizavam a greve¹⁸⁸, tiveram sua redação modificada pelo dec. n° 1.162, de 12.dez.890. As penas da greve seriam elevadas, mais tarde, pelos decs. n° 4.269, de 17.jan.921 (art. 9°) e n° 5.221, de 12.ago.927 (art. 1°), o último dos quais a tornou inafiançável. O dec. n° 774, de 20.set.890, editado vinte dias antes da promulgação do código penal, abolira as penas de galés e reduziu a 30 anos as penas perpétuas, dispondo ainda sobre prescrição e detração da prisão preventiva sobre a pena. O dec. n° 949, de 5.nov.890, alterado pelo dec. n° 18, de 7.mar.891, estabeleceria o Código Penal da Armada, inspirado essencialmente no CP 1890; tal código, que previa a pena de morte (art. 39, al.a) por fuzilamento (art. 40), seria estendido ao Exército pela lei n° 612, de 29.set.899¹⁸⁹. Um Regulamento Processual Criminal Militar foi editado em 16.jul.895 pelo Supremo Tribunal Militar, a partir de discutível autorização legislativa (dec. leg. n° 149, de 18.jul.893, art. 5° § 1°). A euforia emissora daquilo que viria a chamar-se *encilhamento* explica os crimes falimentares e de diretores de companhias (supressão ou adulteração de livros, desvio de ativos etc) contidos no dec. n° 434, de 4.jul.891. A emissão não autorizada de títulos, e especialmente de debêntures, seria punida pelo dec. n° 177-A, de 15.set.893 (art. 3°). O furto de gado “de qualquer espécie”, pesadelo do latifúndio após a abolição, converte-se em crime de ação penal pública (dec. n° 121, de 11.nov.892, art. 1°), punido com a mais elevada das penas cominadas ao furto (art. 3°), e seria inafiançável mais tarde (lei n° 628, de 28.out.899, art. 2°, inc. II). A lei n° 123, de 11.nov.892, equiparava ao contrabando a navegação de cabotagem não autorizada. Previsto CP 1890, dentro da

¹⁸⁸ Na linguagem de Batista Pereira, os dois dispositivos, que objetivavam “proteger o trabalho e assegurar a sinceridade e a liberdade dos contratos (...) levantaram suspeitas na classe operária” (Notas Históricas, XII, em Jurisprudência, cit., v. V, pp. 248 e 249).

¹⁸⁹ Sobre ele, Esmeraldino Bandeira, Curso de Direito Penal Militar, Rio, 1915, ed. F. Alves; Crisolito de Gusmão, Direito Penal Militar, Rio, 1915, ed. Jacintho; Macedo Soares, Oscar, Código Penal Militar, Rio, 1902, ed. Garnier.

lógica dos sistemas penais do capitalismo industrial, que os vadios que violassem o "termo de tomar ocupação dentro de 15 dias" seriam recolhidos, por 1 a 3 anos, em "colônias penais que se fundarem em ilhas marítimas ou nas fronteiras do território nacional" (arts. 399, § 1º e 400). O dec. nº 145, de 11.jun.893, dispunha que a pena de "prisão correccional será cumprida em colônias fundadas pela União ou pelos Estados" para a "reabilitação" de "mendigos válidos, vagabundos ou vadios, capoeiras e desordeiros". Da matéria tratariam ainda a lei nº 947, de 29. dez.902, o dec. nº 4.753, de 28.jan.903, o dec.leg. nº 145, de 12. jul.903 e o dec. nº 1.872, de 29.mai.908, porém o desenho institucional mais completo está no dec. nº 6.994, de 19.jun.908, que reorganizou a Colônia Correccional de Dois Rios, na Ilha Grande, e alterou o código penal quanto à definição de "vadios, mendigos válidos, capoeiras e desordeiros" (arts. 51 e 52), bem como as penas a eles aplicáveis" (arts. 53 a 57). Em São Paulo, a colônia correccional foi construída na Ilha dos Porcos, hoje Anchieta, em Ubatuba. A lei nº 452, de 3.nov.897 (regulamentada pelo dec. nº 2.742, de 17.dez.897) equiparava ao contrabando o fabrico ou importação de rótulos que fizessem passar bebidas e outros produtos nacionais por estrangeiros. A lei nº 496, de 1º.ago.898, criminalizava a contrafacção de obra literária, científica ou artística (arts. 19 ss), inovando a matéria, já contida no CP 1890 (arts. 342 ss). A já citada lei nº 628, de 28.out.899, tornava pública a ação penal por furto (delito que, no CP 1890, ao lado do dano – em ambos, quando não houvesse prisão em flagrante – exceptuava-se a ação por denúncia do Ministério Público – art. 407, § 2º), tornava inafiançável o "furto de animais nas fazendas, pastos ou campos de criação ou cultura" (art. 2º, inc. II), e dispunha sobre processo (especialmente prisão em flagrante). Regulamentando o artigo 5º dessa lei, o dec. nº 3.475, de 4.nov.899, disciplinava a fiança, à qual não teriam direito, mesmo quando a única pena cominada ao delito fosse a multa, os réus "vagabundos ou sem domicílio" (art. 6º). A abolição, pela Constituição de 1891, da

pena de banimento judicial (art. 72, § 20) responde pela lei nº 1.062, de 20.set.903, que cominou ao crime de sedição (art. 107 CP 1890), substituindo a sanção constitucionalmente vedada, a pena de reclusão, aperfeiçoando-lhe ainda a redação (substituição da expressão "co-réus" por "co-autorês", ressaltando assim, como notaria Hungria, que "os cúmplices *stricto sensu* ficariam sujeitos à regra geral do artigo 64 do Código")¹⁹⁰. Alterando a disciplina liberal do CP 1890, que preconizava a entrega dos inimputáveis ("isentos de culpabilidade em resultado de afecção mental" – art. 29) às respectivas famílias ou seu recolhimento a hospital de alienados caso o exigisse a "segurança do público", o dec. nº 1.132, de 21.nov.903, que reorganizou a "assistência a alienados", criava "manicômios criminaes" para "alienados delinquentes". O dec. nº 4.780, de 2.mar.908, criou no Distrito Federal a Escola Correccional XV de Novembro; um ano antes, criara-se em São Paulo o Instituto Disciplinar; a infância pobre e desempregada ganhava os espaços de sua institucionalização republicana. O dec. nº 1.236, de 24.set.904, versava os crimes de violação de marcas de indústria e comércio (arts. 13 ss), modificando a disciplina do dec. nº 3.346, de 14.out.887 (que, por seu turno, tinha como precedente o dec. nº 2.682, de 23.out.875). A lei nº 1.102, de 21.nov.903, que disciplinou os armazéns gerais, criminalizou a emissão irregular de conhecimentos de depósito e *warrants* (art. 35). A partir de autorização legislativa constante do dec.leg. nº 1.631, de 3.jan.907, os serviços policiais no Distrito Federal foram reorganizados através do dec. nº 6.440, de 30.mar.907. Neste diploma, cabe destacar as meticolosas instruções para realização dos exames periciais: o cientificismo presente em tais disposições faz com que todo o título VII do decreto, concernente ao Serviço Médico Legal (arts. 70 a 121), ocupe nada menos que trinta páginas de livro! Para a identificação criminal adotou-se "o método instituído por D. Juan Vucetich" (art.

¹⁹⁰ Hungria, Nelson (colab. Lyra, Roberto) *Compêndio de Direito Penal*, P.E., Rio, 1936, ed. Jacyntho, p. 67.

127), e para que a fotografia de alguém integrasse a "galeria dos ladrões" eram necessárias duas condenações firmes. Criavam-se ainda o Boletim Policial, com uma "parte doutrinária" submetida à "orientação do chefe de Polícia" (art. 174), a inspetoria de polícia marítima, a inspetoria de veículos e o depósito de presos, bem como o regimento de custas policiais: uma "licença para ensaios carnavalescos" custava \$5000 (art. 232). A questão dos imigrantes, que já fora tratada pelo dec. n° 1.565, de 13.out.893 (o qual proibia o ingresso de doentes, mendigos, vagabundos ou suspeitos) recrudesce com o dec. n° 1.641, de 7.jan.907, conhecido por lei Adolpho Gordo¹⁹¹, regulamentado pelo dec. n° 6.486, de 23.mai.907. Interessam ainda à questão dos imigrantes os decretos n° 2.741, de 8.jan.913, e n° 4.247, de 6.jan.921: este último, que elevava de 2 para 5 anos o prazo de residência, proibia o ingresso de aleijados e cegos e cominava pena de prisão por 2 anos, seguida de nova expulsão, ao expulso que regressasse (art. 6°). O canhoneio das muitas batalhas judiciais sobre a legalidade e mesmo a constitucionalidade das expulsões seria silenciado pela reforma constitucional de 1926, que introduziu no rol das garantias uma curiosíssima garantia individual pelo avesso¹⁹². Revogando o dec. n° 1.785, de 28.nov.907, que dispusera sobre o assunto, o dec. n° 2.110, de 30.set.909 reformou a disciplina legal do peculato (arts. 1° a 5°), estabelecendo a comunicabilidade para co-autores e partícipes não qualificados (art. 6°), e ainda tratou da moeda falsa e da falsidade de títulos públicos, selos, outros documentos de arrecadação pública, e até bilhetes de estra-

¹⁹¹ Quinze anos depois, quando dos trabalhos legislativos da lei de imprensa, Lima Barreto se referiria à "perfeição torquemesca, em matéria de legislar", de Adolpho Gordo (Prosa Seleta, Rio, 2001, ed. N. Aguilar, p. 870). Sobre os abusos cometidos na expulsão de imigrantes, cf. Medeiros de Menezes, Lená, Os Indesejáveis, Rio, 1996, ed. UERJ. Para o cotidiano dos imigrantes no meio rural, cf. Alvim, Zuleika, Imigrantes: a vida privada dos pobres do campo, em Novais, Fernando A. (org.) História da Vida Privada no Brasil, cit., v. 3, pp. 215 ss.

¹⁹² Art. 72, § 33. É permitido ao Poder Executivo expulsar do território nacional os subditos estrangeiros perigosos à ordem pública ou nocivos aos interesses da República.

das de ferro (art. 21). O mesmo assunto seria retomado pelo dec. n° 4.780, de 27.dez. 923, incluindo o núcleo "se apropriar" no peculato (art. 1°), ampliando a falsidade documental, que alcançaria a ideológica em documento particular (art. 25) e o atestado médico de favor (art. 28), e criminalizando a interceptação de comunicação governamental telegráfica ou telefônica (art. 30, § 1°). Este decreto se ocupou ainda de prescrição (arts. 33 ss) e de processo (arts. 40 ss), mas convém realçar nele a alteração da polêmica cláusula do CP 1890 (art. 27, § 4: de "privação" para "perturbação" dos sentidos e da inteligência) pelo artigo 38, e a alteração na disciplina do crime continuado (art. 66, § 2° CP 1890) – que introduziria, até 1940, um conceito objetivo-subjetivo que postula "uma só resolução" – pelo artigo 39. Uma lei orçamentária (n° 2.321, de 30.dez.910) retornava à criminalização de rifas e loterias não autorizadas (art. 31). O dec. n° 2.416, de 28.jun.911, dispunha sobre extradição – inclusive de brasileiros (art. 1°) – e sobre aplicação extraterritorial da lei penal brasileira (arts. 13 e 14). O dec. n° 2.591, de 7.ago.912 sujeitava a multa de 10% quem emitisse cheque sem fundos (art. 7°): uma ressalva acerca de "outras penalidades" em que pudesse o emitente incorrer, com menção ao estelionato, foi o bastante para Vicente Piragibe vir a consolidar o texto, solução mantida no Código de 1940. Ao amplo espectro da prevaricação (arts. 207 ss CP 1890) equiparou-se a falsa perícia sobre invalidez de funcionários, pela lei n° 2.924, de 5.jan.915. Por vezes associada à questão dos imigrantes, o lenocínio e alguns delitos sexuais são objeto da lei n° 2.992, de 25.set.915¹⁹³, que alterou os artigos 266, 277 e 278 do CP 1890. De alguns crimes eleitorais trataram o dec. n° 12.193, de 6.set.916, e a lei n° 4.226, de 30.dez.920. Cabe mencionar a

¹⁹³ Sobre prostituição e sistema penal na primeira República, Evaristo de Moraes, Ensaios de Pathologia Social, Rio, 1924, ed. F. Bastos, pp. 139 ss (com ampla informação sobre o tratamento do assunto na França) e Reminiscências de um Rábula Criminalista, Rio, 1922, ed. L. Ribeiro, pp. 57 ss; cf. também Soares, Luiz Carlos, Rameiras, Ilhoas, Polacas..., S. Paulo, 1992, ed. Ática; Kushnir, Beatriz, Baile de Máscaras, Rio, 1996, ed. Imago.

promulgação do Código Civil, pela lei nº 3.071, de 1.º jan. 1916. A lei nº 4.242, de 5. jan. 1921, regulamentada pelo dec. nº 16.272, de 20. dez. 1923, elevou a inimizabilidade para 14 anos e autorizou a criação de um serviço de assistência à infância "abandonada e delinquente", dando início a um processo legiferante (o dec. nº 16.388, de 27. fev. 1924, regulamenta o conselho de assistência e proteção aos menores; o dec. nº 16.444, de 27. abr. 1924, dispõe sobre o abrigo de menores do Distrito Federal) que, passando pelo dec. leg. nº 5.083, de 1.º dez. 1926, culminará no Código de Menores (dec. nº 17.493-A, de 12. out. 1927). Para além de generalizar arraigadamente, até hoje, o uso linguístico forense de nomear como "menor" a criança ou o adolescente pobre, tal diploma criminalizou o abandono, a exposição a perigo, e – em quatro figuras que o CP 1940 reuniria numa só – os maus tratos. Da repressão ao anarquismo se ocupou o dec. nº 4.269, de 17. jan. 1921, criminalizando a incitação a dano, depredação e incêndio, a posse ilícita de dinamite, a apologia do anarquismo ou o elogio de anarquistas, bem como, já o notamos, elevando as penas da greve. O dec. nº 4.743, de 31. out. 1923, que pretendia "regular a liberdade de imprensa", se por um lado teve o mérito de recuperar a responsabilidade sucessiva (art. 10), abandonada pelo CP 1890, por outro participa intensamente da repressão ao anarquismo – crosta superficial do controle penal da classe operária em vias de organização –, criminalizando a apologia ao movimento, a publicação de segredo de Estado (art. 2º), ofensas ao presidente da República (art. 3º) ou "à moral pública e aos bons costumes" (art. 5º), e prevendo a expulsão "administrativamente" quando se tratasse de estrangeiro (art. 1º, § 1º). Ligados à repressão do anarquismo foram também os decretos nº 5.221, de 12. ago. 1927 (que, além de aumentar a pena para a greve, permitia a interdição de agremiações, sindicatos, centros etc) e nº 5.373, de 12. dez. 1927 (alterando penas, criminalizando a fabricação de bombas). Inter-correntemente legislara-se sobre embriaguez (dec. nº 4.294, de 6. jul. 1921), sobre processo e julgamento do crime de sedição (dec. nº 4.848, de 13. ago. 1924), e novamente sobre violação de marcas

de indústria e comércio (dec. nº 16.264, de 19. dez. 1923). O dec. nº 16.588, de 6. set. 1924, introduzira a suspensão condicional da execução da pena, e o dec. nº 16.665, de 6. nov. 1924, jurisdicionizou o livramento condicional, anteriormente em mãos do poder Executivo (art. 51 CP 1890), ainda que de quebra franqueasse à polícia revistar "estalagens, hospedarias e tavernas" (art. 17). O dec. nº 4.861, de 29. set. 1924, dispôs sobre prescrição de crimes políticos, estabelecendo a imprescritibilidade do réu homiziado ou residente no exterior (art. 3º). Pelo dec. nº 17.231, de 26. fev. 1926, entrou em vigor o Código de Justiça Militar, em substituição ao Regulamento Processual de 1895. O dec. nº 17.313, de 12. mai. 1926, punia a adulteração de adubos químicos. Do abandono de cargo público tratou o dec. nº 5.240, de 19. ago. 1927. Alguns delitos contra índios, que deviam considerar-se "sempre como praticados por superior contra inferior" (art. 23) para fins de agravamento da pena, foram previstos pelo dec. nº 5.484, de 27. jun. 1928. A alteração da lei de falências pelo dec. nº 5.746, de 9. dez. 1929, implicou mudanças nos crimes falimentares (arts. 168 ss). O dec. nº 5.776, de 16. jun. 1930, criminalizou abusos na radiodifusão. Sobre a criminalização de drogas ilícitas, remetemos ao minucioso levantamento da legislação pertinente já realizado¹⁹⁴. Por fim, recorde-se que a reforma constitucional de 1926, reduzindo o campo de abrangência do *habeas corpus* à "liberdade de locomoção", coartou uma criativa teoria brasileira que outorgara ao *writ* abrangência bem adequada ao autoritarismo da república oligárquica¹⁹⁵.

8. O carrascal de leis penais extravagantes, com ou sem alteração no texto do código, de que presta contas o arrolamento não exaustivo do parágrafo anterior, levou alguns autores – como Eugênio Cunha e Alvarenga Netto – a publicarem compilações

¹⁹⁴ Cf. Batista, Nilo, Política criminal com derramamento de sangue, em DS-CDS, nº 5/6, pp. 77 ss; também Carvalho, Salb de, A Política Criminal de Drogas no Brasil, Rio, 1996, ed. Luam.

¹⁹⁵ Cf. Pontes de Miranda, História e Prática do Habeas Corpus, Rio, 1972, ed. Borsó, v. I, pp. 159 ss; Tavares Bastos, José, O Habeas Corpus na República, Rio, 1911, ed. Garnier; Koerner, Andrei, Habeas Corpus, Prática Judicial e Controle Social no Brasil, S. Paulo, 1999, ed. IBCCrim.

para uso forense. O mais completo desses trabalhos, um *Código Penal Brasileiro, completado com as leis modificadoras em vigor*, de autoria do Des. Vicente Piragibe, que com paciência beneditina preservou a estrutura articulada do código, enxertando-lhe os acréscimos e alterações, seria oficializado como *Consolidação das Leis Penais*, através do dec. nº 22.213, de 14.dez.932¹⁹⁶. Nessa ocasião, uma comissão – integrada por Virgílio de Sá Pereira, Evaristo de Moraes e Mário Bulhões Pedreira – dedicava-se à revisão do projeto de código penal de autoria do primeiro deles¹⁹⁷, que não lograria converter-se em lei. Anteriormente, frustraram-se em 1913 o projeto de Galdino Siqueira, sequer examinado pelas casas legislativas¹⁹⁸, e em 1893 o projeto de revisão do CP 1890, elaborado pelo então deputado Vieira de Araújo, cuja tramitação, estimulada por um substitutivo do próprio professor do Recife de 1897, paralisara-se em 1899, mesmo após aprovado pela Câmara dos Deputados.

9. A programação criminalizante da primeira República espelha, com evidência didática, as contradições de um sistema penal que participa decisivamente da implantação da ordem burguesa porém traz consigo, e reluta em renunciar a ela, a cultura da intervenção corporal inerente ao escravismo¹⁹⁹. Esquemática-

¹⁹⁶ Piragibe, Vicente, *Consolidação das Leis Penais*, Rio, 1933, ed. J. do Comércio.

¹⁹⁷ Sá Pereira, Des. Virgílio de, *Código Penal da República dos Estados Unidos do Brasil*, Rio, 1928, ed. Imp. Nac. Em 1927, Sá Pereira publicara apenas a Parte Geral.

¹⁹⁸ Galdino Siqueira, *Projeto de Código Penal Brasileiro*, Rio, 1913, ed. J. de Brasil.

¹⁹⁹ Duas boas metáforas desta permanência estão: 1ª) na descrição que um delegado de polícia faz, em 1892, de uma jovem negra indiciada por furto, como se descrevesse uma escrava, ressaltando seus "bons dentes" (Boris Fausto, *Crime e Cotidiano*, S. Paulo, 1984, ed. Brasiliense, p. 54); 2ª) na saudade dos açoites, manifestada expressamente por um dos fundadores da Escola de Polícia dois anos antes de sua fundação: ao fracasso da "regeneração pelo trabalho" caberia reagir com a "moralização pelo gato de nove caudas" (Elysio de Carvalho, op. cit., p. 53). Significativamente, Elysio de Carvalho pode ser considerado também o fundador da investigação privada

mente, poderíamos ensaiar uma descrição das estratégias de tal sistema penal a partir da própria concepção, cara ao positivismo e por sua iniciativa inscrita na bandeira republicana, de ordem. Encontraríamos, assim, a criminalização²⁰⁰ direcionada à configuração e preservação de lugares sociais, cujas bem delimitadas fronteiras não poderiam ser ultrapassadas, funcional ou mesmo territorialmente. Enquanto cumprisse resignadamente suas intermináveis jornadas de trabalho na fábrica²⁰¹, o operário estava em seu lugar, confortado pelo oportuno discurso ético-jurídico que associa trabalho a honestidade e ociosidade a corrupção²⁰². Qualquer transposição das fronteiras deste lugar é perigosa: se um mero acidente de trabalho tende a ser interpretado, numa espécie de lombrosianismo caricatural, como uma predisposição à autovitimização²⁰³, o operário que se interesse pelo anarquismo ou pelo comunismo, ou se filie ativamente a uma associação de fins reivindicatórios ingressa numa zona de suspeição, que poderá materializar-se como criminalização secundária na simples greve de que participe. Enquanto permanecessem confinadas na zona que uma explícita geopolítica criminal lhes destinara²⁰³, as prostitutas estavam em seu lugar, amparadas por um curioso dis-

no Brasil, em papel similar ao de Vidocq na França (sobre este, cf. Kalifa, Dominique, *Naissance de la police privée*, 2000, ed. Plon), com sua Agência de Informação e Pesquisa, criada em 1913. Sobre ele, Tórtima, Pedro, *Polícia e Justiça de Mãos Dadas: a Conferência Judiciária Policial de 1917*, Niterói, 1988, mimeo, dissertação de mestrado UFF-ICHF, pp. 249 ss.

²⁰⁰ Em 1906, na fábrica têxtil do Ipiranguinha, em São Bernardo, a jornada era de treze horas, com intervalo de uma hora para o almoço (Carone, Edgard, *Movimento Operário*, cit., v. I, p. 52).

²⁰¹ Sobre esse discurso se detém Gizlene Nader (*Discurso Jurídico e Ordem Burguesa*, cit., pp. 51 ss) e Sidney Chalhouh (*Trabalho, Lar e Botequim*, cit., pp. 71 ss).

²⁰² Eulália Maria Lahmeyer Lobo detectou a persistência da culpabilização dos operários pelos acidentes de trabalho ainda nos anos trinta (Rio de Janeiro Operário, cit., pp. 63-64).

²⁰³ Na Conferência Judiciária-policial de 1917, o grande foro das políticas criminais da primeira República, tocou a Aureliano Leal relatar a matéria. Cf. Tórtima, Pedro, *Polícia e Justiça de Mãos Dadas*, cit., p. 245; ou cf. o representativo extrato deste trabalho em DS-CDS 2/253.

curso ético-jurídico que lhes reconhece uma "utilidade social"²⁰⁴, fora daí, passavam a constituir um escândalo, que a imprensa denunciaria e a polícia reprimiria severamente²⁰⁵, ou uma ofensa à saúde pública, como se vê na crua comparação de Hungria²⁰⁶. Gizlene Neder aprofundou o estudo da territorialização ordenatória no Rio, encontrando o que designou por *cidade quilombada* e *cidade europeia*, separadas por um *paredão da ordem*²⁰⁷. Ambigualmente autorizadas por um decreto municipal²⁰⁸, que excetuava da proibição de construírem-se "barracões toscos" os "morros que não tiverem habitação", as favelas começavam a configurar-se como residência de uma pobreza já associada à inflação²⁰⁹, cujos deslocamentos que se distraíssem do itinerário da fábrica, do comércio ou dos serviços domésticos atraíam igualmente suspeição. Estabelecidos os lugares sociais de seus alvos, o sistema penal da primeira República reagia às transgressões com basicamente duas sortes de medidas, proscritivas ou institucionalizantes. As medidas de natureza proscritiva estão representadas na construção de colônias em "ilhas marítimas" (art. 400 CP 1890), na expulsão de imigrantes e cáptens, no desterro dos revoltosos da Vacina para o Acre, no degredo de capoeiras ou oposicionistas políticos para Fernando de Noronha, bem como de oficiais sublevados para a ilha de Trindade – tudo isto, apesar da interdição constitucional da pena de banimento, garantia suspensa pelos subsequentes estados de sítio decretados. A am-

²⁰⁴ Formulado explicitamente na Conferência Judiciária-policial de 1917, este discurso sobreviveria no direito penal brasileiro: a prostituição como "mal necessário" em Hungria, Comentários, cit., v. VIII, p. 260.

²⁰⁵ Cf. o caso exemplar narrado por Evaristo de Moraes, *Reminiscências*, cit., pp. 57 ss.

²⁰⁶ "O que era um abcesso de fixação tornou-se uma septicemia generalizada" – Comentários, cit., v. VIII, p. 262.

²⁰⁷ Neder, Gizlene, *Cidade, identidade e exclusão social*, em *Tempo*, Rio, 1997, ed. R. Dumaré, v. 2, n° 3, pp. 106 ss.

²⁰⁸ Dec. n° 391, de 10.fev.903.

²⁰⁹ Em 1906, um urbanista, Backheuser, referindo-se à favela (atual Providência) dizia que "ali não moram apenas os desordeiros, os facinorosos". *Apud* Benchimol, Jaime, op. cit., p. 291.

plitude da mentalidade proscritiva já se delinçara, pelo avesso, na obstinada relutância positivista quanto à imigração de chineses²¹⁰. As medidas de natureza institucionalizante adquirem uma especialização, que se submete à nascente criminologia resultante do encontro entre os saberes médicos e as técnicas policiais: ao lado de uma penitenciária que pretende avocar-se a tarefa de adestrar para o trabalho, os asilos da mendicância inválida, as colônias correccionais para "vadios, mentilgos válidos, capoeiras e desordeiros", os abrigos de "menores" e os manicômios judiciais, tudo isso como que refletindo a "classificação" dos criminosos então em voga, ensinada aos policiais, na sua Escola, numa disciplina intitulada "História Natural dos Malfetores". A par da criminalização, o sistema penal da primeira República aprimora a vigilância. Em nome do princípio positivista da liberdade de profissões, Miguel Lemos protesta junto ao ministro do Interior, em 6 de fevereiro de 1890, contra um regulamento para o serviço doméstico editado pela Intendência Municipal do Rio²¹¹, mas em 1914 uma lei municipal paulistana, a pretexto sanitário, impõe o registro das empregadas domésticas²¹². Vigilância e até matrícula das prostitutas provinham do Império, porém a especialização (polícia de costumes) incrementará sua prática. A espionagem policial de associações operárias é uma constante em todo o período. O padrão liberal de vigilância, aquele inspetor de quarteirão que devia "vigiar sobre a prevenção dos crimes", admoestando os desordeiros e reportando-se ao juiz de paz, criado pelo código de processo imperial (art. 18, inc. 1°), fragmenta-se em núcleos especializados e principalmente desregulamentados, que se reportam, sem fórmulas legais a observar, e sem controle crítico sobre seus levantamentos, aos mais altos escalões das agências policiais. A questão social era definitivamente um caso de polícia, e o manifesto da União dos Operários em Construção Civil

²¹⁰ Cf. a carta de Miguel Lemos a Quintino Bocayuva, de 29.out.881, em Paim, Antônio, *O Apostolado Positivista e a República*, Brasília, 1981, ed. UnB, p. 13.

²¹¹ Antônio Paim, op. cit., p. 69.

²¹² Cf. Boris Fausto, *Crime e Cotidiano*, cit., p. 150.

de 1920 ("Contra a Cadeia, pela Escola"), recusando construir mais prisões²¹³, representava o contraponto político mais lúcido e consequente. Se o proletariado dava os primeiros passos para organizar-se e reconhecer-se como classe, num enfrentamento diuturno e frequentemente sangrento, os alvos desclassificados daquele sistema penal, que ousassem ultrapassar as fronteiras de seus lugares sociais, eram quase passivamente vigiados e criminalizados, e suas improvisadas estratégias de autoproteção não dispunham de eficácia muito superior às velhas orações para "fechar o corpo"²¹⁴, invocando um São Jorge algo africanizado, e ainda sob os riscos da feitiçaria, prevista em lei (art. 157 CP 1890) e versada pela Conferência Judiciária-policia²¹⁵.

IV O Código Penal de 1940

²¹³ Cf. Gizlene Neder, *Discurso Jurídico*, cit., p. 95.

²¹⁴ Wissenbach, Maria Cristina Cortez, *Da escravidão à liberdade: dimensões de uma privacidade possível*, em Fernando Novais (org.) *História da Vida Privada*, cit., p. 127.

²¹⁵ Sobre o assunto, cf. Maggie, Yvonne, *Medo do Feitiço: Relações entre Magia e Poder no Brasil*, Rio, 1992, ed. Arq. Nac.

1. A história do código de 1940 e do sistema penal que se constituiu tomando-o como referência programadora axial tem raízes no conjunto de transformações implantadas a partir da chamada revolução de 1930. Politicamente, 1930 exprime uma reação contra o federalismo exacerbado da primeira República, que se materializara na "política de governadores" apoiada no mandonismo local dos "coronéis"; tal reação, portanto, implicaria não apenas uma forte centralização de poder, acompanhada da necessária reestruturação administrativa, mas também a submissão a este novo poder público de um conjunto de conflitos anteriormente dirimidos em âmbitos privados. Economicamente, 1930 marca a ruptura com a teoria liberal do estado *gendarme* — que Nelson Hungria saborosamente comparará "a um guarda noturno modorrento, que só desperta a um rumor mais alto e se limita a soprar no seu apito assustado e inócuo"²¹⁶ — e a consequente implantação de um estado intervencionista²¹⁷. A crise internacional, o esgotamento do modelo agro-exportador e a superação da mentalidade ufanista que nos restringia ao papel dependente de fornecedores inexauríveis de matéria-prima²¹⁸

²¹⁶ O Direito Penal no Estado Novo, em RF 85/265ss.

²¹⁷ A criação do Conselho Nacional do Café (1931), do Instituto do Açúcar e do Alcool (1933), do Conselho Nacional do Petróleo (1938), do Instituto do Mate (1938), do Conselho de Águas e Energia (1939), do Instituto do Sal (1940), da Comissão Executiva do Plano Siderúrgico Nacional (1940), do Instituto do Pinho (1941), da Comissão de Combustíveis e Lubrificantes (1941), do Conselho Nacional de Ferrovias (1941) e da Comissão do Vale do Rio Doce (1942), bem como o protagonismo do próprio Estado na produção de base (Companhia Siderúrgica Nacional, 1941; Companhia Nacional de Álcalis, 1943; Companhia Hidrelétrica do São Francisco, 1945) revelam a extensão deste esforço. Na contramão desta linha, um relatório de Eugênio Gudin, propondo "a suspensão gradual do mecanismo de intervenção do Estado na economia, a fim de garantir o livre jogo das forças do mercado" (Diniz, Eli, O Estado Novo: Estrutura de Poder e Relações de Classes, em Fausto, Boris [org.] História Geral da Civilização Brasileira — O Brasil Republicano, S. Paulo, 1981, ed. Difel, t. III, p. 116) outorga-lhe a duvidosa glória de ter sido o nosso Hayek (cf. Hayek, Friedrich August von, O Caminho da Servidão, trad. A.M. Capovilla *et alii*, Rio, 1990, ed. Inst. Liberal).

²¹⁸ A superação de tal mentalidade — que contrapunha um Brasil *natural* gran-

conduzirá a um surto industrial cujo ritmo só seria contido pela eclosão da guerra. "A produção de bens de capital, medida em termos de ferro, aço e cimento, recomeçou a crescer já em 1931, e em 1932 aumentara de 60% em relação a 1929; a produção industrial, de modo geral, cresceria 50% entre 1929 e 1937"²¹⁹. Dos 49.418 estabelecimentos industriais registrados pelo censo de 1940, 34.691 haviam sido fundados após 1930²²⁰. Ao mesmo tempo em que credores estrangeiros do Brasil eram levados a aceitar "cortes drásticos de seus créditos", como em 1934, 1940 e 1944²²¹, inúmeras medidas de proteção ao parque industrial brasileiro eram adotadas, preconizando-se a substituição de importações²²² — ainda que frequentemente isso correspondesse à mera montagem de componentes fabricados no exterior. Socialmente, 1930 é sobretudo o ponto de partida para a "incorporação da classe trabalhadora ao cenário político da sociedade brasileira"²²³, ainda que tal classe não haja participado — à parte algumas manifestações públicas favoráveis — das articulações que tornaram

dioso a um Brasil humano deprimido — em discursos da época é trabalhada por Castro Gomes, Ângela, *A Invenção do Trabalhismo*, Rio, 1994, ed. R. Dumarã, pp. 177ss.

²¹⁹ Sola, Lourdes, *O Golpe de 37 e o Estado Novo*, em AA.VV. *Brasil em Perspectiva*, cit., p. 263; cf. também Furtado, Celso, *Formação Econômica do Brasil*, cit., p. 231; Mendonça, Sônia Regina de, *As bases do desenvolvimento capitalista dependente*, em Linhares, M. Yedda (org.) *História Geral do Brasil*, cit., pp. 243 ss.

²²⁰ Diniz, Eli, op.cit., p. 90.

²²¹ Caio Prado Júnior, *História Econômica do Brasil*, cit., p. 297. De uma dívida pública externa de 235 milhões de libras esterlinas em 1930 (na República velha, os Estados da federação podiam tomar empréstimos externos sem licença prévia da União), reconheceram-se apenas 130 milhões, posteriormente liquidados por compensação de exportações não pagas. A substituição de importações retomava os princípios da lei do similar nacional, que na fundação da República Rui Barbosa, sem sucesso, fizera aprovar (cf. Furtado, Celso, *O Longo Amanhecer*, Rio, 1999, ed. Paz e Terra, p. 113).

²²² Exemplos em Fausto, Boris, *A Revolução de 1930*, S. Paulo, 1997, ed. Cia das Letras, p. 68.

²²³ Castro Gomes, Ângela, *A Invenção do Trabalhismo*, cit., p. 293.

vitorioso o movimento²²⁴. A incorporação do proletariado foi instrumentalizada pela legislação previdenciária — que das Caixas de Previdência, em 1931, chegaria aos Institutos de Aposentadoria e Pensões das diversas categorias profissionais, envolvendo assistência médica e programas habitacionais²²⁵ —, pela organização sindical, implantada a contragosto das oligarquias regionais, e pelas leis trabalhistas que culminarão na criação da Justiça do Trabalho e na edição da Consolidação das Leis do Trabalho²²⁶. Paralelamente à configuração dessa nova economia nacional, que desloca seu centro de gravidade das atividades agroexportadoras para a industrialização, edifica-se um Estado intervencionista e previdenciário. As cidades — onde a educação pública primária reduzirá o analfabetismo²²⁷, onde agora também as mulheres vo-

²²⁴ Sobre as forças políticas e sociais que se mobilizaram para 1930, cf. Fausto, Boris, *A Revolução de 1930*, cit., *passim* e Skidmore, Thomaz, *Brasil: de Getúlio a Castelo*, S. Paulo, 1979, ed. Paz e Terra, pp. 27 ss. Mais do que exigência de uma burguesia industrial dissociável da agroexportadora, que não se pode reconhecer à época (Octavio Lantini menciona uma "metamorfose do capital agrário em capital industrial": *O Colapso do Populismo no Brasil*, Rio, 1971, ed. Civ. Bras., p. 26), a industrialização era um tópico destacado do planejamento estratégico das Forças Armadas.

²²⁵ Até 1930, praticamente só os ferroviários e os portuários dispunham de uma Caixa de Previdência. Cf. Ribeiro, José Augusto, *A Era Vargas*, Rio, 2001, ed. Casa Jorge, v. I, p. 104.

²²⁶ Dec.lei nº 5.452, de 1º.mai.43. Uma síntese desse processo legislativo assinalaria a jornada de 8 horas com repouso semanal obrigatório para industriários e comerciários (1932), jornada de 6 horas para bancários (1932), a criação de Juntas e Comissões Mistas de Conciliação e Julgamento (1932), convenções coletivas de trabalho (1932), limites ao trabalho de mulheres e menores (1932), instituição de assistência médica nas Caixas de Aposentadoria e Pensões (1932), férias anuais remuneradas para comerciários, bancários e industriários (1933), criação de Caixas ou Institutos de Aposentadoria e Pensões dos marítimos (1933), dos trabalhadores em trapiches e armazéns de café (1934), estivadores (1934), comerciários (1934), bancários (1934) e industriários (1936), reforma e ampliação da lei sobre acidentes de trabalho (1934), indenização por despedida injusta (1935), salário mínimo (1936; a primeira tabela entraria em vigor em 1940), instituição da Justiça do Trabalho (1939) e reorganização sindical (1939-1940).

²²⁷ Skidmore, op. cit., p. 54.

tam²²⁸ – começam a crescer, na razão direta da oferta de postos de trabalho industriais. Ao mesmo tempo, nos anos trinta “as grandes correntes ideológicas que dividiam o mundo contemporâneo penetravam no país”²²⁹, e influenciariam muito nosso processo político interno.

2. A literatura jurídica brasileira, em geral, promove uma simplificação grosseira em sua análise do período que vai de 1930 a 1945, detendo-se na casca aparente das formas políticas, especialmente no caráter ditatorial do Estado Novo²³⁰. Não surpreende que seja assim, porquanto mesmo entre historiadores e cientistas políticos a complexidade daqueles acontecimentos desafia ainda hoje interpretações simplistas, que não logram compreendê-los por completo e vêm sendo questionadas²³¹. Não nos deteremos sobre a interpretação que se vale da categoria do *populismo*²³², que só reflexamente afeta os campos da programa-

²²⁸ Dec. nº 21.076, de 24.fev.32 (art. 2º: “É eleitor o cidadão maior de 21 anos, sem distinção de sexo, alistado na forma deste Código”). Tal decreto instituiu a Justiça Eleitoral, com uma estrutura cujas linhas gerais ainda subsistem hoje.

²²⁹ Fausto, Boris, *A Revolução de 1930*, cit., p. 151.

²³⁰ Por exemplo, uma exclusiva influência fascista da *Carta del Lavoro* sobre a legislação sindical e trabalhista (também por exemplo, Romita, Arion Sayão, *Justiça do Trabalho: produto do Estado Novo*, em Pandolfi, Dulce (org.) *Repensando o Estado Novo*, Rio, 1999, ed. FGV, pp. 95 ss) ignora não só uma indescartável influência francesa, como também os compromissos socialistas da assessoria do ministro Lindolfo Collor (Joaquim Pimenta, Evaristo de Moraes, Agripino Nazaré e Carlos Cavaco) ou o nível técnico-jurídico da assessoria do ministro Alexandre Marcondes Filho (Arnaldo Sussekind, Oscar Saraiva, Segadas Vianna). Em outras áreas dá-se algo similar: Mário de Andrade, Lúcio Costa, Alceu Amoroso Lima, Carlos Drummond de Andrade, Cândido Portinari, Heitor Villa-Lobos e Anísio Teixeira foram colaboradores do ministro Gustavo Capanema.

²³¹ Assim, Ferreira, Jorge, *Trabalhadores do Brasil*, Rio, 1997, ed. FGV.

²³² Representada por Octavio Ianni (op. cit.) e Francisco Weffort (*O Populismo na Política Brasileira*, Rio, 1980, ed. Paz e Terra). Este último não deixa de reconhecer que o processo em 1930 foi “a expressão mais completa da emergência das classes populares”, que a partir de então conseguiu exter-

ção criminalizante e do sistema penal que a dota de eficácia. Ao contrário, estes campos são diretamente afetados pela interpretação que trabalha com a categoria do *totalitarismo*²³³. Mesmo renunciando a discutir a produção histórica desta categoria²³⁴, cabe-nos constatar facilmente alguns equívocos nos quais seus defensores têm que incidir para sustentá-la, sem embargo dos muitos méritos de seus trabalhos. Circunscrevendo-nos à obra de Elizabeth Cancelli, encontramos a afirmação de que em 1930 estão as raízes “de uma polícia que rompeu todos os seus vínculos de solidariedade com a comunidade”²³⁵. Não seria necessário provar a existência anterior desses “vínculos de solidariedade com a comunidade”, cabalmente desmentidos – entre outros – pelos estudos de Holloway no século XIX e de Gizlene Neder ou Marcos Bretas na primeira República? Os populares que em São Paulo atacaram a delegacia policial de Cambuci, em outubro de 1930, não pareciam acreditar muito nesses vínculos²³⁶. Em outro trabalho, a Autora, após registrar corretamente que a vadiagem e

nar “suas insatisfações” (pp. 61 e 62). Para as insuficiências da teoria do populismo, cf. Laclau, Ernesto, *Política e Ideologia na Terra Marxista*, Rio, 1979, ed. Paz e Terra, e Cerqueira Filho, Gisálho, *A Questão Social no Brasil*, Rio, 1982, ed. Civ. Bras. Nas tendências criminológicas mais atrasadas e policiais ainda se evoca hoje a categoria do populismo (Teixeira, Ib, *A Violência sem Retoque*, Rio, 2002, ed. Universidade, pp. 47 ss).

²³³ Representada por Lenharo, Alcir, *Sacralização da Política*, Campinas, 1986, ed. Unicamp-Papirus e Cancelli, Elizabeth, *O Mundo da Violência*, Brasília, 1994, ed. UnB.

²³⁴ Cesar Guimarães assinala que a noção de *totalitarismo* passou a ser empregada no pós-guerra por “setores da academia e do *establishment* americanos para unificar os sentidos do fascismo derrotado e do comunismo a vencer” (Vargas e Kubitschek: a longa distância entre a Petrobrás e Brasília, em Rezende de Carvalho, M. Alice [org.] *República no Catete*, Rio, 2001, ed. Museu da República, p. 160). Sobre o assunto, Lósurdo, Domenico, *Para uma crítica da categoria do totalitarismo*, em *Crítica Marxista* nº 17, pp. 51 ss.

²³⁵ Ação e repressão policial num circuito integrado internacionalmente, em Pandolfi, Dulce, *Repensando o Estado Novo*, cit., p. 309.

²³⁶ A foto se encontra em Brandão Murakani, A. Maria (org.) *A Revolução de 1930 e seus Antecedentes*, Rio, 1980, ed. N. Fronteira, p. 174.

a mendicância passaram a ser punidas com prisão de 15 dias a 3 meses²³⁷, afirma que “quando havia reincidência, entretanto, poderia haver reclusão de 1 a 5 anos em colônia penal”, concluindo que “os castigos haviam se tomado mais severos”²³⁸. Ainda que ignorássemos os decretos através dos quais Getúlio Vargas indultou todos os condenados e todos os acusados por vadiagem e capoeiragem²³⁹, não há comparação possível entre o regime legal da primeira República²⁴⁰ e o da lei de contravenções penais de 1941, mesmo considerando-se as medidas de segurança, essa

²³⁷ Dec. lei nº 3.688, de 2.out.41 (conhecido por Lei de Contravenções Penais), arts. 59 e 60.

²³⁸ O Mundo da Violência, cit., pp. 34 e 35.

²³⁹ Decretos nº 19.445, de 1º.dez.30 e nº 21.946, de 12.out.32. Tais decretos abrangiam também os crimes de resistência, desacato, lesões corporais leves ou culposas, e o segundo deles também o curandeirismo e a feitiçaria (art. 157 CP 1890, que contemplava o espiritismo). O segundo decreto constitui, portanto, o marco inicial da descriminalização dos cultos afro-brasileiros, que se implementará no código de 1940, num tardio deslocamento do eixo religioso para o sanitário (art. 284 CP 1940). Não obstante, Filinto Müller ampliaria em 1941 o registro policial dos centros espíritas (cf. Maggie, Yvonne, op. cit., p. 46). A vigilância policial sobre os locais dos cultos subsistiria mais algumas décadas. O primeiro ato que dispôs o registro policial desses locais foi do governador da Bahia Roberto Santos (dec. nº 25.095, de 15.jan.76; cf. Nascimento, Abdias do, O Genocídio do Negro Brasileiro, Rio, 1978, ed. Paz e Terra, p. 104). Caberia mencionar também o dec. lei nº 22.494, de 24.fev.33, que reduziu à metade os prazos de prescrição para menores de 21 anos, fonte de uma regra que se incorporaria definitivamente ao direito penal brasileiro.

²⁴⁰ As penas dos artigos 399 e 402 CP 1890 foram alteradas pelo dec. leg. nº 145, de 12.jul.893 (revigorado pela lei nº 947, de 29.dez.902) e passaram para internação em colônia correccional por 6 meses a 2 anos. Na reincidência, mantinha-se a previsão original do CP 1890 (internação por 1 a 3 anos, seguida de deportação, caso estrangeiro o condenado). Se se tratasse de reincidência na capoeiragem, a internação seria pelo prazo máximo. O dec. lei nº 6.994, de 19.jun.908, consolidou esses dispositivos (arts. 51 a 57). A escala penal de 1 a 5 anos foi introduzida pelo código de Menores (dec. nº 17.943-A, de 12.out.927, art. 78) para vadios e capoeiras entre 18 e 21 anos: paradoxalmente, a imaturidade agravava a pena! Compare-se tudo isso com a lei de contravenções penais (que obviamente jamais comina a pena de reclusão).

cruel e festejada novidade que os tribunais, no tema específico de vadiagem e mendicância, reduziram drasticamente²⁴¹. A criminalização da vadiagem é quase um dado estrutural do capitalismo industrial, e portanto não poderia estar ausente da conjuntura em exame; contudo, a disciplina legal da República agro-exportadora a respeito foi inquestionavelmente mais severa. Frisando que “a Escola Positiva ganhara cada vez mais adeptos”, e que “os princípios teóricos desenvolvidos na Itália por Cesare Lombroso, Enrico Ferri e Sergio Sergi eram benvidos”, afirma também a Autora que, para “incorporar os princípios da Escola Positiva”, de modo a abrir “espaço maior para a ação da nova polícia”, tratou o governo Vargas de reformar o código penal: “assim, em 1932, foi feita a Consolidação das Leis Penais e, em 1940, o Estado Novo aprova o Código Penal”²⁴². Desde logo, cabe relembrar que a Consolidação das Leis Penais foi obra de um magistrado sem qualquer compromisso com 1930, e elaborada inteiramente com materiais legislativos da primeira República, sobre a estrutura do código de 1890. Além disso, a afirmativa de que o CP 1940 representou uma incorporação dos princípios da criminologia positivista constitui evidente exagero. Precisamente pela influência metodológica do tecnicismo jurídico²⁴³, a criminologia positivista — a única existente na ocasião — “caíra em desgraça na órbita jurídica, homiziando-se nas Faculdades de Medicina, nos labora-

²⁴¹ Seja limitando a 1 ano o prazo da medida de segurança (RT 234/328), seja libertando o condenado que, cumprida a exigua pena de prisão simples por 15 dias a 3 meses, não fosse removido para inexistentes colônias agrícolas ou institutos de trabalho, reeducação ou ensino profissional (RT 271/513).

²⁴² O Mundo da Violência, pp. 77 e 78.

²⁴³ René Ariel Dotti assinala a “notória adesão (do CP 1940) aos postulados do movimento técnico-jurídico” (História da legislação penal brasileira, em Casos Criminais Célebres, S. Paulo, 1999, ed. RT, p. 104). Compare-se o manifesto do tecnicismo (Rocco, Arturo, *El Problema y el Metodo de la Ciencia del Derecho Penal*, trad. R. N. Vallejo, Bogotá, 1978, ed. Têmis) com a famosa conferência de Hungria em São Paulo (Introdução à Ciência Penal, em Novas Questões Jurídico-penais, Rio, 1945, ed. Nac. Dir., pp. 3 ss).

tórios, nos manicômios, nas penitenciárias²⁴⁴. Refutações cabais da antropologia criminal eram frequentes. Barreto Campelo se insurge, em 1943, contra a preconceituosa interpretação lombrosiana acerca das tatuagens nos presos²⁴⁵; Hungria, o mais influente dos redatores do CP 1940, dizia causticamente que em termos de etiologia do crime “continuamos tão profundamente ignorantes quanto o éramos antes de Lombroso”²⁴⁶. Apesar da Exposição de Motivos do CP 1940 assumir uma “política de transação ou de conciliação” entre os “postulados clássicos” e os “princípios da Escola Positiva”, o que levaria Magalhães Noronha a agradecer que o código “acendeu uma vela a Carrara e outra a Ferri”²⁴⁷, o fato é que, elaborado numa conjuntura na qual o positivismo criminológico era internacionalmente prestigiado, o texto de 1940, que mesmo operando com medidas de segurança fugiu ao modelo unitarista, eludiu-se a tal influência. Nas insuspeitas palavras de Costa e Silva, “nascido embora sob o regime totalitário, o código não apresenta peculiaridades que lhe imprimam o cunho de uma lei contrária às nossas tradições liberais; não é um código de partido”²⁴⁸. Não discrepa Fragozo: “embora elaborado durante um regime ditatorial, o CP 1940 incorpora fundamentalmente as

²⁴⁴ Pimentel, Manoel Pedro, Breves notas para a história da criminologia no Brasil, em *Ciência Penal*, Rio, 1979, ed. Forense, ano V, n° 2, p. 42.

²⁴⁵ Cf. Aguiar Serra, Carlos Henrique, História das Ideias Jurídico-penais no Brasil: 1937 a 1964, Niterói, 1997, tese doutoral, mimeo, UFF, p. 150; Lombroso Cesare, *Les Palimpsestes des Prisons*, Paris, 1894, ed. G. Masson. Na crítica de Barreto Campelo se pode entrever a ressonância da ideia de “homem brasileiro”. Entre as brumas ideológicas daquela conjuntura, o racismo em voga foi aproveitado contra si mesmo. A celebração do Dia da Raça – necessariamente mestiça – representou, como notado por Ângela Castro Gomes, uma “postura de combate aos preconceitos de cor e de elogio ao ecletismo étnico do povo brasileiro, sepultando os ideais de eugenia e branqueamento” (*A Invenção do Trabalhismo*, cit., p. 207).

²⁴⁶ Novas Questões, cit., p. 56.

²⁴⁷ Noronha, E. Magalhães, *Direito Penal*, S. Paulo, 1985, ed. Saraiva, v. 1, p. 61.

²⁴⁸ Costa e Silva, A.J., *Comentários ao Código Penal*, S. Paulo, 1967, ed. Contasa, p. 10.

bases de um direito punitivo democrático e liberal”²⁴⁹. Para encerrar este tópico com a observação de fatos concretos, concernentes ao tratamento da saúde de presos políticos, compare-se a descrição de Cancelli²⁵⁰ com a de Ferreira²⁵¹. Este último revela os frequentes atritos entre burocratas do Ministério da Justiça ou mesmo médicos e funcionários subordinados a “Filinto Muller e sua polícia”, concluindo que “o estudo dos processos de presos políticos que pedem tratamento de saúde desautoriza qualquer versão sobre a existência de um estado monolítico, compacto e isento de contradições internas”²⁵². Em suma, o caminho de compreender o sistema penal do capitalismo industrial dependente e do Estado previdenciário brasileiro, que estão sendo implantados a partir de 1930, unicamente a partir do sub-sistema penal da repressão manifestamente política empobrece e mutila a investigação. Marcos Bretas advertiu justamente sobre o “crescimento da abordagem política em detrimento da história social”, destacando que “as abordagens da polícia privilegiam o seu papel político”²⁵³. O que pensariamos de uma descrição do sistema penal brasileiro do período 1968-1979 que só se detivesse sobre o sub-sistema DOPS/DOI-CODI?

3. A elaboração do CP 1940 se inscreve numa dinâmica política especial, que o fez situar-se equidistantemente da breve Constituição de 1934 – fruto negociado da frustrada revolução constitucionalista de 1932, cujos pigmentos weimarianos foram logo engraxados pelas tintas fortes do marechal Pilsudski, com as quais Francisco Campos desenhou a decretada Constituição de 1937²⁵⁴ – e da Constituição de 1946, que culminaria o processo

²⁴⁹ Fragozo, Heleno, Lições, cit., P.G., p. 66.

²⁵⁰ O Mundo da Violência, cit., pp. 198 ss (A saga dos doentes).

²⁵¹ Trabalhadores do Brasil, cit., pp. 112 ss (Estado, sistema penitenciário e prisioneiros políticos).

²⁵² Op. cit., p. 119.

²⁵³ Bretas, Marcos Luiz, A Guerra das Ruas, Rio, 1997, ed. Arq. Nac., p. 16.

²⁵⁴ Para as influências sofridas por essas duas Constituições, Cerqueira, Marcello, A Constituição na História, Rio, 1993, ed. Revan, pp. 332 e 335.

de desmonte do Estado Novo. Trata-se de um período com intensa produção legislativa. No âmbito do direito e do processo penal militar, definir-se-ão os textos básicos do Código de Justiça Militar²⁵⁵ e do Código Penal Militar²⁵⁶ que, com alterações pontuais, regerão até 1969²⁵⁷. Interessa-nos destacar dois campos da programação criminalizante: aquele concernente ao direito penal da intervenção econômica e aquele relativo ao subsistema penal da repressão política. Quanto ao primeiro, já o dec. n° 19.604, de 19.jan.31, promovia equiparação *quoad poenam* ao estelionato das condutas de fabricar, vender ou "expor a consumo público" gêneros alimentícios cuja qualidade tivesse sido modificada ou cujo valor nutritivo tivesse sido reduzido (art. 1°, inc. I), ou que contivessem "ingredientes nocivos à saúde" (inc. V), tornando obrigatório o exame sanitário de produtos estrangeiros (art. 4°). As duas grandes figuras acadêmicas que começam a destacar-se, Nelson Hungria e Roberto Lyra²⁵⁸, apoiarão a política criminal intervencionista. Hungria afirmará que "o regime da livre e des-

²⁵⁵ O dec. n° 24.803, de 14.jul.34, alterou o dec. n° 17.231, de 26.fev.26; o dec. lei n° 925, de 2.dez.38, deu forma definitiva ao CJM.

²⁵⁶ Dec.lei n° 6.227, de 24.jan.44.

²⁵⁷ Nessa ocasião, serão editados os Código Penal Militar (dec.lei n° 1.001, de 21.out.69), Código de Processo Penal Militar (dec.lei n° 1.002, de 21.out.69) e a lei de Organização Judiciária Militar (dec.lei n° 1.003, de 21.out.69). Com alterações pontuais – talvez as mais importantes sejam as da lei n° 9.299, de 7.ago.96, que subtraiu à jurisdição militar crimes dolosos contra a vida cometidos contra civil – estes diplomas legais encontram-se hoje em vigor.

²⁵⁸ Sobre Hungria, cf. Scartezini, Cid Flaquer, Nelson Hungria: o homem e o jurista, S. Paulo, 1974, ed. A.P.Dir., e os trabalhos de Sepúlveda Pertence e René Dotti em Nelson Hungria – Centenário de seu nascimento, Brasília, 1993, ed. STF; sobre Lyra, cf. Lopo Alegria, Assin foi Roberto Lyra, Rio, 1984, ed. L.Juris, e Araújo Júnior, J. Marcelo, Roberto Lyra, Rio, 1980, ed. Forense. O grande estudo comparativo é o ainda infelizmente inédito de Carlos Henrique Aguiar Serra, História das Ideias Jurídico-penais no Brasil: 1937 a 1964, cit. Cabe mencionar a livre-docência que ambos disputaram, em 1933, na Faculdade Nacional de Direito, perante banca examinadora presidida por Galdino Siqueira: Hungria, com tese sobre *Fraude Penal*, e Lyra versando *Economia e Crime*. A ata está transcrita em Lopo Alegria, op. cit., p. 101.

vigiada iniciativa particular favorece o enriquecimento de uns poucos em prejuízo da grande massa da população"²⁵⁹. Lyra dirá ser forçoso "reconhecer, a partir de 1930, o crescente primado do interesse coletivo no mecanismo do Estado", tocando à lei de economia popular o papel de "instrumento de justiça social"²⁶⁰. Através do dec. n° 22.626, de 7.abr.33, foi criminalizada a usura (art. 13), proibindo-se taxas superiores ao dobro dos juros moratórios que o Código Civil previa no artigo 1.062 para a ausência de convenção entre as partes (art. 1°): tal dispositivo inspiraria o constituinte de 1988 (art. 192, § 3° CR/ não auto-aplicável por decisão do STF) e está vigente ainda hoje, naturalmente não para os bancos²⁶¹. Inspirado no anteprojeto argentino de 1937, elaborado por Jorge E. Coll e Eusébio Gomez, e em propostas de comissão oficial alemã (que concluiu em 1936 um projeto que não seria adotado), o dec.lei n° 869, de 18.nov.38 – que teve em sua redação a colaboração de Hungria²⁶² – viria a constituir-se no centro referencial dessa programação criminalizante, influenciando leis futuras sobre o assunto e correlatas²⁶³. Tal decreto-lei compreendia, além do que se poderia tecnicamente designar por crimes contra a economia popular (como a transgressão de tabe-

²⁵⁹ Hungria, Nelson, Dos Crimes contra a Economia Popular, Rio, 1939, ed. Jacintho, p. 6. A adesão de Hungria – a quem abominavam todos os autoritarismos (cf. Compêndio, cit., pp. 5 ss e 29 ss) – ao Estado Novo é fato incontestável. Os pronunciamentos do ministro Francisco Campos eram por ele tratados como "magistrais circulares" ou "lapidares pastorais" (Dos Crimes contra a Economia Popular, cit., pp. 8 e 11). Disse ele, na ocasião, que a lei de imprensa de 1934 "enaltece nossa civilização jurídica" (Novas Questões, cit., p. 24). Seu texto definitivo a respeito é o citado O Direito Penal no Estado Novo.

²⁶⁰ Lyra, Roberto, Crimes contra a Economia Popular, Rio, 1940, ed. Jacintho, p. 91.

²⁶¹ Sobre o assunto, Batista, Nilo, A usura nos tempos do neoliberalismo, DS-CDS 3/215 ss.

²⁶² Cf. Roberto Lyra, Crimes contra a Economia Popular, cit., p. 110.

²⁶³ Tal influência se exerceria diretamente sobre a lei n° 1521, de 26.dez.51, que dispôs sobre a mesma matéria, e indiretamente sobre diversos outros diplomas legais (por exemplo: o art. 4°, inc. I da lei n° 8.137, de 27.dez.90, em relação ao art. 2°, inc. IV do dec.lei n° 869; o art. 4° da lei n° 7.492, de 16.jun.86, em relação ao art. 2°, inc. IX do dec.lei n° 869, etc).

las oficiais de preços — art. 3º, inc. II), também delitos de abuso de poder econômico (art. 2º, incs. II a V), a usura (art. 4º)²⁶⁴, e germinalmente algo do futuro direito penal do consumo (art. 2º, inc. VII). Sinal dos tempos, atribuiu-se o julgamento de tais crimes ao Tribunal de Segurança Nacional — do qual nos ocuparemos mais tarde — e proibiu-se a suspensão condicional da pena e o livramento condicional (art. 6º). A interdição administrativa da pessoa jurídica em cujo nome se praticasse o delito, uma vez transitada em julgado a sentença condenatória (art. 5º) é um precedente histórico que cabe assinalar. A grande reação causada pelo inc. IV, segunda parte, do artigo 3º (que criminalizava, nas vendas com reserva de domínio rescindidas por mora do comprador, o desconto, nas prestações já pagas, de quantia maior do que a correspondente à depreciação da coisa) levou à edição (para atender, como disse Hungria, “a grita dos comerciantes interessados”²⁶⁵) do dec. lei nº 1.041, de 11.jan.39, que ressaltou da nova disciplina os contratos anteriores; o novo Código de Processo Civil, que entrou em vigor em 1º de março de 1940, dispôs a respeito. Ainda numa linha de complementação do dec. lei nº 869, de 18.nov.38, o dec. lei nº 1.113, de 22.fev.39, vedou a cobrança de juros superiores a 12% ao ano nos empréstimos sob penhor, também ressaltando os contratos já celebrados (art. 1º, par. ún.). Como a lei nº 38, de 4.abr.35 (que será referida a seguir, porquanto relativa a crimes contra a segurança do Estado) contemplasse um delito contra a economia popular que mencionava gêneros de primeira necessidade (art. 21), foram estes definidos pelo dec. lei nº 1.716, de 28.out.39 (art. 1º), que também outorgava às apurações administrativas da Comissão de Abastecimento (criada pelo dec. lei nº 1.067, de 16.set.39) “força de inquérito policial para efeito de processo no Tribunal de Segurança Nacional” (art. 3º). Tratemos agora da programação criminalizante de

²⁶⁴ Na qual, por influência alemã — a indistinação entre *Geldwucher* e *Geschäftswucher* — à usura pecuniária somou-se a usura real ou negocial (cf. Hungria, *Dos Crimes contra a Economia Popular*, cit., p. 144).

²⁶⁵ *Dos Crimes contra a Economia Popular*, p. 123.

que se valia o sub-sistema penal da repressão política, que apenas se comunicava com o aparato punitivo da intervenção econômica no procedimento perante o Tribunal de Segurança Nacional (TSN). O alvo por excelência desse sub-sistema penal era o Partido Comunista, fundado em 1922, e que em 1935 procura articular sindicatos, promove mobilizações e eventos, aposta na constituição de uma frente — a efêmera Aliança Nacional Libertadora (criada em março, com 1.600 sedes locais em maio, fechada pelo governo em julho) — e chega a uma frustrada insurreição, a partir de alguns quartéis nas cidades de Natal, Recife e Rio, em novembro. Aos comunistas, enquanto alvos deste sub-sistema penal, viriam juntar-se membros de uma organização fascista, a Ação Integralista Brasileira, menos por ocasião de sua dissolução²⁶⁶ do que após o ataque ao palácio Guanabara em maio de 1938²⁶⁷. Ampla reforma da polícia se realizara em 1934²⁶⁸. A lei nº 38, de 4.abr.35, definiu os “crimes contra a ordem política e social”. Além da insurreição (art. 1º), com escala penal inferior à revogada²⁶⁹, dos delitos de perturbação à reunião ou ao funcionamento de poderes políticos ou de seus agentes (arts. 2º e 3º)²⁷⁰, da coação a funcionários, da incitação a tais delitos, da greve de funcionários públicos (art. 8º), da posse não autorizada de “engenhos explosivos” (art. 13), da coação a funcionários, da incitação a tais delitos, da greve de funcionários públicos (art. 8º), da posse não autorizada de “engenhos explosivos” (art. 13), da instigação das “classes sociais à luta pela violência” (art. 15) e da conspiração

²⁶⁶ O dec. lei nº 37, de 2.dez.37, dissolveu todos os partidos políticos (art. 1º) e todas as “milícias cívicas e organizações auxiliares” (art. 1º, § 2º), proibindo o “uso de uniformes, estandartes, distintivos e outros símbolos” (art. 2º). As camisas verdes e o sigma tornaram-se ilegais.

²⁶⁷ Sobre o episódio, Silva, Hélio, 1938 — Terrorismo em Campo Verde, Rio, 1971, ed. Civ. Bras.

²⁶⁸ Dec. lei nº 24.531, de 2.jul.34.

²⁶⁹ O que levou Hungria a dizer que “o diabo não é tão feio como se pinta” (*Compêndio*, cit., p. 66).

²⁷⁰ Nos quais a proeminência da União se reflete nas escalas penais (redução de 1/3, se poder ou funcionário for estadual, e de 1/2 se for municipal).

(art. 20), encontramos também o crime de promoção fraudulenta da "alta ou baixa dos preços de gêneros de primeira necessidade" (art. 21). Quando fossem os crimes políticos praticados através da imprensa, autorizava-se a polícia a apreender as "respectivas edições" (art. 25). Proibia-se a existência de partidos políticos ou agremiações que objetivassem "a subversão, pela ameaça ou violência, da ordem política ou social" (art. 30). Prevvia-se o cancelamento da naturalização de quem exercesse "atividade nociva ao interesse nacional" (art. 37 ss). Eram tais delitos submetidos a julgamento monocrático pela Justiça Federal (art. 44), e o cumprimento da pena — "asseguradas sempre boas condições de salubridade e higiene", que os prisioneiros que flagelavam Graciliano Ramos²⁷¹ ou o cruel isolamento a que foi submetido Luiz Carlos Prestes desmentem — não poderia "ser situado a mais de mil quilômetros do lugar do delito" (art. 43, § 1º). No mês seguinte à frustrada insurreição comunista, a lei nº 136, de 14.dez.35, alterou a lei nº 38 e acrescentou-lhe novos crimes. A atenção do legislador está agora voltada para a filiação, ostensiva ou clandestina, de funcionários públicos, militares, ou mesmo empregados de empresas, institutos ou serviços criados ou mantidos pelos poderes públicos a partidos ou agremiações proibidas (arts. 1º ss e 13). Crimes de opinião são criados (arts. 7º e 8º), reduzem-se os níveis de garantia dos procedimentos penais (art. 17) e administrativos para exoneração de funcionários (art. 18), e empregados de empresas particulares filiados, mesmo clandestinamente, a partidos ou agremiações proibidas podem ser demitidos sem indenização, desde que o Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio o autorize após apuração (art. 23). Estabelecimentos de ensino que não excluíssem professores nessas condições poderiam ser fechados (art. 24). Quatro dias após a edição desta lei, uma emenda constitucional autorizou a equiparação da "comoção intestina greve, com finalidades subversivas"

²⁷¹ Ramos, Graciliano, *Memórias do Cárcere*, S. Paulo, 1972, ed. Martins, v. I, pp. 210 ss.

ao "estado de guerra"²⁷². Através da lei nº 244, de 11.set.36, foi instituído, "como órgão da Justiça Militar" desde que decretado o "estado de guerra" (art. 1º), o Tribunal de Segurança Nacional (TSN), para o julgamento dos crimes contra a segurança externa da República e contra as instituições militares (art. 3º). A indicação pela Ordem dos Advogados do Brasil do defensor do acusado ausente ou desprovido de defesa (art. 9º, inc. 3º) ensejaria o encontro de Sobral Pinto com Prestes e Harry Berger. Testemunhas de defesa deviam comparecer independentemente de notificação (art. 9º, inc. 7º), atos processuais poderiam realizar-se "no presídio" (art. 9º, inc. 10) e presumia-se a culpa de quem fosse "preso com arma na mão por ocasião de insurreição" (art. 9º, inc. 15). Embora os cinco membros do TSN deveriam paradoxalmente julgar "como juízes de fato, por livre convicção" (art. 10, par. ún.), as decisões eram fundamentadas²⁷³. A Constituição de 1937, que tinha a "luta de classes", a "infiltração comunista" e o "apoio das Forças Armadas" em seu preâmbulo, previa que os crimes "contra a segurança do Estado e a estrutura das instituições" estariam sujeitos "a justiça e processo especiais, que a lei prescreverá" (art. 172). Foi o suficiente para que o dec. lei nº 88, de 20.dez.37, livrasse o TSN de sua configuração restritiva original (órgão da Justiça Militar para crimes contra a segurança do Estado em tempo de guerra), acrescentando-lhe um sexto juiz (art. 2º), agora que seus membros passariam a decidir monocraticamente como primeira instância (art. 7º), sendo irrecorríveis as decisões das apelações (art. 10), das quais se encarregaria o Tribunal Pleno (art. 8º). A competência do TSN abrangia agora os

²⁷² Dec.leg. nº 6, de 18.dez.35, Emenda nº 1. É que o estado de guerra implicava a "suspensão das garantias constitucionais" (art. 161 CR 1934).

²⁷³ Campos, Reynaldo Pompeu de, *Repressão Judicial no Estado Novo*, Rio, 1982, ed. Achiamé; Castello Branco, Eurico, *Anotações às Leis de Segurança Nacional e Economia Popular*, Rio, 1940, ed. Jacinho (este autor foi escrivão do TSN). O regimento interno do TSN em Lyra, Roberto, *Crimes contra a Economia Popular*, cit., pp. 39 ss.

crimes contra a economia popular (art. 4º, al. c)²⁷⁴. A lei constitucional nº 1, de 16.mai.38, alterou o art. 122, inc. 13 CR 1937 para autorizar a pena de morte para inúmeros crimes políticos (alfacaa a a f) e mesmo para o homicídio qualificado (al. f). O dec.lei nº 474, de 8.jun.38, que ampliou o breve dec.lei nº 428, de 16.mai.38, dispôs sobre o processo perante o TSN: seu caráter policialesco pode ser resumido na leitura de um só artigo²⁷⁵. O dec.lei nº 431, de 18.mai.38, consolidou toda a legislação anteriormente citada, ampliando a criminalização referente à segurança externa, elevando penas de crimes já existentes, e esclarecendo que a privação de liberdade se daria em "prisão celular", que o ministro da Justiça a qualquer tempo poderia converter em internação em "estabelecimentos especiais ou em colônias penais agrícolas" (art. 2º). A pena de morte, que se daria por fuzilamento (art. 2º, § 3º), jamais foi executada. A composição do TSN seria ainda objeto do dec.lei nº 1261, de 10.mai.39. Através do dec.lei nº 7.474, de 18.abr.45, Getúlio Vargas concedeu anistia "a todos quantos tenham cometido crimes políticos desde 16 de julho de 1934" (art. 1º). Foi o TSN extinto pela lei constitucional nº 14, de 17.nov.45. Não convém encerrar este tópico sem mencionar a hostilidade legal aos estrangeiros, proibidos de exercer atividade política (dec. lei nº 383, de 18.abr.38, art. 1º), impedidos de se organizar salvo para fins culturais ou beneficentes (arts. 2º e 3º), e vigiados (art. 6º). Da expulsão de estrangeiros trataram o dec. lei nº 392, de 27.abr.38, e nº 479, de 8.jun.38. A extradição de brasileiro, contudo, era inadmissível (dec.lei nº 394, de 28.abr.38). O dec. nº 4.865, de 23.out.42, proibiria a concessão da suspensão condicional de pena aplicada a estrangeiros que se encontrassem no país em caráter temporário (art. 1º), determinando

²⁷⁴ A lei constitucional nº 7, de 30.set.42, alteraria o art. 173 CR 1937 para a possibilidade de ampliação, em razão do estado de guerra, da competência do TSN.

²⁷⁵ "Art. 9º. Considera-se provado, desde que não eliminado por prova em contrário, o que ficou apurado no inquérito. Mas o juiz poderá, *ex-officio*, reinquirir as testemunhas que neste depuseram." A segunda oração não estava presente no dec.lei nº 428, de 16.mai.38 (art. 8º).

a revogação de *sursis* anteriormente concedido (art. 2º). Neste campo, talvez o mais significativo pormenor estivesse no fato de que *ser estrangeiro* constituía, para os crimes contra a segurança do Estado, circunstância agravante²⁷⁶.

4. Como vimos, o projeto de Virgílio de Sá Pereira, de 1927-1928, revisto por comissão integrada por ele próprio mais Evaristo de Moraes e Mário Bulhões Pedreira, apesar de aprovado em 1935 pela Câmara dos Deputados e remetido ao Senado, não se converteu em lei, atropelado teoricamente por muitas críticas, em 1936, e politicamente pelo advento do Estado Novo, em 1937. No final deste ano, o ministro Francisco Campos encarregou o prestigiado professor paulista Alcântara Machado, ex-governador, constituinte em 1933, e membro da Academia Brasileira de Letras, da elaboração de novo projeto. Em maio de 1938 – "com surpreendente presteza", diria ferinamente Hungria²⁷⁷ – Alcântara Machado entregava seu anteprojeto de Parte Geral do Código Criminal Brasileiro, completando-o, em agosto, com a Parte Especial²⁷⁸. Embora pretendesse partir do projeto Sá Pereira, Alcântara Machado sucumbiu à bateria de críticas – muitas delas, aliás, injustas²⁷⁹ – contra ele assestada, e caminhou para uma formulação original. As influências que seu anteprojeto sofreu são claras e foram pontualmente indicadas em sua Exposição de Motivos²⁸⁰. A maior delas provém

²⁷⁶ Dec. lei nº 88, de 20.dez.37, art. 18, par. ún.; dec.lei nº 431, de 18.mai.38, art. 18.

²⁷⁷ Novas Questões, cit., p. 28.

²⁷⁸ Machado Alcântara, Projeto do Código Criminal Brasileiro, S. Paulo, 1938, ed. RT.

²⁷⁹ Como a concessão de *sursis* a criminosos passionais (art. 120), verberada por Jorge Severiano Ribeiro, as escalas penais benignas para crimes políticos, a possibilidade do condenado à pena de detenção de escolher entre os trabalhos que se executarem no estabelecimento aquele mais conveniente a suas aptidões, inclusive de natureza intelectual (art. 63), a proibição da conversão da pena pecuniária em privativa de liberdade (art. 57) – medida que, sete décadas depois da elaboração inicial do projeto Sá Pereira, converteu-se em lei (nº 9.268, de 1º.abr.96).

²⁸⁰ Op. cit., pp. 11 ss.

do código penal italiano de 1930: “neste, e em outros lances, tomamos por modelo o trabalho de Alfredo Rocco”, diz Alcântara Machado a Francisco Campos²⁸¹. O projeto argentino de 1937, de Jorge E. Coll e Eusebio Gomez, que era uma referência muito acatada entre os penalistas brasileiros daquela conjuntura, é também mencionado, ao lado dos códigos dinamarquês de 1930, cubano e romeno (ambos de 1936), mexicano de 1931 e do projeto francês de 1934. Apesar de ter sido o anteprojeto recebido, no exterior, favoravelmente, foi entre nós alvo de muitos reparos, especialmente de Costa e Silva e Nelson Hungria. Decidiu o ministro da Justiça constituir uma comissão revisora, nomeando para compô-la Nelson Hungria, Roberto Lyra, Vieira Braga e Narcélio de Queiroz. Por influência de Hungria, o ministro solicitou a colaboração, mesmo à distância, de Costa e Silva²⁸². Além de “reviver alguma coisa do projeto Sá Pereira”²⁸³, inspirou-se a comissão nos códigos penais suíço (1937/1942)²⁸⁴, dinamarquês de 1930 e polonês de 1932, para alterar profundamente o anteprojeto Alcântara Machado – especialmente nos dispositivos algo desconexos concernentes à teoria do delito – e cortar sem rebuços da sua carne. Acompanhemos com Hungria o que ele mesmo chamou de “cortes radicais”: foi suprimido o capítulo sobre menoridade penal (art. 102 ss), que conduzia para o interior do código o tratamento do que hoje se designa por atos infracionais da adolescência; rejeitou-se a indistinação entre crime e contravenção, ardentemente defendida por Alcântara Machado em sua Exposição de Motivos; extirparam-se da Parte Especial classes de delitos sujeitas a frequentes redefinições, como aqueles previstos “nas irrequietas leis de segurança nacio-

²⁸¹ Op. cit., p. 27.

²⁸² Sobre essa colaboração, cf. Costa e Silva, A.J., Ligeiras observações sobre o trabalho da comissão revisora na sua primeira fase, em *Justitia*, S. Paulo, 1958, v. 20, pp. 9 ss; Hungria, Nelson, Costa e Silva penalista, em *Novas Questões*, cit., pp. 299 ss.

²⁸³ Hungria, Nelson, A autoria intelectual do Código penal de 1940, em *Comentários*, cit., v. I, p. 210.

²⁸⁴ Embora aprovado em 1937, o código unitário suíço, para atender às contravenções do federalismo cantonal, teve de submeter-se a um *referendum* popular, só entrando em vigor em 1º jan. 42.

nal” ou nas “versáteis leis de falência”; renunciou-se à cominação da pena de morte (arts. 26, inc. I, e 27 ss) ao “assassinio legal”, bem como à pena de segregação (arts. 26, inc. IV e 32), que era na verdade uma medida de segurança; recusou-se – e, no particular, infelizmente – a faculdade do juiz converter em prisão domiciliar a pena de detenção até um mês aplicada a valetudinários e mulheres honestas (art. 31, § 4º); retirou-se do texto o capítulo, de nítida inspiração positivista, que versava a classificação dos criminosos (arts. 20 ss) etc²⁸⁵. Alcântara Machado ressentiu-se de só tomar conhecimento dessas alterações quando os trabalhos da comissão revisora estavam concluídos, chegando a afirmar que ela se reuniria “a portas e janelas fechadas, como se o trabalho tendesse não a repressão, mas a prática de crime”²⁸⁶. Criaram-se ressentimentos que perdurariam até o falecimento do professor paulista. Isso explica porque Hungria sempre exaltou a contribuição de Alcântara Machado para o CP 1940, consignando ser dele “o cerne, a medula, o granito” desse diploma, “a cada passo” do qual “depara-se a marca, o sinal de unha do emérito e saudoso professor”²⁸⁷. Alcântara Machado foi, sem dúvida, entre outros méritos, um penalista competente e atualizado, e basta uma leitura comparativa de seu anteprojeto e do CP 1940 para constatar que estruturas articuladas foram aproveitadas integralmente, apesar de mudanças redacionais (por exemplo, os primeiros oito artigos, sobre aplicação da lei penal), que inúmeras soluções teóricas suas foram mantidas (por exemplo, na definição de tentativa, desistência e crime impossível – arts. 10 e 11 do anteprojeto – ou no erro de direito – art. 14) e que a supressão de alguns dispositivos representou um empobrecimento do texto final (assim, a referência à omissão imprópria – art. 9º, § 1º – ou a disciplina do consentimento do ofendido – art. 14, inc. I). Sem dúvida alguma, o “sinal de unha” de Alcântara Machado está presente por toda parte. Mas as impressões digitais perenemente

²⁸⁵ Os trechos entre aspas do período são de Hungria, A autoria intelectual, cit., pp. 213-214.

²⁸⁶ *Apud* René Dotti, História da legislação penal brasileira, cit., p. 303.

²⁸⁷ A autoria intelectual, cit., pp. 209 e 210.

gravadas no CP 1940 (dec. lei nº 2.848, de 7.dez.40)²⁸⁸ são as de Nelson Hungria, que já não poderia elogiar, sem evidente imodéstia, a Exposição de Motivos assinada por Francisco Campos.

5. A despeito das influências anteriormente assinaladas, e mesmo da mais visível delas – a italiana –, as mudanças econômicas e culturais no período de gestação do CP 1940 se refletem nele, e Hungria retomaria uma passagem de Esmeraldino Bandeira para glosar penalisticamente a política de substituição de importações²⁸⁹, afirmando afinal que o código era “uma resultante da cultura jurídica brasileira”²⁹⁰. Seria descabido dirigir-lhe uma crítica formulada com materiais teóricos ainda indisponíveis, como por exemplo o finalismo, que na ocasião engatinhava, meio clandestinamente, em sua primeira versão. Apesar de falhas pontuais, que seus mais ilustres estudiosos situarão aqui e ali, de acordo com sua própria sensibilidade²⁹¹, o código resultou, como diria Anibal Bruno, “em conjunto, obra de harmoniosa estrutura, de boa técnica, bem redigida, clara, concisa”²⁹². As normas sobre aplicação da lei penal, à frente das quais se insculpia o princípio da legalidade (arts. 1º e 2º), ocupavam os primeiros dez artigos. Do crime tratavam os artigos 11 (sobre relação de causalidade, expressamente adotada a teoria da *conditio sine qua non*) a 27 (que, versando o princípio da executividade na participação, introduzia o princípio geral da lesividade). À tentativa, constru-

²⁸⁸ A lei de introdução ao CP 1940 (bem como a citada lei de contravenções penais – LCP) foi promulgada através do dec. lei nº 3.914, de 9.dez.41. O CP 1940 e a LEP entraram em vigor em 1º de janeiro de 1942.

²⁸⁹ “Mandam (os comentaristas do CP 1890) vir do estrangeiro um por um dos elementos de que se compõe determinado produto, inclusive o invólucro. Reúnem e colam esses elementos e, metendo-o no envólucro refinado, os expõem à venda como produto nacional”. Novas Questões, cit., p. 18.

²⁹⁰ Novas Questões, cit., p. 31.

²⁹¹ Frágoso alertará para a severidade do tratamento penal da greve (Lições, cit., PG., p. 66); Bruno mencionará a subsistência de responsabilidade objetiva (Bruno, Anibal, Direito Penal, Rio, 1959, ed. Forense, v. I, t. 1º, p. 170).

²⁹² Loc. cit.

ria segundo o modelo do início de execução (art. 12, inc. II), cominava-se a pena do crime consumado reduzida de 1 a 2 terços (art. 12, par. ún.), contemplando-se sua desistência (art. 13) e sua inidoneidade (art. 14). A um dolo direto centrado na vontade do resultado corresponde um dolo eventual que postula a assunção do risco de produzi-lo (art. 15, inc. I), enquanto na disciplina da culpa se descartava definitivamente a violação de regulamentos (art. 15, inc. II). Operava o CP 1940 com a dicotomia erro de direito – erro de fato, reduzindo o primeiro à *ignorantia legis* (art. 16); a incompatibilidade de tal redução com o princípio da culpabilidade seria denunciada por nossos penalistas²⁹³. O erro de fato escusável, associado ao que hoje chamamos erro de tipo permissivo (art. 17) “isentava de pena”, expressão que também se aplicava a situações de inimizabilidade (art. 22), à coação irresistível e à obediência hierárquica (art. 18), sinalizando sua função excludente de culpabilidade. Já a expressão “não há crime”, dirigida ao estado de necessidade, à legítima defesa, ao estrito cumprimento de dever legal e ao exercício regular de direito, representava exclusão de ilicitude (arts. 19 ss). Quanto a autoria e participação (arts. 25 ss), Hungria supunha que a adoção pelo código da teoria da *conditio* resolvera todos os problemas, e a disciplina legal a respeito viu-se empobrecida drasticamente²⁹⁴. As penas se dividiam em principais e acessórias. As penas principais eram reclusão, detenção e multa (art. 28), esta última abandonando a criação brasileira do dia-multa (art. 35), que retornaria com a reforma de 1984. Reclusão e detenção se diferenciam no maior rigor penitenciário da primeira (arts. 29 ss). A aplicação da pena se realizava, em duas ou três fases de cálculo (polêmica entre Lyra e Hungria, que a reforma de 1984 encerraria com a opção

²⁹³ Cf. Munhoz Netto, Alcides, A Ignorância da Antijuricidade em Matéria Penal, Rio, 1978, ed. Forense; Assis Toledo, Francisco, O Erro no Direito Penal, S. Paulo, 1977, ed. Saraiva.

²⁹⁴ Cf. Batista, Nilo, Concurso de Agentes – uma investigação sobre os problemas da autoria e da participação no direito penal brasileiro, Rio, 1979, ed. L. Juris.

trifásica), onde intervinham circunstâncias agravantes e atenuantes (arts. 42 ss). Contemplava o CP 1940 a suspensão condicional da pena (arts. 57 ss) e o livramento condicional (arts. 60 ss). As penas acessórias eram três: a perda de função pública, as interdições de direitos e, vestígio moderno da infamação, a publicação da sentença (arts. 67 ss). Previa o CP 1940, sob regime de duplo binário, a aplicação de medidas de segurança detentivas para imputáveis, sob os pressupostos de prática de crime, periculosidade do autor ou ainda tentativa inidônea com autor perigoso (art. 76). Além dos imputáveis ou semi-imputáveis por doença mental, presumiam-se perigosos os condenados por crimes cometidos em estado de embriaguez habitual, os reincidentes em crime doloso, e os filiados a quadrilha (art. 78). Dava-se a caducidade da presunção se a sentença fosse proferida dez anos depois do fato, para os imputáveis, ou cinco anos depois nos outros casos (art. 78, § 1º). A influência do código Rocco é bastante evidente aqui: assim, a regra da aplicabilidade da lei vigente ao tempo da execução da medida de segurança (art. 75) provinha diretamente do artigo 200 do código Rocco. Basileu Garcia foi o primeiro professor brasileiro a denunciar, em artigo de 1945, a natureza penal das medidas de segurança²⁹⁵. Um conjunto de dispositivos sobre a ação penal (arts. 102 ss) e o título sobre extinção da punibilidade (arts. 108 ss) encerram a Parte Geral. A Parte Especial, dividida em onze títulos, começava com os crimes contra a pessoa (arts. 121 ss) e contra o patrimônio (arts. 155 ss), passando pelos delitos contra bens jurídicos comunitários (tit. VIII, crimes contra a incolumidade pública, arts. 250 ss) para chegar aos crimes contra a fé pública (arts. 289 ss) e finalmente os crimes contra a administração pública (arts. 312 ss). Tal disposição, que na ordenação classificada dos tipos prioriza as ofensas ao indivíduo e à comunidade por sobre aquelas contra o Estado, é um último indicador que cabe assinalar acerca das virtudes políticas que o pensamento penalístico brasileiro inscreveu no CP 1940.

²⁹⁵ Cf. Aguiar Serra, Carlos Henrique, *op. cit.*, p. 140.

6. A primeira Constituição republicana, de 1891, dentro do espírito federalista que a dominava, reservava o direito processual para as legislações estaduais, salvo aquele concernente à Justiça Federal (art. 34, inc. 23). Alguns estados, como por exemplo o Rio Grande do Sul, elaboraram códigos de processo penal; a maior parte, no entanto — como por exemplo São Paulo — não o fez, continuando vigentes textos legislativos oriundos do Império, frequentemente acrescidos de leis que versavam aspectos pontuais²⁹⁶. Em 1931, o governo provisório instituiu comissão para proceder à revisão do Código de Processo Penal do Distrito Federal²⁹⁷. A Constituição de 1934 concedeu “privativamente à União” o poder de legislar sobre processo (art. 5º, inc. XIX), e em suas disposições transitórias determinou a nomeação de comissão, integrada por “dois ministros da Corte Suprema e um advogado (...) para elaborar um projeto de Código do Processo Penal” (art. 11), tendo sido escolhidos Bento de Faria, Plínio Casado e Gama Cerqueira. O projeto elaborado por tal comissão, que suprimia o inquérito policial em favor do juizado de instrução, e restringia a então ampla competência do júri, foi concluído em 1935. A Constituição de 1937 manteve a solução da legislação federal sobre processo (art. 16, inc. XVI), porém outra comissão foi nomeada, desta feita integrada por Nelson Hungria, Roberto Lyra, Narcélio de Queiroz, Vieira Braga e Cândido Mendes. Antes de dedicar-se à elaboração do código, tal comissão redigiu o texto que se converteria no dec. lei nº 167, de 5 jan. 38, que além de reduzir a competência do júri permitia que os tribunais de apelação pudessem reformar seus veredictos. Curiosamente, este traço nitidamente anti-liberal de limitar a judicatura popular direta, que na tragédia do chamado caso dos irmãos Naves²⁹⁸ revelou o equívoco da presunção de superioridade das decisões

²⁹⁶ Para São Paulo, cf. Mendes de Almeida, J. Caetano, *Princípios Fundamentais de Processo Penal*, S. Paulo, 1973, ed. RT, pp. 136 ss.

²⁹⁷ Dec. nº 19.684, de 10 fev. 31.

²⁹⁸ Cf. René Dotti, *Casos Criminais Célebres*, cit., pp. 113 ss.

togadas, não costuma ver-se realçado na literatura jurídica. Enfim, a comissão concluiu seu trabalho, convertido em Código de Processo Penal pelo dec. Lei nº 3.689, de 3.out.41, cuja vigência coincidiria com a do Código Penal, iniciando-se em 1º de janeiro de 1942 (art. 810).

7. Uma visão panorâmica da legislação penal extravagante das décadas posteriores ao CP 1940 revelará tendências político-criminais inteiramente compatíveis com o cenário de um sistema penal inscrito num Estado de bem estar. Tais tendências prevalecerão mesmo após o golpe de estado de 1964, quando as oligarquias brasileiras, valendo-se das Forças Armadas²⁹⁹ e com dissimulado mas incontestável apoio norte-americano, depuseram o presidente João Goulart e instauraram uma ditadura. Com efeito, se excetuarmos as leis penais predispostas à repressão manifestamente política (programadoras de um sistema penal que ainda assim as violava rotineiramente, na tortura e mesmo no extermínio de dissidentes do regime, e sobre o qual nos deteremos adiante), constataremos a manutenção, em linhas gerais, daquelas tendências mesmo após 1964. Se desconsiderarmos a legislação penal de ajuste ou "modernização", seja aquela que não altera o CP 1940 (por exemplo, o dec.lei nº 7.661, de 21.jun.45, que, dando nova disciplina às falências, tratou dos crimes falimentares – arts. 186 ss –; a lei nº 3.274, de 2.out.57, que dispôs sobre normas gerais do regime penitenciário; a lei nº 5.256, de 6.abr.67, que regulamentou a prisão especial; a lei nº 4.737, de 15.jul.65, Código Eleitoral com seu elenco de crimes – arts. 283 ss), seja aquela que altera o CP 1940 (por exemplo, o dec.lei nº 7.903, de 27.ago.45, cujos artigos 169 ss revogariam, como reafirmado pelo art. 128 da lei nº 5.772, de 21.dez.71, os capítulos II, III e IV do título II CP 1940, concernentes a crimes contra privilégios

²⁹⁹ Para o papel proeminente do que ele chama de "elite orgânica" nos acontecimentos de 1964, cf. Dreifuss, René Armand, 1964 – A Conquista do Estado, trad. A.B. Oliveira Farias *et alii*, Petrópolis, 1988, ed. Vozes. Cf. também Silva, Hélio, 1964: Golpe ou Contragolpe?, Rio, 1975, ed. Civ. Bras.

de invenção, de violação de marcas e de concorrência desleal³⁰⁰; a lei nº 6.895, de 17.dez.80, que faria uma primeira mudança no delito de violação de direito autoral – art. 184 CP 1940 –, que ainda seria modificado pela lei nº 8.635, de 16.mar.93), podemos classificar as leis penais desse período em cinco grandes grupos. No primeiro deles, encontramos textos legais que efetuam uma correção da legislação anterior, com nítido sentido restritivo do poder punitivo. Enquadram-se aí a lei nº 1.802, de 5.jan.53 (que versou os crimes contra a segurança nacional, numa linha de "abrandamento das penas"³⁰¹), a lei nº 2.505, de 11.jun.55 (que reduziu a pena mínima, prevista no CP 1940 para a receptação – art. 180 –, de 2 anos para 1 ano, tornando-a idêntica à do furto³⁰²), e mesmo a lei nº 5.250, de 9.fev.67, que trata dos crimes através da imprensa³⁰³. O segundo grupo reuniria as leis penais concernentes à intervenção econômica e a delitos fiscais, ainda que a primeira a ser mencionada – a lei nº 1.521, de 26.dez.51, contendo os crimes contra a economia popular – não tenha deixado de mitigar a legislação estadonovista a respeito. Podem incluir-se neste segundo grupo a lei nº 4.591, de 16.dez.64 (que contemplou, nos arts. 65 ss, infrações penais praticáveis nas incorporações imobiliárias), as leis nº 4.728 e 4.729, ambas de 14.jul.65 (a primeira, que disciplinou o mercado de capitais, criminalizando a impressão e comercialização irregulares de ações – arts. 73 e 74 –, e a segunda criminalizando, pela primeira vez sistematicamente, a sonegação fiscal³⁰⁴), o dec.lei nº 16, de 10.ago.66 (que criminalizava a produção, estocagem e transporte irregulares de

³⁰⁰ Hoje, regidos pelos arts. 183 ss da lei nº 9.279, de 14.mai.96.

³⁰¹ Canedo Gonçalves da Silva, Carlos Augusto, Crimes Políticos, B. Horizonte, 1993, ed. Del Rey, p. 101.

³⁰² Hungria afirmava que a escala penal original da receptação era de 2 meses a 4 anos, e que teria havido um erro de impressão. Sua exaltada polêmica com José Duarte a respeito está em Comentários, cit., v. VII, pp. 307 ss.

³⁰³ Para o equívoco de só perceber-se nesta lei um ínatiz autoritário, cf. Batista, Nilo, Lei da censura e lei da imprensa, em Pundós e Mal Pagos, Rio, 1990, ed. Revan, pp. 139 ss.

³⁰⁴ Hoje, regida basicamente pela lei nº 8.137, de 27.dez.90.

açúcar e álcool), o dec. lei nº 66, de 21.nov.66 (introduzindo - art. 155 - os crimes previdenciários³⁰⁵) e a lei nº 4.888, de 9.dez.65 (que equiparava à concorrência desleal o uso, mesmo disfarçado, da palavra *couro* em produtos sintéticos). Num terceiro grupo se artolariam as leis de um direito penal ambiental moderado, cujas imperfeições técnicas - aliás, frequentes nos textos posteriores a 1964 - não merecem relevo superior à cominação preferencial das penas mais leves das contravenções: a lei nº 4.771, de 15.set.65 (contravenções florestais, arts. 26 ss), a lei nº 5.197, de 3.jan.67 (contravenções relativas à fauna, art. 27) e o dec. lei nº 221, de 28.fev.67 (pesca ilícita, art. 61). No quarto grupo inscreveríamos a programação criminalizante que se interessa, sob os mais diversos aspectos, pela constitucionalidade e pela legalidade no exercício da administração pública e pelo patrimônio público. Caberia aqui mencionar a lei nº 1.079, de 10.abr.50 (crimes de responsabilidade, sujeitos, mediante julgamento em foro político, às penas de perda de cargo e inabilitação até 5 anos - art. 2º), a lei nº 1.579, de 18.mar.52 (reforçando penalmente - art. 4º - as Comissões Parlamentares de Inquérito), a lei nº 4.898, de 9.dez.65 (crimes de abuso de autoridade), o dec. lei nº 201, de 27.fev.67 (crimes de responsabilidade de prefeitos e vereadores), a lei nº 5.346, de 3.nov.67 (qualificando o dano praticado sobre patrimônio da administração indireta), a lei nº 5.553, de 6.dez.68 (uma semana antes da edição do Ato Institucional nº 5, que suprimiria o *habeas corpus* para crimes políticos, esta lei considerava contravencional a conduta de reter documento de identificação pessoal de qualquer cidadão: ela seria acrescida de um parágrafo pela lei nº 9.453, de 20.mar.97), a lei nº 3.924, de 26.jul.61 (na qual uma articulação, lesiva por imperfeições técnicas do princípio da legalidade, entre os artigos 5º e 29, revelava a intenção de criminalizar o dano a monumentos arqueológicos e

³⁰⁵ Que seriam alterados pela lei nº 8.212, de 24.jul.91 (art. 95), para finalmente serem introduzidos no Código Penal através da lei nº 9.983, de 14.jul.00, pela criação dos artigos 168-A, 313-A e 313-B, 337-A e alteração dos artigos 153, 296, 297, 325 e 327.

pré-históricos), e a lei nº 6.799, de 23.jun.80 (que acrescia um § 2º ao art. 327 CP, concernente ao conceito penal de funcionário público). Por fim, as leis penais de um quinto grupo teriam o elemento comum de dirigirem-se à proteção especial de sujeitos fragilizados: desde logo a lei nº 2.889, de 1º.out.56 (editada em cumprimento de compromisso internacional, criminalizando o genocídio), a lei nº 1.390, de 3.jul.51 (contravenções penais relativas à discriminação racial³⁰⁶), a lei nº 2.252, de 1º.jul.54 (que criminalizou induzir à prática de crime ou aceitar nela a participação de menor de 18 anos), a lei nº 5.478, de 25.jul.68 (procurando, com a intervenção penal - art. 22 - dar rapidez e eficácia às pensões alimentícias judicialmente fixadas ou acordadas), a lei nº 6.898, de 30.mar.81 (alterando o art. 242 CP, e prevendo perdão judicial para a perfilhação irregular), e a lei nº 7.251, de 19.nov.84 (que aprimorou a redação da modalidade de abandono moral prevista no art. 245 CP). Este quadro, embora não exaustivo³⁰⁷, sinaliza para uma legislação penal extravagante com tendências político-criminais bem distintas daquelas que no futuro viriam a predominar.

8. Referência especial deve ser feita à programação criminalizante vertida para a repressão manifestamente política. A lei nº 1.802, de 5.jan.53, que mitigara o tratamento penal dos crimes políticos, foi revogada pelo dec. lei nº 314, de 13.mai.67, que incorporou conceitualmente a chamada doutrina da segurança nacional. O autoritarismo e o rigor deste texto seria ainda exacerbado pelo dec. lei nº 510, de 20.mar.69, que entre outras emendas determinava a punição de atos preparatórios, sobrevivendo finalmente o dec. lei nº 898 de 29.set.69, que cominava as penas de prisão perpétua e de morte³⁰⁸. Pertencem ainda a este

³⁰⁶ A matéria é hoje versada pela lei nº 7.716, de 5.jan.89.

³⁰⁷ Para a legislação penal sobre drogas ilícitas, cf. Batista, Nílo, Política criminal com derramamento de sangue, cit.

³⁰⁸ Sobre essa legislação, cf. Fragoso, Heleno, Lei de Segurança Nacional, P. Alegre, 1980, ed. Fabris; Canedo Gonçalves da Silva, C.A., Crimes Políticos, cit.; Moraes Filho, A. Evaristo de, Lei de Segurança Nacional - um

núcleo legislativo a lei nº 5.786, de 27.jun.67 (apoderamento ilícito de aeronaves) e o dec.lei nº 975, de 20.out.69 (vôo e pouso não autorizado de aeronaves e transporte de "subversivos"), bem como a indefectível xenofobia legal dos autoritarismos (dec.lei nº 417, de 10.jan.69, sobre expulsão de estrangeiro que atente "contra a segurança nacional" ou "cujo procedimento o torne nocivo ou perigoso à conveniência ou aos interesses nacionais" – art. 1º – e o mais genérico dec.lei nº 941, de 13.out.69, que repete essa fórmula – art. 73). As agências policiais que promoviam a criminalização secundária desta programação excediam sistemática e rotineiramente suas balizas. Conjugando repartições policiais civis e repartições militares³⁰⁹, o sub-sistema penal DOPS/DOI-CODI, especialmente entre 1968 e 1974 – quando organizações políticas clandestinas optaram pelo enfrentamento armado³¹⁰ – torturou, matou e ocultou o cadáver de centenas de pessoas³¹¹. O sub-sistema penal DOPS/DOI-CODI engendrou

atentado à liberdade, Rio, 1982, ed. Zahar; Batista, Nilo, O direito da tortura e da morte, em Temas de Direito Penal, Rio, 1984, ed. L. Juris. O dec.lei nº 898, de 29.set.69, seria revogado pela lei nº 6.620, de 17.dez.78 – que, a despeito de abrandar algumas penas, mantinha menos explicitamente a doutrina da segurança nacional: uma lei "recauchutada", como disse Carlos Drummond de Andrade (cf. Batista, Nilo, Para que serve essa boca tão grande?, em Temas, cit., pp. 34 ss). Eleito o primeiro presidente civil, no chamado processo de "abertura", o ministro da Justiça constituiu comissão (integrada por Evandro Lins e Silva, René Ariel Dotti, Antônio Evaristo de Moraes Filho e Nilo Batista) que redigiu um anteprojeto de lei de defesa do estado democrático (reproduzido em Dotti, René, Reforma Penal Brasileira, Rio, 1988, ed. Forense, pp. 452 ss), que não se converteu em lei. A matéria é hoje tratada pela lei nº 7.170, de 14.dez.83.

³⁰⁹ As primeiras, estaduais, geralmente designadas por Departamento de Ordem Política e Social (DOPS); as segundas, associando um órgão de inteligência (Destacamento de Operações de Informações – DOI) a um órgão operativo (Centro de Operações de Defesa Interna – CODI). Daí falarmos em sub-sistema DOPS/DOI-CODI.

³¹⁰ Para os fundamentos políticos de tal opção, Gorender, Jacob, Combate nas Trevas, S. Paulo, 1987, ed. Ática.

³¹¹ Uma relação de 125 "desaparecidos" em AA.VV. Brasil: Nunca Mais, Petrópolis, ed. Vozes, p. 291. Entre a farta bibliografia sobre o assunto, citam-

uma estrutura que colocou em contacto com a repressão manifestamente política policiais que, a partir do final dos anos cinquenta, haviam dinamizado procedimentos ilegais de execução sumária de suspeitos ou acusados, geralmente de crimes patrimoniais, ou mesmo simplesmente de mendigos, sob a designação de "esquadrão da morte"³¹². As afinidades ideológicas entre os dois pólos que passaram a comunicar-se, bem como sua informalidade com as garantias que controlam o exercício do poder punitivo no estado de direito, podem ser ilustradas com a coincidência de que na repartição policial conhecida por Invernada de Olaria, onde a polícia de Amaury Kruehl no final dos anos cinquenta, inaugurava os esquadrões da morte – matando inclusive mendigos no rio Guandu –, ali mesmo, em 1962, militantes do Movimento Revolucionário Tiradentes eram torturados³¹³, e, em 1972, ao crânio da guerrilheira Aurora Maria Nascimento Furtado era imposto um torniquete (a "coroa de Cristo") que a mataria. Se nos recordarmos também de que, no projeto e na instalação do Departamento Federal de Segurança Pública, em 1965, a assessoria norte-americana era prestada a um irmão de Amaury, o general Riograndino Kruehl³¹⁴, bem como o de que, já depois da reconstitucionalização de 1988, o ex-chefe do DOI-CODI baiano general Nilton Cerqueira – que, entre outros feitos, comandara pessoalmente a execução de Carlos Lamarca – viria a instituir no Rio de Janeiro um sistema de promoções "por bravura" na carreira de policiais, que tomava em consideração a morte de suspeitos, constataremos que toda a atenção deferida por certos

– se Cabral, Reinaldo e Lapa, Ronaldo (orgs.) Desaparecidos Políticos, Rio, 1979, ed. Opção; Guimarães, Renato, Travessa, Rio, 1999, ed. Revan; Frei Betto, Batismo de Sangue, Rio, 1983, ed. Civ. Bras.

³¹² Bicudo, Hélio P., Meu Depoimento sobre o Esquadrão da Morte, S. Paulo, 1977, ed. Pont. Com. Just. e Paz; *America's Watch*, Violência Policial no Brasil, S. Paulo, 1987, ed. OAB-SP; Barcellos, Caco, Rota 66, S. Paulo, 1992, ed. Globo; Rosário, José Barbosa do, Quando a Polícia Mata, Rio, 1983, ed. Achiamé.

³¹³ Gorender, Jacob, Combate nas Trevas, cit., p. 48.

³¹⁴ Huggins, Martha K., Polícia e Política, trad. D. L. Oliveira, S. Paulo, 1998, ed. Cortez, p. 145.

pesquisadores brasileiros ao encontro, nas prisões, entre presos comuns e presos políticos acaba por encobrir este outro, fundamental para a compreensão do atuante sistema penal subterrâneo que, parasitariamente ligado ao oficial, reuniu assassinos de extração distinta num amplo programa de feições genocidas. O fato de grande parte dos militantes torturados nos quartéis pertencer à classe média finalmente deu visibilidade à tortura habitual dos pobres nas delegacias policiais³¹⁵.

9. Nelson Hungria concluiu, em 1963, um anteprojeto de código penal que o breve governo de Jânio Quadros lhe solicitara, dois anos antes, em paralelo a anteprojetos de códigos de processo penal e de execuções penais, de cuja redação se incumbiram respectivamente Hélio Tornaghi e Roberto Lyra. Amplamente divulgado, o anteprojeto Hungria despertou grandes discussões³¹⁶, tendo sido revisto, em 1965, por comissão integrada, além de seu autor, pelos professores Aníbal Bruno, Heleno Fragoso e Hélio Tornaghi. Com sua tramitação empecada pelas conturbadas circunstâncias políticas do período, o anteprojeto Hungria deixa subitamente as gavetas do ministério da Justiça em janeiro de 1969 – o Congresso Nacional fechado, no mês anterior, pelo Ato Institucional nº 5 – e, após um arremedo de revisão cujos constrangimentos foram lembrados por Fragoso³¹⁷, é editado pelo dec. lei nº 1.004, de 21.out.69. Muitas de suas incorreções seriam objeto das retificações da lei nº 6.016, de 31.dez.73, mas sua vigência, várias vezes postergada, não ocorreria jamais³¹⁸. A pá de cal no chamado Código Penal de 1969 fora lançada pela lei

³¹⁵ A tortura seria destacadamente criminalizada pela lei nº 9.455, de 7.abr.97.

³¹⁶ O melhor das polémicas então travadas, inclusive com a apaixonada defesa de seu anteprojeto por Hungria, está nas páginas da Revista Brasileira de Criminologia e Direito Penal, Rio, ed. (C-UPERJ) (do último número de 1963 em diante). Cf. Fragoso, Heleno Cláudio, Subsídios para a História do novo Código Penal, em RDP 3/7 ss.

³¹⁷ Subsídios, cit., p. 11.

³¹⁸ O chamado Código Penal de 1969 seria finalmente revogado pela lei nº 6.578, de 11.out.78.

nº 6.416, de 24.mai.77. Embora de iniciativa do governo militar, e processada perante um enfraquecido Congresso Nacional que a ditadura mantinha em sua vitrine institucional, a lei nº 6.416, de 24.mai.77 respondia a uma pauta político-criminal que os penalistas e criminólogos brasileiros discutiam intensamente desde o início dos anos setenta³¹⁹, questionando de forma geral a eficiência da sanção penal e especialmente o “hiato de legalidade” que a falta de uma lei de execuções penais criava no quadro deplorável de nossa realidade penitenciária. Tal lei dava o primeiro passo no sentido da unificação das penas privativas de liberdade, criando regimes de execução comuns e institucionalizando a prisão-albergue (pioneiramente regulamentada em São Paulo³²⁰) como modalidade do regime aberto, estipulando benefícios ressocializantes a serem regulamentados por legislação estadual, instituindo aos cinco anos a caducidade da reincidência, que não mais se distinguiria entre genérica e específica, ainda alterando positivamente a disciplina do *sursis* e do livramento condicional. A lei nº 6.416, de 24.mai.77, também modificou o Código de Processo Penal e a Lei de Contravenções Penais. Sua maior contribuição, no entanto, consistiu em advertir para as possibilidades frutuosas de uma reforma do CP 1940 substituir-se à sempre adiada vigência do polêmico CP 1969.

10. Antes de passarmos à reforma da Parte Geral do CP 1940, efetuada em 1984 – paralelamente à edição de nossa primeira Lei de Execução Penal (LEP) – convém mirar o sistema penal por ele programado. E isto se faz não porque a reforma de 1984 e a LEP se tenham afastado dos paradigmas político-criminais que se desenvolveram sob a regência do CP 1940, mas sim em razão da superveniência de eixos legislativos extravagantes que mutilariam aqueles paradigmas. A centralização de poder

³¹⁹ A melhor síntese desses debates em René Dotti, História da legislação penal brasileira, cit., pp. 332 ss.

³²⁰ Cf. Silveira, Alípio, Prisão-albergue, S. Paulo, 1981, ed. Brasilvros, 2 vols, que desenvolveu o Teoria e Prática da Prisão-albergue, S. Paulo, 1973, ed. EUD.

promovida a partir de 1930 se refletiu no sistema penal como afirmação da pena pública por sobre o poder punitivo patronal ou coronelístico, que sobrevivia nas dobras do federalismo e do patrimonialismo. Uma tensão irresolúvel se instauraria entre a industrialização, perante a qual a prisão ganha o centro do sistema penal, e o Estado do bem estar (ou previdenciário) que está sendo construído, em suas utopias preventivas — obrigadas, de um lado, a fundamentar positivamente o encarceramento e de outro a ignorar ou minimizar a inevitável deterioração prisional. É o tempo das penitenciárias agrícolas ou industriais, que uma taxa específica — o selo penitenciário, criado em 1934 — permite edificar e manter. Repugna ao Estado previdenciário, que lança sobre a questão criminal um olhar social e não econômico³²¹, o encarceramento assepticamente neutralizador. Para a ética do bem estar, a pergunta sobre o custo do preso está interdita: como poderia o carcereiro questionar o preço da carceragem? As leis extravagantes editadas, como vimos, além do inevitável direito penal da intervenção econômica, têm um sentido limitador do poder punitivo, abrandam penas, tentam proteger sujeitos fragilizados, interessam-se pelo controle de abusos na administração pública e buscam tutelar o patrimônio público. Aquela tensão irresolúvel, entre a necessidade estrutural da prisão no capitalismo industrial e o modelo estatal do bem estar, floresce nos anos setenta num discurso tático de redução da execução da privação de liberdade (*ultima ratio*), bem como nas propostas de descriminalização³²² e no nascente abolicionismo, não por acaso de criação nórdica³²³.

³²¹ Sobre a passagem do que chama de um "estilo" social a um econômico, cf. Garland, David, *The Culture of Control*, 2001, ed. Un.Oxford, pp. 188 ss.

³²² Sua recepção no Brasil em Dotti, René Ariel, *Bases e Alternativas para o Sistema de Penas*, S. Paulo, 1998, ed. RT, pp. 251 ss.

³²³ Sobre as vertentes do abolicionismo, cf. Zaffaroni, E. R., *Em Busca das Penas Perdidas*, trad. V.R. Pedrosa e A. L. Conceição, Rio, 1991, ed. Revan, pp. 97 ss; Carvalho, Salo, *Considerações sobre as incongruências da Justiça Penal Consensual*, em Wunderlich, Alexandre *et alii*, *Diálogos sobre a Justiça Dialogal*, Rio, 2002, ed. L. Juris, pp. 129 ss; Hulsman, Louk e Celis, J.B., *Penas Perdidas*, trad. M.L. Karam, Niterói, 1993, ed. Luam; Hulsman,

Como todas as limitações impostas pela conjuntura política, muito deste pensamento se agrega à lei nº 6.416, de 24.mai.77, que pela primeira vez intervinha estruturalmente no CP 1940. Portanto, se abstrairmos os sistemas paralelos (por exemplo, na institucionalização médico-psiquiátrica, que dialogava com o sistema penal nas medidas de segurança mediante um dialeto positivista, ou na institucionalização da adolescência infratora, servida por um discurso tutelar que se alimentava teoricamente nas medidas de segurança) e os sistemas subterrâneos (como o de Felinto Muller durante o Estado Novo, ou o DOPS/DOI-CODI durante a ditadura militar), veremos no CP 1940 o que ele verdadeiramente foi: o grande eixo programático da criminalização do Estado previdenciário. Não por casualidade, e sim pela força política que lhe era imanente, sobreviveu o CP 1940 às cinco Constituições e ao poderoso rival que a Junta Militar que governava o país decretou em 1969.

Pensar em Clave Abolicionista, trad. A. Vallespir, B. Aires, 1997, ed. Vallespir; Pérez Pinzón, A. O. *La Perspectiva Abolicionista*, Bogotá, 1989, ed. Têmis; Passetti, Edson e Dias da Silva, R.B., *Conversações Abolicionistas*, S. Paulo, 1997, ed. IBCCrim; Christie, Nils, *Los Límites del Dolor*, trad. M. Caso, Mexico., 1984, ed. F. Cult. Económica; Scheerer, Sebastian *et alii* *Abolicionismo*, B. Aires, 1989, ed. Ediar.

V

A reforma da Parte Geral de 1984

1. No final de 1980, o ministério da Justiça instituiu comissões de juristas para a reforma da legislação penal e processual penal, bem como para a criação de uma abrangente lei de execução penal. A comissão para a reforma do direito penal – integrada por Francisco de Assis Toledo, Francisco de Assis Serrano Neyes, Ricardo Antunes Andreucci, Miguel Reale Júnior, Hêlio Fonseca, Rogério Lauria Tucci e René Ariel Dotti – concluiu um anteprojeto de Parte Geral que foi publicado em 1981 para sugestões e debates, sendo posteriormente sua revisão empreendida por outra comissão, composta pelos professores Francisco de Assis Toledo, Dínio de Santis Garcia, Jair Leonardo Lopes e Miguel Reale Júnior. Entendeu-se então conveniente deixar para momento posterior a reforma da Parte Especial³²⁴, e após os procedimentos legislativos foi a Parte Geral do CP 1940 objeto de profunda remodelação (lei nº 7.209, de 11.jul.84, com vigência seis meses após sua publicação – art. 5º –, motivo pelo qual se fala comumente de uma “reforma de 1985”). Também a comissão encarregada de suprir o “hiato de legalidade” do processo executório penal³²⁵ viu, ao contrário daquela dedicada ao proces-

³²⁴ Em setembro de 1983, o ministério da Justiça constituiu comissão para elaborar anteprojeto de reforma da Parte Especial (Francisco de Assis Toledo, Luiz Vicente Cernicchiaro, Miguel Reale Júnior, René Ariel Dotti, Manoel Pedro Pimentel, Everardo da Cunha Luna, Jair Leonardo Lopes, Ricardo Antunes Andreucci, Sérgio Marcos de Moraes Pitombo e José Bonifácio Diniz de Andrade). Cerca de um ano depois, estava o anteprojeto pronto, porém só seria publicado, para críticas e sugestões, em 1987. No final de 1992, nova comissão foi instituída (Evandro Lins e Silva, Francisco de Assis Toledo, Luiz Vicente Cernicchiaro, Alberto Silva Franco, René Ariel Dotti, João Marcello de Araújo Júnior, Juarez Tavares, Jair Leonardo Lopes, Hêlio Bicudo, Paulo Sérgio Pinheiro, Luiza Nagib Eluf e Wandellolk Moreira). Um lustro mais tarde, e nova comissão (Luiz Vicente Cernicchiaro, René Ariel Dotti, Miguel Reale Júnior, Juarez Tavares, Ney Moura Teles, Elia Wiecko Volkmer de Castilho, Licínio Leal Barbosa) se dedicará ao assunto, que resultará num anteprojeto publicado em 1998. Desinteligências evidenciadas no seio de tais comissões apontam para as dificuldades da obra. Com muitas alterações pontuais, continua em vigor a Parte Especial do CP de 1940.

³²⁵ Integrada por Francisco de Assis Toledo, René Ariel Dotti, Benjamin Mora-

so penal, seus esforços frutificaram em nossa primeira lei de execuções penais (lei nº 7.210, de 11.jul.84, que entraria em vigor concomitantemente à lei de reforma da Parte Geral – art. 204).

2. A reforma de 1984 constitui a prova definitiva da vitalidade do CP 1940, expungido de vícios que a conjuntura penalística daquela ocasião lhe impusera (como a má influência italiana quanto às medidas de segurança) e aperfeiçoado por aportes teóricos então indisponíveis (como a nova disciplina do erro). Afastou-se a restrição anterior quanto à retroatividade da lei mais benigna (comparar a redação do parágrafo único do artigo 2º, que colidia com a fórmula constitucional do princípio da legalidade então vigente (art. 153, § 16) e colidiria com a fórmula futura (art. 5º, incs. XXXIX e XL CR). Procurou-se disciplinar a omissão imprópria, caracterizando-se o garantidor (art. 13, § 2º). Atribuiu-se função minorante à reparação do dano, em crimes sem violência ou grande ameaça (art. 16). O princípio da culpabilidade foi ressalvado na hipótese, sempre ameaçadora para ele, dos crimes preterintencionais (art. 19)³²⁶. Notável modificação, ajustada à teoria limitada da culpabilidade, sofreu a disciplina do erro, cabendo perceber aí especial influência da paixão de Francisco de Assis Toledo pelo tema³²⁷. Embora preservada a infecunda concepção extensiva de 1940, temperada agora por uma referência à culpabilidade (art. 29), as regras sobre autoria e participação foram enriquecidas. Para não se afastar da teoria puramente objetiva, no crime continuado, criou-se regra própria para ofensas similares a bens personalíssimos (art. 71, par. ún). Baniram-se as medidas de segurança para sujeitos imputáveis,

es Filho, Miguel Reale Júnior, Rogério Lauria Tucci, Ricardo Antunes Andreucci, Sérgio Marcos de Moraes Pitombo e Negi Calixto. O anteprojeto fora publicado também em 1981.

³²⁶ É curioso que a fórmula adotada tenha sido a mesma sugerida por Costa e Silva a Nelson Hungria (cf. *Novas Questões*, cit., p. 309), finalmente incorporada ao CP quase meio século depois. No entanto, a primazia tocou à legislação penal militar (CPM, art. 34).

³²⁷ Toledo, Francisco de Assis, *Culpabilidade e a problemática do erro jurídico-penal*, em RT 517/251 ss; *O Erro no Direito Penal*, cit.

e substituiu-se pelo vicariante o irracional regime do duplo binário para semi-imputáveis. O sistema de penas foi objeto de primorosa reforma, da qual se destaca em primeiro lugar a quase integral (a subsistência da Parte Especial de 1940, bem como do CPP impediam a total) unificação das penas privativas de liberdade. A partir da quantidade de pena, conjugada à primariedade do condenado, estipula-se o regime: fechado, semi-aberto e aberto (art. 33, § 2º), dispostos em “forma progressiva”. Aquilo que a lei nº 6.416, de 24.mai.77, cometera às legislaturas estaduais ganhava no corpo do código penal suas linhas básicas, enquanto dos pormenores regulamentadores tratava a LEP. As penas restritivas de direito (art. 43: prestação de serviços à comunidade, interdição temporária de direitos e limitação de fim de semana) funcionavam como substitutivos das privativas de liberdade até um ano, ou sem qualquer limite se o crime fosse culposos (art. 44). Na pena de multa, retornava-se ao critério histórico brasileiro do dia-multa (art. 49). Resolvendo polêmica que acompanhara todo o percurso do CP 1940, a aplicação da pena se regeria por um sistema trifásico (arts. 59 e 68). Aprimorou-se a suspensão condicional da pena, adaptando-a ao novo sistema. Talvez o ponto menos feliz da reforma de 1984 esteja na eufemística designação de “efeitos da condenação” para as verdadeiras penas previstas no artigo 92 (nenhuma dúvida quanto aos efeitos contemplados no art. 91). No título relativo à extinção da punibilidade, a chamada prescrição retroativa viu-se finalmente reconhecida em sua plenitude (art. 110, §§ 1º e 2º). Os aspectos ora realçados, que enaltecem a criatividade, a erudição e a sensibilidade dos juristas que colaboraram na reforma, não podem eludir o fato de que muito da Parte Geral anterior foi preservado, de que aquela “harmoniosa estrutura” do CP 1940, à qual se referia Aníbal Bruno, foi o sólido terreno onde puderam eles edificar.

3. Um arrolamento exaustivo da exuberante produção legislativa penal posterior à reforma da Parte Geral de 1984 é desnecessário, de vez que compilações completas podem ser facilmente encontradas, dispostas temática ou cronologicamente, em

diversas edições anuais do código penal³²⁸. Da mesma forma, e tal como se deu anteriormente, na abordagem de programações criminalizantes históricas – não se fará aqui uma listagem estática da rica literatura jurídico-penal brasileira contemporânea, sem embargo das tantas ocasiões em que se recorreu a ela. Com o notável conjunto de monografias e obras gerais produzido a partir da reforma de 1984, e mesmo com os trabalhos anteriores cuja pertinência não se viu afetada pelas retificações legislativas, dialogaremos intensamente nos segundo (dedicado à teoria do delito) e terceiro (dedicado à teoria da pena) volumes deste livro.

4. As representações políticas comprometidas com as transformações econômicas e culturais que, com raízes na crise de 1973, conduziram ao que se costuma chamar de neoliberalismo ou globalização³²⁹, chegaram ao poder no Brasil em 1989 e nele se mantiveram até hoje (2002). A desaceleração do crescimento econômico – acompanhada, em países periféricos como o nosso, da destruição de parques industriais –, a queda nos rendimentos dos trabalhadores que logram escapar ao desemprego massivo ou se submetem à flexibilização de suas garantias ou ao sub-emprego

³²⁸ Destacam-se aquelas organizadas por Juarez de Oliveira (ed. Saraiva, S. Paulo) e por Maurício Antônio Ribeiro Lopes (ed. RT, S. Paulo).

³²⁹ Dentre a farta bibliografia sobre o tema, sugere-se: Bauman, Zygmunt, *Globalização – as consequências humanas*, trad. M. Penchel, Rio, 1999, ed. Zahar, e *O Mal-estar da Pós-modernidade*, trad. M. Gama e C. M. Gama, Rio, 1998, ed. Zahar; Forrester, Viviane, *O Horror Econômico*, trad. A. Lorencini, S. Paulo, 1997, ed. UNESP; Anderson, Perry, *As Origens da Pós-modernidade*, trad. M. Penchel, Rio, 1999, ed. Zahar; Fiori, José Luís, *Os Moedeiros Falsos*, Petrópolis, 1998, ed. Vozes; Sader, Emir (org.), *Pós-neoliberalismo*, S. Paulo, 1995, ed. Paz e Terra; Tavares, Maria da Conceição, *Destruição Não Criadora*, Rio, 1999, ed. Record; Furtado, Celso, *O Capitalismo Global*, S. Paulo, 1998, ed. Paz e Terra; Santos Milton, *Por uma Outra Globalização*, S. Paulo, 2000, ed. Record; Mello, Alex Fiuza de, *Marx e a Globalização*, S. Paulo, 1999, ed. Boitempo; Pochmann, Márcio, *O Emprego na Globalização*, S. Paulo, 2001, ed. Boitempo; Lesbaupin, Ivo (org.), *O Desmonte da Nação*, Petrópolis, 2000, ed. Vozes; Bochi, João Ildebrando (org.), *Restrições Externas e Desenvolvimento Econômico no Brasil*, S. Paulo, 2000, ed. EDUC; Vasconcellos, Gilberto F., *O Príncipe da Moeda*, Rio, 1997, ed. Espaço e Tempo; Ianni, Octavio, *Teorias da Globalização*, Rio, 1995, ed. Civ. Bras.

go, em contraste com uma fantástica acumulação financeira, o desmonte de programas assistenciais públicos característicos do estado previdenciário, tudo isso gera gravíssimas consequências sociais. À reflexão jurídica acerca dessa conjuntura³³⁰ cabe, no âmbito penal, deter-se sobre mutações na estrutura e funcionamento do sistema penal, e um dos indicadores mais importantes reside na programação criminalizante. A hipótese de que o sistema penal do empreendimento neoliberal, vertido para o controle dos contingentes humanos por ele mesmo marginalizados, opera mediante uma dualidade discursiva que distingue os delitos dos consumidores ativos (aos quais correspondem medidas despenalizadoras em sentido amplo) dos delitos grosseiros dos consumidores falhos (aos quais corresponde uma privação de liberdade neutralizadora)³³¹ pode ser experimentada num rápido exame de dois grupos de leis penais extravagantes³³². No primeiro destes grupos encontraremos a lei nº 9.099, de 26.set.95 (criando os Juizados Especiais Criminais, orientados à obtenção da reparação do dano *ex delicto* e à aplicação de pena não privativa de liberdade – art. 62 –, introduzindo a transação penal e a suspensão condicional do processo), a lei nº 9.268, de 1º.abr.96 (que alterou o art. 51 CP para impedir a conversão de multa não paga em privação da liberdade, além de amenizar as condições do *sursis* do

³³⁰ Também exemplificativamente, sugere-se Artuda Júnior, Edmundo Lima, *Direito Moderno e Mudança Social*, B. Horizonte, 1997, ed. Del Rey; Faria, José Eduardo (org.), *Direito e Globalização Econômica*, S. Paulo, 1996, ed. Malheiros; AA.VV. *Direito e Cidadania na Pós-modernidade*, Piracicaba, 2002, ed. UNIMEP; Wunderlich, Alexandre *et alii*, *Diálogos*, cit.; Delmas-Marty, Mireille, *Três Desafios para um Direito Mundial*, trad. F. Hassan Choukr, Rio, 2002, ed. L. Juris.

³³¹ Para essa hipótese, cf. Batista, Nilo, *Os sistemas penais brasileiros*, em Pereira de Andrade, Vera Regina (org.) *Verso e Reverso do Controle Penal*, Florianópolis, 2002, ed. Fund. Boiteux, e Prezada Senhora Viégas, em *DS-CDS*, nº 9/10, pp. 103 ss.

³³² Não nos deteremos sobre a programação criminalizante diretamente inspirada pelas instâncias financeiras internacionais dessa conjuntura. Ao que se poderia, algo jocosamente, designar por “pauta político-crime do FMI” se filiam as leis nº 9.613, de 3.mar.98 (sobre “lavagem” de dinheiro) e nº 10.028, de 19.out.00 (responsabilidade fiscal, também alterando o art. 339 CP).

condenado que reparou o dano), a lei nº 9.714, de 25.nov.98 (que elevou de 1 para 4 anos a possibilidade de substituição de penas privativas de liberdade aplicadas em crimes dolosos, acrescentando contudo a exigência de que em tais crimes não intervesse violência ou grave ameaça, e criando duas novas penas restritivas de direito) e a lei nº 10.259, de 12.jul.01 (que, ao instituir os Juizados Especiais no âmbito na Justiça Federal, dilargou o cabimento da suspensão condicional do processo). Este grupo de leis poderia legitimamente situar-se na linhagem daquele discurso tático de redução da execução da privação da liberdade (*ultima ratio*), se não tivesse como contrapartida necessária sua mais cabal negação. Podemos perceber com clareza esta ambiguidade na exposição de motivos ministerial da mensagem que se converteria na lei nº 9.268, de 1º.abr.96: se o argumento de que “a prisão não vem cumprindo o principal objetivo da pena, que é reintegrar o condenado ao convívio social” fundamentava ali uma notável ampliação do uso substitutivo das penas restritivas de direito, poucas linhas adiante o argumento desaparecia perante “agentes de crimes graves cuja periculosidade recomenda seu isolamento do seio social”, pouco importando que a prisão não viesse cumprindo seu objetivo, o qual, diga-se de passagem, jamais cumpriu. Num segundo grupo de leis encontraremos uma política criminal diametralmente oposta à do primeiro. Podemos formatar boa amostragem com a lei nº 8.072, de 25.jul.90 (que regulamentou, inconstitucionalmente, os “crimes hediondos”³³³, ampliando as duríssimas restrições do texto constitucional³³⁴ e os prazos da prisão temporária, elevando penas e impedindo a progressividade na execução, além de instituir a delação premiada), a lei nº 8.930, de 6.set.94 (que aumentou o rol de crimes hediondos, nele incluindo o homicídio qualificado), a lei nº 9.034, de 3.mai.95 (na qual, a pretexto de investigar a inconsistência conceitual chamada “crime organizado”, sai em campo um juiz inquisidor – art. 3º – que não concederá liberdade provisória – art.

³³³ Cf. *supra* § 15, I, 5.

³³⁴ Comparar o art. 5º, inc. XLIII CR e o art. 2º, incs. I e II da lei.

7º – nem apelação em liberdade – art. 9º)³³⁵, as “leis Serra” de nº 9.677, de 2.jul.98 e nº 9.695, de 20.ago.98 (para alavancar a candidatura presidencial do ministro da Saúde, a primeira delas eleva delirantemente as penas dos crimes contra a saúde pública³³⁶, e a segunda os inclui entre os “crimes hediondos”), a lei nº 9.807, de 13.jul.99 (que atribui à delação eficaz o perdão judicial – art. 13 – e cria benefícios para “réus colaboradores”) e mesmo a lei nº 10.409, de 11.jan.02 (que instituiu o que poderia designar-se por “delação premiada consensual” – art. 32, § § 2º e 3º – e concentrou em audiência única toda a instrução dos casos de drogas ilícitas). Se não poderia causar surpresa a diferença entre duas leis – uma, no Estado previdenciário, e a outra no Estado neoliberal – versando o mesmo objeto³³⁷, aqui se observa fenômeno

³³⁵ Em fevereiro de 2004, o STF finalmente declarou a inconstitucionalidade do art 3º (ADIn nº 1.570, rel. Min. Mauricio Corrêa).

³³⁶ Por exemplo, um birosqueiro que venda um saneante de vasos sanitários por ele adquirido a um laboratório com licença vencida estaria sujeito às penas de reclusão por 10 a 15 anos e multa.

³³⁷ Tomemos como exemplo a prisão especial, que o CPP previa em seu art. 295 para ocupantes de certos cargos públicos, oficiais, magistrados, diplomados em curso superior, ministros de confissão religiosa e jurados. Foi a prisão especial regulamentada pelo dec. lei nº 38.016, de 5.out.55, garantindo “alojamento condigno”, “recreio”, “uso do próprio vestuário”, visitas de advogados e parentes próximos “sem restrições, durante o horário do expediente”, “recepção e transmissão de correspondência livremente” – ressalvada ordenada “autoridade competente” – “assistência de médico particular”, “alimentação” que, em casos especiais, poderia ser “enviada pela família ou por amigos”, e “transporte diferente do empregado para os presos comuns”. A lei nº 5.256, de 6.abr.67, preconizava que onde não houvesse o “estabelecimento adequado”, poderia o Juiz, ouvido o Ministério Público, autorizar a prisão domiciliar, acrescida eventualmente de outras limitações, entre as quais uma vigilância policial “exercida sempre com discrição e sem constrangimento para o réu e sua família” (art. 3º). É claro que este regime legal, característico de um sistema de bem-estar, viu-se estendido, antes e depois do decreto e da lei citados, a inúmeras categorias profissionais, com ou sem alteração do CPP: ainda em 1949, aos oficiais da Marinha Mercante, em 1956 a dirigentes sindicais, em 1957 a servidores públicos, em 1961 a aviadores civis, em 1963 a advogados, em 1967 a policiais civis e também a jornalistas, em 1979, a juizes de paz, em 1983 a professores de 1º e 2º grau etc. As condições carcerárias brasileiras sugeririam que o já tão dilatado privilégio viesse, especialmente após a

distinto: a programação criminalizante neoliberal tem dois caminhos conflitantes, duas inspirações antagônicas, que conduzem à convivência de dois sub-sistemas penais com regras e procedimentos distintos para duas clientelas de extrações sociais igualmente distintas. Nessa distinção Vera Andrade viu "a nova musa do direito penal"³³⁸, porém nem todos os seus cantores percebem, como Jackson De Azevêdo, que as medidas alternativas se instituíram complementarmente ao encarceramento "para abranger uma clientela que nunca foi a da prisão, e mesmo depois de sua implantação manteve a tradição de imunidade: as classes média e alta"³³⁹. De toda sorte, a criação dessas novas agências judiciais – os Juizados Especiais Criminais –, articuladas nos grandes centros urbanos com agências policiais, não deixou de ser o elixir que ressuscitou uma fauna delitosa meio em extinção, aquelas contravenções e aqueles pequenos crimes para os quais já não se dava importância, à mingua de burocracia; as malhas da rede diminuíram. Mas aquele tratamento diferenciado pode mesmo alcançar a teoria do delito, e basta verificar que enquanto para o furto ainda predomina, na caracterização da tentativa, o tradicionalmente aceito critério da *ablatio*, para o roubo – a despeito do

consagração constitucional da presunção de inocência, a generalizar-se completamente. Mas foi em sentido oposto que o legislador neoliberal marchou, ao editar a lei nº 10.258, de 11.jul.01, acrescentando cinco parágrafos ao art. 295 CP. O § 1º esclarece que a prisão especial "consiste exclusivamente no recolhimento em local distinto da prisão comum". O § 2º dispõe que "não havendo estabelecimento específico" – como, aliás, só o legislador não sabia no Brasil – o preso seria recolhido em "cela distinta do mesmo estabelecimento". Apressa-se o § 3º em esclarecer que a "cela especial" – que a tanto já se reduzira a prisão especial – "poderá consistir em alojamento coletivo", tendo a fineza de condicionar o agora "alojamento especial" a sua adequação à "existência humana". O § 4º garante ao preso especial transporte distinto do preso comum, e o § 5º repisa que "os demais direitos e deveres do preso especial serão os mesmos do preso comum". Em síntese, a prisão especial se transformou no transporte especial, e nada mais. Não teria sido mais sincero revoga-la?

³³⁸ No prefácio a Carvalho, Salo de, *A Política Criminal de Drogas no Brasil*, cit., p. 4.

³³⁹ Azevêdo, Jackson C. de, *Reforma e Contra-reforma Penal no Brasil*, Florianópolis, 1999, ed. OAB-SC, p. 108.

núcleo típico ser exatamente, inclusive do ponto de vista gramatical, o mesmo – gradualmente os tribunais passaram a adotar o critério da simples remoção (*amotio*)³⁴⁰. Os novos papéis que a mídia entrou a desempenhar, configurando-se como um conjunto de agências de comunicação social do sistema penal que podem mesmo desempenhar tarefas próprias das agências executivas, resultaram não apenas numa instável legitimação publicitária da hipercriminalização, mas sobretudo num instrumento de compreensão induzida dos conflitos sociais a partir da estreita lógica binária infracional. Este novo sistema penal, na sua face dura, não postula do encarceramento as utopias preventivas ressocializadoras, senão a mais fria e asséptica neutralização do condenado. Enquanto, sob o Estado previdenciário, germinavam instrumentos de proteção da intimidade e da vida privada, o novo sistema do Estado neoliberal, replicante do vigilantismo eletrônico, é invasivo e cultiva a delação, cujo estatuto ético virou-se pelo avesso. A criminalização do protesto e de movimentos sociais significa um retorno ao mote da República velha, segundo o qual a questão social seria um caso de polícia. Os números chocantes do narcogenocídio, dispersos nas páginas policiais em breves notas necrológicas de confrontos policiais, não sensibilizam perante o medo diariamente alavancado para sua legitimação. Como assinala Vera Malaguti Batista, "no Brasil a difusão do medo do caos e da desordem tem sempre servido para detonar estratégias de exclusão e disciplinamento das massas empobrecidas"³⁴¹. O encarceramento cresce alarmantemente, de forma drástica nas áreas nas quais a destruição do parque industrial foi mais inten-

³⁴⁰ Reportando-se a "assentada jurisprudência desta Corte e do STF", STJ, 5ª T, REsp nº 284.105-SP, rel. Min. José Arnaldo da Fonseca, un.; explicitando a adesão à "vertente doutrinária denominada *amotio*", STJ, 6ª T, HC nº 21.812-SP, rel. Min. Fernando Gonçalves, un.

³⁴¹ Malaguti Batista, Vera, *O medo e o método*, em DS-CDS, nº 9/10, p. 188.

sa³⁴², sugerindo a realização da metáfora de Loïc Wacquant³⁴³; é como se se tratasse de um sinistro programa habitacional para os novos pobres. O sistema penal do empreendimento neoliberal é o cenário sombrio no qual o Estado, pateticamente despossuído dos generosos instrumentos assistenciais que outrora teve em mãos, impõe às magras silhuetas dos desajustados e inúteis da nova economia a única intervenção na qual repousa agora sua autoridade: a pena.

³⁴² De 95,5 presos (sobre 100.000 habitantes) em 1995, passamos para 141 em 2002; naturalmente, o estado de São Paulo lidera com a taxa de 276,3 presos (o Distrito Federal tem 269,2, o Rio de Janeiro 147,2 e o Rio Grande do Sul 146,6). Cf. Lemgruber, Julita – Musumeci, Bárbara – Ramos, Silvia, Por que é tão difícil implementar uma política de segurança? Rio, 2002, IBASE, p. 53.

³⁴³ Wacquant, Loïc, Punir os Pobres, Rio, 2001, ed. ICC – F. Bastos; do mesmo, As Prisões da Miséria, trad. A. Telles, 2001, ed. Zahar.